

法律职业资格考试**刑法母题**

二、刑法

140、关于侵犯公民人身权利的犯罪，下列哪一选项是正确的？

- A.甲对家庭成员负有扶养义务而绝扶养，故意造成家庭成员死亡。甲不构成遗弃罪，成立不作为的故意杀人罪
- B.乙闯入银行营业厅挟持客户王某，以杀害王某相要挟，迫使银行职员交给自己20万元。乙不构成抢劫罪，仅成立绑架罪
- C.丙为报复周某，花5000元路费将周某12岁的孩子带至外地，以2000元的价格卖给他人。丙虽无获利目的，也构成拐卖儿童罪
- D.丁明知工厂主熊某强迫工人劳动，仍招募苏某等人前往熊某工厂做工。丁未亲自强迫苏某等人劳动，不构成强迫劳动罪

【答案】C

【解析】

A选项：根据《刑法》第261条：“对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有扶养义务而拒绝扶养，情节恶劣的，成立遗弃罪。”甲对家庭成员负有扶养义务而拒绝扶养，已经构成遗弃罪。其故意造成家庭成员死亡的行为，可能构成不作为的故意杀人罪。综上，甲成立遗弃罪和故意杀人罪的想象竞合犯，应当择一重罪处罚。因此，A选项错误。B选项：根据《最高人民法院关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》中关于抢劫罪与绑架罪的界限中规定：绑架罪是侵害他人人身自由权利的犯罪，其与抢劫罪的区别在于：第一，主观方面不尽相同。抢劫罪中，行为人一般出于非法占有他人财物的

故意实施抢劫行为，绑架罪中，行为人既可能为勒索他人财物而实施绑架行为，也可能出于其它非经济目的实施绑架行为；第二，行为手段不尽相同。抢劫罪表现为行为人劫取财物一般应在同一时间、同一地点，具有“当场性”；绑架罪表现为行为人以杀害、伤害等方式向被绑架人的亲属或其他人或单位发出威胁，索取赎金或提出其他非法要求，劫取财物一般不具有“当场性”。乙控制王某，胁迫银行职员交付财产，属于以非法占有为目的压制反抗、强行取财的行为，满足“当场性”条件，成立抢劫罪。因此，B选项错误。C选项：《刑法》第240条第2款规定：“拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的，有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。”丙虽然不是以营利为动机，但其以出卖为目的无疑，因此是否以营利为动机以及最终是否营利都不影响拐卖儿童罪的认定。丙将周某12岁的孩子带往外地卖给他人的行为已经成立拐卖儿童罪。因此，C选项正确。D选项：《刑法》第244条第2款规定：“明知他人实施前款行为，为其招募、运送人员或者有其他协助强迫他人劳动行为的，成立强迫劳动罪。”丁明知工厂主熊某强迫工人劳动，仍招募苏某等人前往熊某工厂做工，成立强迫劳动罪的帮助犯。因此，D选项错误。（注：由于刑法分则对其明确了处罚条款，因此该情形不适用总则关于帮助犯的处罚原则。）综上所述，本题答案为C。

141、甲架好枪支准备杀乙，见已患绝症的乙踉跄走来，顿觉可怜，认为已无杀害必要。甲收起枪支，但不小心触动扳机，乙中弹死亡。关于甲的行为定性，下列哪一选项是正确的？

- A.仅构成故意杀人罪（既遂）
- B.仅构成过失致人死亡罪
- C.构成故意杀人罪（中止）、过失致人死亡罪

D.构成故意杀人罪（未遂）、过失致人死亡罪

【答案】C

【解析】

甲在犯罪过程中，自动放弃犯罪，属于“能达目的而不欲”，成立故意杀人罪（中止），而不是由于意志以外的原因未得逞，不属于“欲达目的而不能”，不成立故意杀人罪（未遂）。甲收起枪支时，不小心触动扳机，导致乙中弹身亡，此行为是独立于前行为的第二个行为，另行成立过失致人死亡罪，对甲应以故意杀人罪（中止）、过失致人死亡罪数罪并罚。乙的死亡不是由于甲的故意杀人行为导致的，与甲的故意杀人行为没有因果关系，故不成立故意杀人罪（既遂）。C项正确。

142、关于故意杀人罪、故意伤害罪的判断，下列哪一选项是正确的？

- A.甲的父亲乙身患绝症，痛苦不堪。甲根据乙的请求，给乙注射过量镇定剂致乙死亡。乙的同意是真实的，对甲的行为不应以故意杀人罪论处
- B.甲因口角，捅乙数刀，乙死亡。如甲不顾乙的死伤，则应按实际造成的死亡结果认定甲构成故意杀人罪，因为死亡与伤害结果都在甲的犯意之内
- C.甲谎称乙的女儿丙需要移植肾脏，让乙捐肾给丙。乙同意，但甲将乙的肾脏摘出后移植给丁。因乙同意捐献肾脏，甲的行为不成立故意伤害罪
- D.甲征得乙（17周岁）的同意，将乙的左肾摘出，移植给乙崇拜的歌星。乙的同意有效，甲的行为不成立故意伤害罪

【答案】B

【解析】

A选项：《刑法》第232条规定了故意杀人罪，生命是人最重要的权益，刑法认

为生命不具有可放弃性，放弃生命的承诺是无效的。故为免除患者的痛苦而提前结束其生命的行为，不阻却行为的违法性。甲即使取得了乙的真实的承诺，仍成立故意杀人罪。因此，A 选项错误。B 选项：《刑法》第 234 条规定了故意伤害罪，甲不顾乙的死伤，说明甲既有故意杀人的故意又有故意伤害的故意，根据主客观相一致原则，应按照实际造成的结果认定甲所构成的犯罪。本案中，由于造成了乙死亡的结果，故甲构成故意杀人罪。因此，B 选项正确。C 选项：《刑法》第 234 条第 2 款规定：“未经本人同意摘取其器官，或者摘取不满十八周岁的人的器官，或者强迫、欺骗他人捐献器官的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。”甲对乙实施了欺骗行为，让乙误以为其将器官捐献给了甲的女儿丙，实际上，甲将乙的肾脏移植给了丁，乙的捐献承诺并不是真实有效的，故甲的行为符合《刑法》第 234 条第 2 款的规定，应当以故意伤害罪论处。因此，C 选项错误。D 选项：《刑法》第 234 条第 2 款规定：“未经本人同意摘取其器官，或者摘取不满十八周岁的人的器官，或者强迫、欺骗他人捐献器官的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。”乙未满 18 周岁，不论甲是否取得其同意，甲摘取乙器官的行为，都构成故意伤害罪。因此，D 选项错误。综上所述，本题答案为 B。

143、甲男（15 周岁）与乙女（16 周岁）因缺钱，共同绑架富商之子丙，成功索得 50 万元赎金。甲担心丙将来可能认出他们，提议杀丙，乙同意。乙给甲一根绳子，甲用绳子勒死丙。关于本案的分析，下列哪一选项是错误的？

- A. 甲、乙均触犯故意杀人罪，因而对故意杀人罪成立共同犯罪
- B. 甲、乙均触犯故意杀人罪，对甲以故意杀人罪论处，但对乙应以绑架罪论处
- C. 丙系死于甲之手，乙未杀害丙，故对乙虽以绑架罪定罪，但对乙不能适用“杀

害被绑架人”的规定

D.对甲以故意杀人罪论处，对乙以绑架罪论处，与二人成立故意杀人罪的共同犯罪并不矛盾

【答案】C

【解析】

根据《刑法》第 239 条的规定，绑架杀害被绑架人的（俗称“撕票”），仍构成绑架罪一罪，处死刑。这属于结合犯，即将绑架行为与故意杀人行为结合为一个罪。但适用本条的前提是行为人已经达到了绑架罪所要求的刑事责任年龄——已满 16 周岁。如果是已满 14 不满 16 周岁的人参与绑架他人，并杀害被绑架人的，则其只对故意杀人行为负责，对绑架行为不负责，对其只能以故意杀人罪追究刑事责任，而不能以绑架罪追究刑事责任。本案中，甲男与乙女共同实施了绑架行为，并将被绑架人杀害。但甲男只有 15 周岁，所以，甲男对绑架行为不负责，只对故意杀人行为负责，对甲男不能定绑架罪，只能定故意杀人罪。而乙女已满 16 周岁，其既要对其绑架行为负责，也要对其故意杀人行为负责，其既触犯了绑架罪，也触犯了故意杀人罪，只不过基于《刑法》第 239 条的特殊规定，对乙女无须以绑架罪和故意杀人罪数罪并罚，只对乙女以绑架罪一罪定罪处罚即可。当然，由于甲、乙二人均需对故意杀人行为负责，均触犯故意杀人罪，同时，二人又具有杀人的共同故意，所以，可以认为他们在故意杀人罪的范围内成立共同犯罪。结合上述分析，我们可以得出如下结论：甲、乙二人均触犯故意杀人罪，在故意杀人罪的范围内成立共同犯罪，但在最后的罪名上，对甲应以故意杀人罪论处，对乙应以绑架罪论处。所以，A、B、D 项说法均是正确的。至于 C 项，由于甲、乙二人属于共同犯罪，所以，即使丙是由甲杀死的，乙也要对丙的死亡

负责，对乙应适用“杀害被绑架人”的规定，处死刑，故C项错误。本题答案为C项。

144、首要分子甲通过手机指令所有参与者“和对方打斗时，下手重一点”。在聚众斗殴过程中，被害人被谁的行为重伤致死这一关键事实已无法查明。关于本案的分析，下列哪一选项是正确的？

- A.对甲应以故意杀人罪定罪量刑
- B.甲是教唆犯，未参与打斗，应认定为从犯
- C.所有在现场斗殴者都构成故意杀人罪
- D.对积极参加者按故意杀人罪定罪，对其他参加者按聚众斗殴罪定罪

【答案】A

【解析】

根据《刑法》第292条第1款的规定，聚众斗殴罪是指聚集多人攻击对方身体或者相互攻击对方身体的行为。根据本条第2款规定，聚众斗殴致人重伤、死亡的，以故意伤害罪、故意杀人罪定罪处罚。关于此规定，要特别注意两点：第一，这一规定属于法律拟制。所以，行为人在斗殴过程中即使没有杀人的故意，但只要客观上致人重伤、死亡的，就应认定为故意伤害罪、故意杀人罪。第二，鉴于聚众斗殴的特殊性，根据责任主义原则，只应对直接造成死亡的斗殴者和首要分子认定为故意杀人罪，对其他参与者不宜认定为故意杀人罪；在不能查明死亡原因的情况下，也不宜将所有的斗殴者均认定为故意杀人罪，仅应对首要分子以故意杀人罪论处。如果不作上述限制，那么，在一人死亡的情况下，斗殴双方的所有参加者都成立故意杀人罪，这有悖于刑法的谦抑性。本案中，第一，行为人实施的行为属于聚众斗殴行为，虽然看得出来行为人具有杀人的故意，但基于《刑

法》第 292 条第 2 款的拟制规定，由于发生了被害人重伤致死的结果，仍应对有关行为人以故意杀人罪论处。第二，由于不能查明被害人被谁的行为重伤致死，故只能对首要分子甲以故意杀人罪定罪处罚，对其他参加者均不能认定为故意杀人罪。所以，A 项正确，C、D 项错误。根据《刑法》第 29 条第 1 款的规定，教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。据此，教唆犯如果起主要作用，属于主犯，如果起次要作用，则属于是从犯。而在聚众犯罪成立共同犯罪的情况下，首要分子均是其组织、策划、指挥作用的犯罪分子，即属于起主要作用的犯罪分子，应认定为主犯。这就意味着，在聚众犯罪成立共同犯罪的情况下，如果教唆犯同时是首要分子，则应将其认定为主犯。本案中，甲属于教唆犯，但其同时属于聚众犯罪的首要分子，故甲属于主犯，而非从犯。B 项错误。综上所述，本题答案为 A。

145、警察带着警犬（价值 3 万元）追捕逃犯甲。甲枪中只有一发子弹，认识到开枪既可能只打死警察（希望打死警察），也可能只打死警犬，但一枪同时打中二者，导致警察受伤、警犬死亡。关于甲的行为定性，下列哪一选项是错误的？

- A.如认为甲只有一个故意，成立故意杀人罪未遂
- B.如认为甲有数个故意，成立故意杀人罪未遂与故意毁坏财物罪，数罪并罚
- C.如甲仅打中警犬，应以故意杀人罪未遂论处
- D.如甲未打中任何目标，应以故意杀人罪未遂论处

【答案】B

【解析】

A 选项：如认为甲只有一个故意，则其故意是希望打死警察，即甲只具有故意杀人罪的故意。但是甲一枪同时打中二者，导致警察受伤、警犬死亡。因此甲故意

杀人的目的并未实现，且是由于意志以外的原因，所以甲成立故意杀人罪未遂。因此，A 选项正确。B 选项：如认为甲有数个故意，则其故意是既希望打死警察（杀人故意），也希望打死警犬（故意毁坏财物）。但甲枪中只有一发子弹，一枪同时打中二者，一个行为触犯两个罪名，属于想象竞合犯，只能择一重罪论处，而不能数罪并罚。因此，B 选项错误。C 选项：甲枪中只有一发子弹，认识到开枪可能打死警察（希望打死警察，具有杀死警察的故意），但甲仅打中警犬，其对警察的故意杀人内容因意志以外的因素未能实现，成立故意杀人罪未遂。因甲认识到自己可能打死警犬（其对警犬的死亡具有间接故意），而其最终打死警犬的行为可评价为故意毁坏财物罪。甲一行为触犯两罪名，是想象竞合犯，应择一重罪处理，即按故意杀人罪未遂论处。因此，C 选项正确。D 选项：甲枪中只有一发子弹，认识到开枪可能打死警察（希望打死警察），但甲未打中任何目标，其对警察的故意杀人内容因意志以外的因素未能实现，成立故意杀人罪未遂。甲认识到开枪可能打死警犬，但甲未打中任何目标，认定为故意毁坏财物未遂，而刑法理论通常认为故意毁坏财物的未遂不处罚。理论上说，甲一行为触犯两罪名，是想象竞合犯，应择一重罪处理，即按故意杀人罪未遂论处。因此，D 选项正确。综上所述，本题答案为 B。

146、甲以伤害故意砍乙两刀，随即心生杀意又砍两刀，但四刀中只有一刀砍中乙并致其死亡，且无法查明由前后四刀中的哪一刀造成死亡。关于本案，下列哪一选项是正确的？

- A.不管是哪一刀造成致命伤，都应认定为一个故意杀人罪既遂
- B.不管是哪一刀造成致命伤，只能分别认定为故意伤害罪既遂与故意杀人罪未遂
- C.根据日常生活经验，应推定是后两刀中的一刀造成致命伤，故应认定为故意伤

害罪未遂与故意杀人罪既遂

D.根据存疑时有利于被告人的原则,虽可分别认定为故意伤害罪未遂与故意杀人罪未遂,但杀人与伤害不是对立关系,故可按故意伤害(致死)罪处理本案

【答案】D**【解析】**

关于故意伤害罪与故意杀人罪的关系,存在两种理论:(1)对立理论认为,杀人与伤害是两个相互排斥的概念,杀人故意排除伤害故意,故杀人不包含伤害。(2)单一理论认为,杀人行为必然包含伤害行为,杀人故意必然包含伤害故意。事实上,任何杀人既遂都必然经过了伤害过程,任何杀人未遂也必然造成了伤害结果或者具有造成伤害结果的危险性。显然,单一理论具有合理性。本题采纳的是单一理论。在本案中,前两刀是伤害的故意,后两刀是杀人的故意,如果是前两刀中的一刀致乙死亡,则对甲应认定为故意伤害致人死亡;如果是后两刀中的一刀致乙死亡,对甲应认定为故意杀人既遂。所以,A项的说法错误。在无法查明是哪一刀致人死亡的情况下,应本着“存疑有利于被告”的原则予以认定。如果推定是后两刀中的一刀致人死亡,显然是不利于被告的,C项错误。由于被害人仅身中一刀,但无法查清是哪一刀导致的致命伤,既无法证明仅具有伤害故意的前两刀和伤亡之间具有因果关系,也无法证明仅具有杀人故意的后两刀和死亡之间具有因果关系,所以,既不能对前两刀认定为故意伤害既遂,也不能对后两刀认定为故意杀人既遂,根据“存疑有利于被告”的原则,对前两刀和后两刀可分别认定为故意伤害未遂和故意杀人未遂。但是,由于杀人的故意包含着伤害的故意,杀人的行为包含着伤害的行为,所以,可以将甲主观上整体评价为伤害的故意,客观上四刀整体评价为伤害行为,这样,无论是哪一刀致人死亡的,都是在甲伤

害故意支配下，由甲的伤害行为导致的死亡，从而将甲的行为评价为故意伤害致人死亡。D项正确。

147、吴某被甲、乙合法追捕。吴某的枪中只有一发子弹，认识到开枪既可能打死甲也可能打死乙。设定吴某对甲、乙均有杀人故意，下列哪一分析是正确的？

A.如吴某一枪没有打中甲和乙，子弹从甲与乙的中间穿过，则对甲、乙均成立故意杀人罪未遂

B.如吴某一枪打中了甲，致甲死亡，则对甲成立故意杀人罪既遂，对乙成立故意杀人罪未遂，实行数罪并罚

C.如吴某一枪同时打中甲和乙，致甲死亡、乙重伤，则对甲成立故意杀人罪既遂，对乙仅成立故意伤害罪

D.如吴某一枪同时打中甲和乙，致甲、乙死亡，则对甲、乙均成立故意杀人罪既遂，实行数罪并罚

【答案】A

【解析】

A选项：想象竞合犯是指一个行为触犯了数个罪名的情况。吴某对甲、乙均有杀人故意，吴某开枪后，子弹从甲与乙的中间穿过，但是吴某的行为对于甲和乙的生命均有侵犯的紧迫危险性，有危险结果。但由于意志以外的原因而未打中二人，应当判定为未遂，所以对甲、乙两人都应该成立故意杀人罪的未遂。由于只有一个行为属于想象竞合犯，根据想象竞合犯的处理原则，应当按照一个故意杀人罪未遂处理。但是在对该行为评价时，应当充分、全面、完整地评价其行为，即对甲、乙均成立故意杀人罪的未遂。因此，A选项正确。B选项：由于吴某只实施了一个行为，属于想象竞合犯。吴某只开了一枪，且主观上有杀死甲的故意，其

最终打死了甲，对甲成立故意杀人罪既遂；其主观上具有杀死乙地故意，但未杀死乙，对乙最多成立故意杀人罪未遂。由于吴某只实施了一个行为，属于想象竞合犯，应当从一重罪论处。因此，B选项错误。C选项：由于吴某对甲有杀人故意，如吴某一枪同时打中甲和乙，致甲死亡，其对甲造成死亡的结果，应当评价为故意杀人罪既遂；由于吴某对乙也有杀人故意，如吴某一枪同时打中甲和乙，致乙重伤，其对乙造成重伤的结果，可以成立故意杀人罪未遂也可以成立故意伤害罪，但应当优先适用特别法条（故意杀人罪），应当评价为故意杀人罪未遂。因此，C选项错误。D选项：在主观层面，吴某对甲、乙都有杀人的故意，此时，若吴某一枪同时将甲和乙击中，致使甲、乙两人均死亡，则吴某对甲、乙的死亡均成立故意杀人罪既遂。但若仅一个杀人行为，此时系一行为触犯数罪名的，刑法理论称之为想象竞合，按照其处罚规则，应当择一重罪论处而非适用数罪并罚规则。因此，D选项说法错误。综上所述，本题答案为A。

148、甲、乙、丙共同故意伤害丁，丁死亡。经查明，甲、乙都使用铁棒，丙未使用任何凶器；尸体上除一处致命伤外，再无其他伤害；可以肯定致命伤不是丙造成的，但不能确定是甲造成还是乙造成的。关于本案，下列哪一选项是正确的？

- A.因致命伤不是丙造成的，尸体上也没有其他伤害，故丙不成立故意伤害罪
- B.对甲与乙虽能认定为故意伤害罪，但不能认定为故意伤害（致死）罪
- C.甲、乙成立故意伤害（致死）罪，丙成立故意伤害罪但不属于伤害致死
- D.认定甲、乙、丙均成立故意伤害（致死）罪，与存疑时有利于被告的原则并不矛盾

【答案】D

【解析】

A 选项：《刑法》第 25 条第 1 款规定“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”按照犯罪的阶层理论，犯罪的实体包含违法与责任，而共同犯罪是一种违法形态，共同犯罪的立法与理论知识解决违法层面的问题，即将违法事实归属于哪些参与人的行为，而非解决责任层面的问题。换言之，只要认定成立共同犯罪，无论各参与者能否承担责任，只要参与人的行为与结果之间具有物理的因果性或者心理的因果性，即使查明侵害结果由其中一人直接造成，或者不能查明具体的结果由谁的行为直接造成，也要将法益侵害结果归属于各方参与者的行为。甲、乙、丙三人共谋伤害丁，其三人成立共同犯罪，应将致人死亡的违法事实归属于所有为这个违法事实发挥了作用力的人。本案虽然确定了丁的致命伤不是丙造成的，但丙在参与实施伤害行为的时候，为伤害行为至少起到了心理的强化作用，也应将死亡归属于丙，丙成立故意伤害（致死）罪。因此，A 选项错误。 B. C 选项：按照违法层面的共犯理论，甲、乙、丙共同实施了致丁死亡的故意伤害行为，其行为与丁的死亡之间都具有因果关系，甲、乙、丙具有共犯关系；由于甲、乙、丙都具有故意伤害的故意，且不具有责任阻却事由，故甲、乙、丙都成立故意伤害致死罪。因此，B. C 选项错误。 D 选项：存疑时有利于被告的原则，是指在现有证据不能证明行为人的行为与结果之间具有因果关系时，按照有利于被告的原则，行为人不需要对该结果负责。甲、乙、丙成立共同犯罪，三人均应对致人死亡的事实结果负责。甲、乙、丙三人均成立故意伤害（致死）罪，与存疑时有利于被告的原则并不矛盾，该原则是在无法确定因果联系时才考虑的，本

案不存在这样的问题。如果三人属于同时正犯，才有可能适用存疑时有利于行为人的原则。因此，D选项正确。综上所述，本题答案为D。

149、翟某与彭某在农贸市场内嬉戏打闹，彭某拿着棍棒追打翟某，犯某手持尖刀在彭某面前挥舞，以阻挡彭某靠近，不慎将尖刀刺入彭某腹部，致使彭某受到重伤。翟某的行为构成？

- A.故意伤害罪既遂，属于间接故意
- B.过失致人重伤罪，属于疏忽大意的过失
- C.正当防卫
- D.相互斗殴

【答案】B

【解析】

A项，故意伤害罪，是指故意非法损害他人身体健康的行为。本罪侵犯的法益是他人的身体健康权。注意，不是任何暴行行为都是故意伤害罪中的伤害行为。伤害行为的成立条件：（1）主观心理具有侵害他人生理机能达到轻伤程度的意图（行凶意图）。（2）客观行为具有侵害他人生理机能达到轻伤程度的一般可能性。本题中，翟某与彭某嬉戏打闹，双方没有伤害对方的故意，没有行凶的意图。因此，翟某不构成故意伤害罪。B项考查疏忽大意的过失与意外事件的区分。二者的相同点：二者都没有预见到危害结果可能发生。二者的区分点：疏忽大意的过失是应当预见而没有预见，意外事件是因无法预见而没有预见。判断核心点在于是否具有结果预见可能性，判断标准：一是看行为人主观上的认识和预见能力；二是看客观上的认识条件和环境。

常见错误：误将“没有预见”当作“没有预见可能性”。“没有预见”不等于“没有预见可能性”。本题中，虽然翟某没有预见到自己的行为会导致影某受到重伤，但是具有预见到的可能性，因此属于疏忽大意的过失，构成过失致人重伤罪。C项，正当防卫是指制止正在进行的不法侵害。本题中，翟某与彭某嬉戏打闹，双方没有伤害对方的故意，没有行凶的不法意图。彭某对看某的举动属于嬉闹，不属于不法侵害。因此，翟某的行为不属于正当防卫。D项，相互斗殴，是指双方都出于侵害对方的意图而相互攻击，也即不法侵害对不法侵害这种情形类似于决斗。法谚有云：斗殴无防卫。理由：第一，防卫认识必要说的理由是，斗殴双方均没有防卫意思，均有不法侵害的意图。第二，防卫认识必要说和不要说的共同理由是被害人承诺（斗殴有承诺）。具体而言，双方意识到斗殴会使自己受伤，仍自愿参与斗殴，表明对可能出现的伤害结果有预见、有承诺。基于被害人承诺原理，任何一方的斗殴行为均属于得到承诺的行为，不具有法益侵害性。但是，被害人承诺中对承诺的事项有限定，轻伤害可以承诺放弃，重伤害及生命即使承诺放弃也无效。因此，相互斗殴中，一方将另一方打成轻伤，不构成故意伤害罪，但打成重伤或打死，则成立犯罪。当然，相互斗殴中也会出现正当防卫的情形。本题中，翟某与彭某属于嬉戏打闹，双方没有伤害对方的故意，对对方都不是不法侵害，因此不属于刑法上的相互斗殴。综上所述，本题答案为B。

150、甲为勒索财物，打算绑架富商之子吴某（5岁）。甲欺骗乙、丙说：“富商欠我100万元不还，你们帮我扣押其子，成功后给你们每人10万元。”乙、丙

将吴某扣押，但甲无法联系上富商，未能进行勒索。三天后，甲让乙、丙将吴某释放。吴某一人在回家路上溺水身亡。关于本案，下列哪一选项是正确的？

- A.甲、乙、丙构成绑架罪的共同犯罪，但对乙、丙只能适用非法拘禁罪的法定刑
- B.甲未能实施勒索行为，属绑架未遂；甲主动让乙、丙放人，属绑架中止
- C.吴某的死亡结果应归责于甲的行为，甲成立绑架致人死亡的结果加重犯
- D.不管甲是绑架未遂、绑架中止还是绑架既遂，乙、丙均成立犯罪既遂

【答案】D

【解析】

A 选项：根据《刑法》第 238 条第 3 款的规定，行为人为索取债务非法扣押、拘禁他人的，只构成非法拘禁罪，不成立绑架罪。本案中，甲具有绑架的故意，并实施了绑架的行为，成立绑架罪。乙、丙主观上是因索取债务而扣押吴某，既没有绑架的故意，也没有绑架行为，故乙、丙成立非法拘禁罪，不可能将乙、丙认定为绑架罪的共犯。因此，A 选项错误。B 选项：绑架罪是指以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的行为。只要行为人开始实施以实力控制他人的行为，就是绑架罪的着手；一旦以实力控制他人，绑架罪就已既遂。本案中，甲通过第三人控制了人质吴某，使吴某处于第三者（乙、丙）的实力支配之下，其已经构成绑架罪的既遂。不存在绑架罪的未遂和中止状态。因此，B 选项错误。C 选项：结果加重犯的成立需要具备直接性要件，结果加重犯中的“结果”属于规范所保护目的范围内的结果。本案中，吴某的死亡并不是由甲的绑架行为直接造成的，故不成立绑架致人死亡的结果加重犯。因此，C 选项错误。D 选项：我

国《刑法》第 238 条第 3 款规定：“为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚”，即成立非法拘禁罪。因此乙、丙针对扣押吴某的行为只承担非法拘禁的责任，而非法拘禁的行为已经控制了被害人，故不论甲的行为如何评价，乙、丙两人成立非法拘禁罪的既遂。因此，D 选项正确。综上所述，本题答案为 D。

151、甲杀丙后潜逃。为干扰侦查，甲打电话让乙将一把未留有指纹的斧头粘上丙的鲜血放到现场。乙照办后报案称，自己看到“凶手”杀害了丙，并描述了与甲相貌特征完全不同的“凶手”情况，导致公安机关长期未将甲列为嫌疑人。关于本案，下列哪一选项是错误的？

- A.乙将未留有指纹的斧头放到现场，成立帮助伪造证据罪
- B.对乙伪造证据的行为，甲不负刑事责任
- C.乙捏造事实诬告陷害他人，成立诬告陷害罪
- D.乙向公安机关虚假描述“凶手”的相貌特征，成立包庇罪

【答案】C

【解析】

A 选项：根据《刑法》第 307 条第 2 款规定的帮助伪造证据罪是指帮助诉讼活动的当事人伪造证据，情节严重的行为。本案中，乙将未留有指纹的斧头粘上丙的鲜血放到现场，凭空制造了一个证据，导致公安机关长期未将甲列为嫌疑人，其行为已构成帮助伪造证据罪（这里的帮助不是帮助犯的帮助，该行为属于正犯行为）。因此，A 选项正确。B 选项：帮助伪造证据罪是行为人帮助诉讼活动的当事人伪造证据。当事人对于行为人帮助自己伪造证据的行为，因不具有期待可能性，不负刑事责任。因此，B 选项正确。C 选项：根据《刑法》第 243 条第 1

款的规定，捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，构成诬告陷害罪。诬告陷害罪侵犯的法益是公民的人身权利、民主权利，其对象是具体的人，是存在着的人。乙捏造了一个不存在的人，没有侵犯具体某个人的法益，故不具有侵犯他人人身权利、民主权利的可能性，不成立诬告陷害罪。因此，C选项错误。D选项：《刑法》第310条规定的窝藏、包庇罪是指明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的行为。本案中，乙明知甲是杀人凶手，但故意向公安机关虚假描述一个与甲完全不一样的“凶手”的相貌特征。乙向公安机关作假证明，意图包庇他人的行为，构成包庇罪。因此，D选项正确。综上所述，本题答案为C。

152、关于诬告陷害罪的认定，下列哪一选项是正确的(不考虑情节)?

- A.意图使他人受刑事追究，向司法机关诬告他人介绍卖淫的，不仅触犯诬告陷害罪，而且触犯侮辱罪
- B.法官明知被告人系被诬告，仍判决被告人有罪的，法官不仅触犯徇私枉法罪，而且触犯诬告陷害罪
- C.诬告陷害罪虽是侵犯公民人身权利的犯罪，但诬告企业犯逃税罪的，也能追究其诬告陷害罪的刑事责任
- D.15周岁的人不对盗窃负刑事责任，故诬告15周岁的人犯盗窃罪的，不能追究行为人诬告陷害罪的刑事责任

【答案】C

【解析】

A选项：根据《刑法》第243条第1款的规定，捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，构成诬告陷害罪。本项中，介绍卖淫的行为可

能成立介绍卖淫罪,那么带有使他人受刑事追究的意图并向司法机关诬告他们卖淫的行为构成诬告陷害罪。而侮辱罪是指使用暴力或者其他方式公然侮辱他人,败坏他人名誉,情节严重的行为。本项中的行为并不符合暴力或其他方式公然侮辱他人,不成立侮辱罪。因此,A选项错误。B选项:《刑法》第399条第1款规定:“司法工作人员徇私枉法、徇情枉法,对明知是无罪的人而使他受追诉、对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉,或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的,构成徇私枉法罪。”由此可知,法官(司法工作人员)明知被告人系被诬告,仍判决被告人有罪的,构成徇私枉法罪。而本项中的法官既没有诬告陷害的行为,也没有捏造事实的行为,不成立诬告陷害罪。因此,B选项错误。C选项:诬告陷害罪是侵犯公民人身权利的犯罪,单位虽然不存在人身权利,但是对于单位的诬告陷害,很有可能导致单位的负责任的主管人员和直接责任人员受到刑法上的追究,从而侵犯单位负责任的主管人员和直接责任人员的人身权利,从而构成本罪。诬告企业犯逃税罪的,就有可能导致追究企业责任人的刑事责任,能够成立诬告陷害罪。因此,C选项正确。D选项:根据《刑法》第243条第1款的规定,司法机关是否实际追究了被害人的刑事责任并不影响诬告陷害罪的成立,只要诬告行为可能使司法机关采取刑事追究活动即可。故诬告15周岁的人盗窃的,可能使司法机关对其采取刑事追究活动,应以诬告陷害罪定罪处罚。因此,D选项错误。综上所述,本题答案为C。

153、关于侮辱罪与诽谤罪的论述,下列哪一选项是正确的?

A.为寻求刺激在车站扒光妇女衣服,引起他人围观的,触犯强制猥亵、侮辱妇女罪,未触犯侮辱罪

B.为报复妇女,在大街上边打妇女边骂“狐狸精”,情节严重的,应以侮辱罪论

处，不以诽谤罪论处

C.捏造他人强奸妇女的犯罪事实，向公安局和媒体告发，意图使他人受刑事追究，情节严重的，触犯诬告陷害罪，未触犯诽谤罪

D.侮辱罪、诽谤罪属于亲告罪，未经当事人告诉，一律不得追究被告人的刑事责任

【答案】B

【解析】

A 选项：《刑法》第 237 条规定的强制猥亵、侮辱罪，是指以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的行为。“强制猥亵他人”或者“侮辱妇女”即违背妇女意志，侵害他人或者妇女对（广义的）性行为的自己决定权，不以公然实施为前提。故公然强制猥亵他人、侮辱妇女的，可能同时构成侮辱罪与强制猥亵、侮辱罪，属于想象竞合犯，按照重罪强制猥亵、侮辱罪论处。本案中，在车站这个公共场所，公然扒光妇女衣服，对妇女实施侮辱行为的，既触犯强制猥亵、侮辱妇女罪，也触犯侮辱罪。因此，A 选项错误。B 选项：《刑法》第 246 条第 1 款规定的侮辱、诽谤罪，是指以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的行为。诽谤罪中行为人散布的必须是损害他人名誉的虚假事实，而侮辱罪即可以不用具体事实，也可以用真实事实损害他人名誉。但诽谤罪中所散布的事实必须足以使人信以为真的，否则不构成诽谤，可能成立侮辱。例如数落别人长得像猪一样等行为。骂妇女是“狐狸精”的行为，由于未散布损害他人名誉的虚假事实，成立侮辱罪。因此，B 选项正确。C 选项：

根据《刑法》第 243 条第 1 款的规定，捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，构成诬告陷害罪。行为人捏造他人强奸妇女的犯罪事实，向公安局和媒体告发，意图使他人受刑事追究，情节严重的，满足诬告陷害罪的构成要件，成立诬告陷害罪。诽谤罪是指捏造事实诽谤他人或者明知是捏造的事实而进行散布，情节严重的行为。行为人捏造他人强奸妇女的犯罪事实，向公安局和媒体告发，属于捏造损害他人名誉的虚假事实并予以散布的行为，符合诽谤罪构成要件。一行为触犯两个罪名，是想象竞合犯，应以重罪诬告陷害罪处理。因此，C 选项错误。D 选项：《刑法》第 246 条第 2 款规定：

“前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。”侮辱罪、诽谤罪属于告诉才处理的犯罪，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。故“未经当事人告诉，一律不得追究被告人的刑事责任”的表述错误。因此，D 选项错误。综上所述，本题答案为 B。

154、甲为 A 公司股东，乙为 A 公司总经理，二人原本为男女朋友，后因故分手。甲怀恨在心，经自己研究发现，A 公司生产的保健品毫无保健作用。甲抛售股票后紧接着在网上公布该研究结果，并写明乙是 A 公司总经理。该报告导致 A 公司股价狂跌。关于甲的行为，下列哪一说法是正确的？

- A.甲构成破坏生产经营罪
- B.甲构成侵犯公民个人信息罪
- C.甲构成内幕交易罪
- D.不构成犯罪

【答案】D

【解析】

出于泄愤报复或者其他个人目的，毁坏机器设备、残害耕畜或者以其他方法破坏生产经营的，成立破坏生产经营罪。甲的行为是有益于社会的行为，显然不符合本罪的构成要件。A项是错误的。侵犯公民个人信息罪，是指违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重，以及窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的行为。乙在A公司任职的信息，本就是公开信息，故甲将乙在A公司任职的情形在网上予以公布的，不成立本罪。B项是错误的。内幕交易罪是指，证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者明示、暗示他人从事上述交易活动，情节严重的行为。甲是通过自己研究获得A公司保健品没有保健作用的，既不是内幕信息知情人员，也不是通过非法手段获得的内幕信息，故甲的行为不符合本罪的构成要件。C项是错误的。

155、以下不构成侵犯公民个人信息罪的是（假设下列信息都是公民个人信息，且不考虑数量和情节）？

- A.章某窃取某重点大学新生入学信息，但是并没有将信息泄露出去
- B.李某在寄快递时，快递公司要求其写下自己的姓名、家庭住址。信件发出后，快递公司并没有将李某的相关信息删除而是长期保存
- C.小额贷款公司促使借款人还款付息，不仅登记了借款人的信息，而且获取借款人手机里其他全部手机联系人的联系方式等信息
- D.甲银行工作人员将在该银行的储户的相关信息提供给乙银行，其目的在于让乙

银行在向公民个人发放贷款时，了解贷款人是否具有还款能力

【答案】B

【解析】

A 项错误。章某是通过非法手段获取公民个人信息，构成侵犯公民个人信息罪。

B 项正确。快递公司后续并没有将该信息出售或提供他人，仅仅是长期保存，不成立本罪。C 项错误。小额贷款公司登记借款人的信息是经借款人同意后合法收集，但是，小贷公司在提供服务的过程中，违反国家有关规定，收集与提供的服务无关的公民的个人信息，属于非法获取公民个人信息的行为，构成侵犯公民个人信息罪。D 项错误。这种交换行为也属于非法获取行为，构成侵犯公民个人信息罪。实践中，一些房产中介、物业管理公司、保险公司、担保公司的业务员往往与同行通过 QQ 微信群互相交换各自掌握的客户信息，这些都可能触犯本罪。《刑法》第 253 条之一规定：违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，构成侵犯公民个人信息罪。

156、关于侵犯人身权利罪，下列哪些选项是错误的？

A.医生甲征得乙（15 周岁）同意，将其肾脏摘出后移植给乙的叔叔丙。甲的行为不成立故意伤害罪

B.丈夫甲拒绝扶养因吸毒而缺乏生活能力的妻子乙，致乙死亡。因吸毒行为违法，乙的死亡只能由其本人负责，甲的行为不成立遗弃罪

C.乙盗窃甲价值 4000 余元财物，甲向派出所报案被拒后，向县公安局告发乙抢劫价值 4000 余元财物。公安局立案后查明了乙的盗窃事实。对甲的行为不应以诬告陷害罪论处

D.成年妇女甲与 13 周岁男孩乙性交，因性交不属于猥亵行为，甲的行为不成立猥亵儿童罪

【答案】ABD

【解析】

A 选项：《刑法》第 234 条之一规定：“未经本人同意摘取其器官，或者摘取不满十八周岁的人的器官，或者强迫、欺骗他人捐献器官的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。”乙未满 18 周岁，无论甲是否取得乙的同意，甲摘取乙肾脏的行为都构成故意伤害罪。因此，A 选项错误。B 选项：《刑法》第 261 条规定的遗弃罪，是指对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有扶养义务而拒绝扶养，情节恶劣的行为。本案中，甲、乙是夫妻，具有互相扶养的义务，即使乙因吸毒而丧失或缺乏生活能力，甲都具有对乙的扶养义务，但甲拒绝履行扶养义务而致乙死亡，甲的行为构成遗弃罪。因此，B 选项错误。C 选项：根据《刑法》第 243 条第 1 款的规定，捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，构成诬告陷害罪。本罪中的“捏造”是指向司法机关告发不存在的犯罪事实。是指，本案中，甲因乙盗窃自己的财物，去派出所报案时未能立案而向公安局告发乙具有抢劫 4000 元财物行为，乙原本就存在着盗窃 4000 元财物的犯罪事实，甲为使乙受到刑事追究，而夸大了乙的犯罪行为，甲的行为不是捏造事实，故甲的行为不成立诬告陷害罪。因此，C 选项正确。D 选项：《刑法》第 237 条规定的强制猥亵、侮辱罪，是指以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的行为。猥亵儿童是指猥亵不满 14 周岁的幼男或者幼女。本案中，成年妇女甲与 13 周岁男孩乙性交，甲的行为成立猥亵儿童罪，且从重处罚。因此，D 选项错误。综上所述，本题答

案为 ABD。

157、关于侵犯公民人身权利罪的认定，下列哪些选项是正确的？

- A.甲征得 17 周岁的夏某同意，摘其一个肾脏后卖给他人，所获 3 万元全部交给夏某。甲的行为构成故意伤害罪
- B.乙将自己 1 岁的女儿出卖，获利 6 万元用于赌博。对乙出卖女儿的行为，应以遗弃罪追究刑事责任
- C.丙为索债将吴某绑于地下室。吴某挣脱后，驾车离开途中发生交通事故死亡。丙的行为不属于非法拘禁致人死亡
- D.丁和朋友为寻求刺激，在大街上追逐、拦截两位女生。丁的行为构成强制侮辱罪

【答案】AC

【解析】

A 选项：《刑法》第 234 条规定：“未经本人同意摘取其器官，或者摘取不满十八周岁的人的器官，或者强迫、欺骗他人捐献器官的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚（故意伤害罪、故意杀人罪）。” 本案中，夏某系不满十八周岁的未成年人，即使甲征得夏某同意，摘其一个肾脏后卖给他人，按照刑法规定，甲依然构成故意伤害罪。因此，A 选项正确。B 选项：乙将自己 1 岁的女儿出卖，虽出卖的是其亲生子女，依然触犯拐卖儿童罪。同时，其出卖的行为应被认定为不履行法定抚养义务，触犯遗弃罪。本案情形属于一行为触犯两个犯罪的想象竞合情形，原则上，应择一重罪处罚，拐卖儿童罪的刑罚相较于遗弃罪更重。故应当认定乙触犯拐卖儿童罪。因此，B 选项错误。C 选项：《刑法》238 条规定：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三

年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。”成立非法拘禁罪致人死亡的结果加重犯的前提条件是，拘禁行为与死亡结果具有刑法上的因果关系。本案中，死亡结果并非拘禁行为导致的，而是因交通事故死亡，故其死亡结果与拘禁行为没有刑法上的因果关系，故丙的行为不属于非法拘禁致人死亡的情形。因此，C选项正确。D选项：强制侮辱罪侵犯的法益是一种性的羞耻心。依据常识判断，丁和朋友为寻求刺激，在大街上追逐、拦截两位女生的行为并未侵犯两位女生的性羞耻心，故丁的行为不构成强制侮辱罪，可能构成寻衅滋事罪。因此，D选项错误。综上所述，本题答案为AC。

158、甲在乙骑摩托车必经的偏僻路段精心设置路障，欲让乙摔死。丙得知甲的杀人计划后，诱骗仇人丁骑车经过该路段，丁果真摔死。关于本案，下列哪些选项是正确的？

- A.甲的行为和丁死亡之间有因果关系，甲有罪
- B.甲的行为属对象错误，构成故意杀人罪既遂
- C.丙对自己的行为无认识错误，构成故意杀人罪既遂
- D.丙利用甲的行为造成丁死亡，可能成立间接正犯

【答案】ACD

【解析】

对象错误和打击错误如何区分的问题：首先要看对实害对象和实害结果持何种心

理？如果是过失(或意外事件)，则是打击错误；如果是故意（包括间接故意），则应当看行为时对实害对象的身份有无认识错误，有是对象错误，无则是没有任何事实认识错误。本题中，甲在设置公共道路障碍，想摔死骑摩托车的乙，此时甲一定会认识到，在公共道路设置障碍很有可能将其他骑手摔死，即使是偏僻路段，也会有这种认识，这表明甲对其他路人的死亡持放任的态度，这是一种间接故意。结果路人丁骑车摔死，这种死亡，在甲的间接故意的认识范围内，由于甲对实害对象及结果不是持过失心理，因此排除了甲构成打击错误的可能。其次，判断行为人在实施行为时，对施害对象的身份有无认识错误，甲在设置路障，对实害对象丁，欲害对象乙的身份并没有搞混，并没有认识错误，没有误将丁当做乙的心理活动，因此甲不构成对象错误，甲没有任何事实认识错误，由于甲对施害对象，丁的死亡持间接故意，因此甲构成故意杀人罪既遂。旧理论在此的判断路线是，第一步以结果发生时为标准，判断行为人对实害对象的身份有无认识错误，以此判断，从结果发生时看，假以为死者是乙实际是丁，因此属于对象错误，此种看法不仅违背了行为与故意同时存在原则，而且导致打击错误，均变成对象错误。丙的间接正犯问题：间接正犯的成立，条件是对实行者具有支配力，一个人对他人能形成支配力，主要源于两种情形，一是强制手段，典型情形是强迫被害人实施自损行为，二是欺骗手段，典型情形是欺骗被害人，实施自损行为，本题中丙的确利用了甲的行为，但是应注意丙能够成为间接正犯，要形成支配力，但是丙对甲并未形成支配力，因为丙欺骗被害人丁时，甲的行为已经实施完毕，丙对甲的行为没有支配力。丙能够成为间接正犯，是因为利用了被害人丁的不知情欺骗丁自陷死亡之地，并通过这种欺骗对被害人丁形成支配力，构成故意杀人罪的间接正犯。司法部公布的答案认为，D选项结论正确，这种说法没问题，因

为丙的确利用了甲的行为,但是要明白这里的利用是普通的利用,不是指间接正犯能够形成支配力的利用,此外,A项认为甲的行为和丁死亡之间具有因果关系,甲有罪,这种说法正确。C项认为丙没有认识错误,并且构成故意杀人罪既遂,这种说法正确。综上所述,本题答案为ACD。

159、甲为要回30万元赌债,将乙扣押,但2天后乙仍无还款意思。甲等5人将乙押到一处山崖上,对乙说:“3天内让你家人送钱来,如今天不答应,就摔死你。”乙勉强说只有能力还5万元。甲刚说完“一分都不能少”,乙便跳崖。众人慌忙下山找乙,发现乙已坠亡。关于甲的行为定性,下列哪些选项是错误的?

- A.属于绑架致使被绑架人死亡
- B.属于抢劫致人死亡
- C.属于不作为的故意杀人
- D.成立非法拘禁,但不属于非法拘禁致人死亡

【答案】ABC

【解析】

A选项:刑法238条第3款规定,为索取债务,非法扣押、拘禁他人的,构成非法拘禁罪。同时,根据《关于对为索取法律不予保护的债务非法拘禁他人行为如何定罪问题的解释》,行为人为索取高利贷、赌债等法律不予保护的债务的,非法扣押、拘禁他人的,依照非法拘禁罪定罪处罚,即238条规定的债务包括非法债务,因此,甲的行为并不触犯抢劫罪或者绑架罪。因此,AB选项错误。

C选项:在本案中,当甲说“如今天不答应就摔死你”时,甲仅具有恐吓的意思,实际上并没有杀害乙的意思,乙跳崖的行为系异常的介入因素,这一因素已经阻断了先前的因果关系,即甲的先前行为在此时已经与乙的死亡结果没有刑法上的

因果关系。同时，当乙跳崖后，众人还慌忙下山找乙，这也表明甲当时并没有杀人的故意。综上，甲未触犯不作为的故意杀人罪。因此，C 选项错误。D 选项：依据刑法理论，非法拘禁致人重伤、死亡要求非法拘禁行为与被害人重伤、死亡存在因果关系即是非法拘禁行为本身致使被害人重伤、死亡的。若在行为人实施了行为之后，被害人因自身原因致使其死亡、重伤的，属于异常介入因素，其效果是阻断了先前的因果关系，故不能认定为结果加重犯。在本案中，乙跳崖的行为系异常的因素，其阻断先前非法拘禁行为与死亡之间的因果关系。故甲不需要承担乙死亡的刑事责任。因此，D 选项正确。综上所述，本题答案为 ABC。

160、下列哪些行为构成侵犯公民个人信息罪(不考虑情节)?

- A.甲长期用高倍望远镜偷窥邻居的日常生活
- B.乙将单位数据库中病人的姓名、血型、DNA 等资料，卖给某生物制药公司
- C.丙将捡到的几本通讯簿在网上卖给他人，通讯簿被他人用于电信诈骗犯罪
- D.丁将收藏的多封 50 年代的信封(上有收件人姓名、单位或住址等信息)高价转让给他人

【答案】BC

【解析】

《刑法》253 条之一：“违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。”。侵犯公民个人信息罪中的“公民个人信息”，是指以电子或者其

他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。A 选项：在本案中，虽然甲偷窥邻居的日常生活，但按照刑法理论，日常生活非系刑法意义上的“公民个人信息”，故甲未触犯侵犯公民个人信息罪。因此，A 选项错误。B 选项：依据刑法分则的规定，“基于业务原因而获取的病人姓名、血型、DNA 等资料，”系刑法意义上的“公民个人信息”；在本案中，乙将其非法卖给他人的行为触犯了侵犯公民个人信息罪。因此，B 选项正确。C 选项：依照刑法分则的规定，“通讯簿上记载有他人的联系方式，”系刑法上的“公民个人信息”；行为人将其非法卖给他人，同时该信息被用于犯罪的，触犯侵犯公民个人信息罪。因此，C 选项正确。D 选项：虽然 50 年代的信封中存在收件人姓名、单位或者住址等信息，但是，年代久远，信封上的个人信息情况很难危及到相关人员的人身和财产安全。故丁的行为不构成侵犯公民个人信息罪。因此，D 选项错误。综上所述，本题答案为 BC。

161、甲与乙（女）2012 年开始同居，生有一子丙。甲、乙虽未办理结婚登记，但以夫妻名义自居，周围群众公认二人是夫妻。对甲的行为，下列哪些分析是正确的？

- A.甲长期虐待乙的，构成虐待罪
- B.甲伤害丙（致丙轻伤）时，乙不阻止的，乙构成不作为的故意伤害罪
- C.甲如与丁（女）领取结婚证后，不再与乙同居，也不抚养丙的，可能构成遗弃罪
- D.甲如与丁领取结婚证后，不再与乙同居，某日采用暴力强行与乙性交的，构成强奸罪

【答案】ABCD**【解析】**

A 选项：刑法 260 条规定，虐待家庭成员，情节恶劣的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。虐待罪的对象必须是家庭成员。事实婚姻中的夫妻双方也属于虐待罪中的家庭成员。这里需要对家庭成员做扩大解释。在本案中，甲乙未办理法定的结婚登记，但长期以夫妻名义同居，系事实婚姻，甲长期虐待乙的行为触犯虐待罪。因此，A 选项正确。B 选项：甲伤害其子丙致使其轻伤的行为触犯故意伤害罪，此时乙具有救助的义务而不阻止的，触犯不作为方式的故意伤害罪。因此，B 选项正确。C 选项：刑法 261 条规定，对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有扶养义务而拒绝扶养，情节恶劣的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。丙系没有独立生活能力的未成年人，若甲与丁结婚，不再与乙同居的，也有抚养其子丙的法定义务，若甲不抚养丙的，则触犯遗弃罪。因此，C 选项正确。D 选项：强奸罪规定在刑法的 236 条，是指以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的行为，其侵犯的法益是妇女（包括幼女）的性的自主决定权。在本案中，甲如与丁领取结婚证后，不再与乙同居，表明事实婚姻已经不存在。此时甲采用暴力强行与乙性交的行为，满足强奸罪的构成要件，触犯强奸罪。因此，D 选项正确。综上所述，本题答案为 ABCD。

162、下列关于侮辱、诽谤行为，下列选项正确的是？

A.甲冲入李某家中，当着其父母的面将垃圾倒李某脸上，并将侮辱李某的漫画贴在其家中。甲不构成侮辱罪

B.乙以张某为原型创作小说，该小说主人公极其卑鄙，枪杀了二十多名警察，强奸了多名网红女主播并被通缉，后被枪决。尽管读者难以将主人公与张某对号入

座，乙仍构成侮辱罪

C.丙为报复同事陈某，编其虐待前妻和多次离婚的谣言。丙构成诽谤罪和诬告陷害罪的想象竞合

D.丁对某品牌的奶商不满，编造在该品牌的牛奶中喝出苍蝇的谣言，导致该奶商损失巨大。丁构成损害商品声誉罪

【答案】ABD

【解析】

A 选项正确。侮辱行为必须公然进行，例如，在住宅内向一家四口侮辱他人的，一般不具有公然性。需要说明的是，刑法规定侮辱罪是为了保护被害人的名誉、荣誉，而名誉、荣誉是具有“外向性”的特殊法益，即社会、他人对被害人的评价。从这一意义上看，侮辱必须以公然的方式进行。B 选项正确。以文字方式，创作有损他人名誉的小说的，属于侮辱行为，构成侮辱罪。C 选项错误。甲只构成诽谤罪，不符合诬告陷害罪的构成要件。D 选项正确。《刑法》第 221 条规定了损害商业信誉、商品声誉罪，是指行为人捏造并散布虚伪事实，损害他人的商业信誉、商品声誉，给他人造成重大损失或者有其他严重情节的行为。本题中，丁故意捏造奶中喝出苍蝇的虚伪事实，导致奶商损失重大的，丁的行为成立损害商品声誉罪。

163、关于拐卖妇女罪,下列说法正确的有?

A.甲欲拐卖妇女,将妇女控制后,没有找到卖家,构成拐卖妇女罪的未遂

B.乙欲拐卖妇女,将妇女控制后,没有找到卖家,便与妇女以夫妻名义共同生活,仍构成拐卖妇女罪

C.丙收买被拐卖的妇女后,将其关押,剥夺其人身自由,后又想卖掉,并将其卖掉,仅

以拐卖妇女罪论处即可

D.成年妇女王某欲离开原居住地,向丁谎称自己卖身救母,需要 50 万元。丁支付王某 50 万元,将王某带回家。丁不构成收买被拐卖的妇女罪

【答案】BCD

【解析】

A.B 项,采取控制、绑架方式实施拐卖妇女罪,既遂标准是将妇女拐到手,也即控制到手。本题中甲、乙均将妇女控制到手,就构成拐卖妇女罪的既遂。既遂之后的情形不影响既遂结论的成立。因此,A 项说法错误,B 项说法正确。C 项,收买罪+拐卖罪=拐卖罪。例如,甲收买了一位被拐卖的妇女,本想与之结婚,但发现越看越丑,便卖掉。对甲只以拐卖妇女罪论处。如果甲收买时,就是以出卖为目的,然后卖掉了,此时收买行为不构成收买被拐卖妇女罪,整体就定一个正常的拐卖妇女罪。

应注意的是,收买罪+新罪+拐卖罪。本题中,新罪是非法拘禁罪。由于非法拘禁罪能够被拐卖罪吸收,因此只定拐卖罪即可。C 项说法正确。D 项,拐卖妇女罪的保护法益是妇女的人身自由。注意:成年妇女如果同意放弃该法益,则行为人不构成拐卖妇女罪,相应的,收买者也不构成收买被拐卖妇女罪。本题中,成年妇女王某同意出卖自己,王某的身份不属于被拐卖的妇女,因此,丁不构成收买被拐卖的妇女罪。D 项说法正确。综上所述,本题答案为 B.C.D。

164、丈夫甲欲与乙离婚,乙不同意,丙建议甲在牛奶里投毒杀害乙,甲听从了丙的建议,把有毒的牛奶拿给乙,乙把牛奶递给儿子丁喝,甲看见后说了一句“儿子已经喝过牛奶了,别给他喝”,乙没有听甲的话,甲看着丁喝下牛奶后转身离去,丁喝下牛奶后呕吐不止,乙马上将丁送往医院,经抢救后脱险,分析本案中正确的有:

- A.丙对儿子属于对象错误，构成故意杀人未遂
- B.丙对乙故意杀人未遂
- C.甲对乙故意杀人未遂
- D.甲对儿子故意杀人未遂

【答案】BCD

【解析】

A 项错误，教唆犯只对与自己的教唆行为具有因果关系的结果承担责任。C 项正确，丙教唆乙下毒杀甲，乙实施了被教唆的犯罪行为，但是由于意志以外的原因使得犯罪未遂，丙是未遂的教唆犯，丙、乙对甲成立故意杀人罪未遂。D 项正确，甲对孩子具有保护义务和危险排除义务，甲没有履行该义务系不作为犯罪，构成不作为的故意杀人罪，甲的不救助义务没有造成被害人死亡结果，应成立不作为犯的故意杀人罪（未遂）。

165、甲绑架了乙,要求乙的妻子丙火速交付 30 万元赎金。丙由于经常被丈夫打骂,觉得这是个除掉丈夫的好机会,便以无钱为由,拒付赎金,也未报警。甲恼羞成怒,杀害了乙。关于本案,下列说法正确的是?

- A.只有承认片面共犯理论,才能认定丙与甲构成共同犯罪
- B.如果不能认定丙与甲构成共同犯罪,就必须认定丙构成故意杀人罪的间接正犯,否则将无法追究其刑事责任
- C.即使认定丙与甲构成共同犯罪,也只能认定二者构成故意杀人罪的共同犯罪
- D.绑架罪属于继续犯,如果认定丙与甲构成共同犯罪,就应按照绑架罪中的“杀害被绑架人”追究丙的刑事责任

【答案】AC

【解析】

A 项,妻子丙负有解救丈夫乙的作为义务,丙故意不解救,构成不作为犯罪。丙构成不作为的帮助犯。第一,丙不给钱,在心理上促进和强化了甲的杀人决意,因此,构成心理性的帮助犯。第二,甲已经有杀人的故意,即使丙给了赎金,不表示甲就不会杀人,依然有可能杀人。所以,丙不是使甲从无到有产生杀人的故意,因此不是教唆犯。片面共同犯罪,是指二人共同制造违法事实,一方有参与意识(知情),另一方没有参与意识(不知情)。本题中,妻子丙故意不给钱,促进了甲的杀人决意。丙知道自己在心理上促进甲杀人,但是甲不知道丙在精神鼓励自己杀人,因此丙构成片面的帮助犯。概言之,丙构成甲的故意杀人罪的心理性帮助犯、不作为的帮助犯、片面的帮助犯。(4)如果不承认片面共犯理论,不承认知情一方可以构成片面的帮助犯,那么就无法认定妻子丙与甲构成共同犯罪,只能各自单独处理。只有承认片面共犯理论,才能认定丙与甲构成共同犯罪。因此,A 项说法正确。B 项,如果不承认片面共犯理论,就只能对妻子丙和甲各自单独处理。如此,丙构成单独的不作为的故意杀人罪(正犯),也即故意不履行解救义务,导致丈夫死亡。但是注意,丙不构成故意杀人罪的间接正犯,因为间接正犯要求“引起+支配”。第一,甲的杀人故意不是丙引起的,甲一开始实施绑架,就有杀人故意,即使丙给钱,甲也可能杀人。第二,丙对甲没有支配力和控制力。B 项说法错误。C 项,即使按照片面共犯理论,认为妻子丙与绑匪甲构成共同犯罪,也只能构成故意杀人罪的共同犯罪,不构成绑架罪的共同犯罪。这是因为,第一,绑架罪的实行行为是实力控制人质,也即非法拘禁行为。妻子丙的意图不是促使甲继续非法拘禁丈夫乙,而是促使甲杀害乙。第二,绑架罪的成立要求行为人具有向第三人勒索财物的目的。而妻子丙就是第三人,丙不可能有向自己勒索财物的目的。因此,C 项说法正确。D 项,《刑法》第 239 条

第2款规定:犯绑架罪,杀害被绑架人的,定绑架罪,处无期徒刑或者死刑。这便是结合犯:绑架罪+故意杀人罪=绑架罪(加重处罚)。绑匪甲符合:绑架罪+故意杀人罪=绑架罪(加重处罚)。但是,妻子丙不属于:绑架罪+故意杀人罪=绑架罪(加重处罚)。这是因为,丙与甲只构成故意杀人罪的共同犯罪,丙不构成绑架罪。而适用上述结合犯的规定,前提是丙构成绑架罪。因此,D项说法错误。综上所述,本题答案为A.C。

166、国有A公司总经理甲发现A公司将从B公司购进的货物转手卖给某公司时,A公司即可赚取300万元。甲便让其妻乙注册成立C公司,并利用其特殊身份,让B公司与A公司解除合同后,再将货物卖给C公司。C公司由此获得300万元利润。关于甲的行为定性,下列哪一选项是正确的?

- A.贪污罪
- B.为亲友非法牟利罪
- C.诈骗罪
- D.非法经营同类营业罪

【答案】A

【解析】

A选项:《刑法》第382条规定的贪污罪是指“国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员,利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的,以贪污论。与前两款所列人员勾结,伙同贪污的,以共犯论处。”贪污罪中“利用职务上的便利”,是指利用职务上主管、管理、经营、经手财物的权力及方便条件。“侵

吞”是指即侵占，是指将自己因为职务而占有、管理的公共财物据为己有或者使第三者所有。本案中，甲通过自己国有 A 公司总经理的身份得知了公司的运作方式，并利用其特殊身份，让原本与 A 公司合作的 B 公司与 A 公司解约后与自己授意妻子所成立的 C 公司合作，从而让自己的 C 公司获取原本属于 A 公司的利润 300 万元。甲属于利用职务上的便利变相侵吞原本属于 A 公司的利润。该行为符合贪污罪的构成要件，成立贪污罪。因此，A 选项正确。B 选项：《刑法》第 166 条规定的为亲友非法牟利罪，是指国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，有下列情形之一，使国家利益遭受重大损失的：（一）将本单位的盈利业务交由自己的亲友进行经营的；（二）以明显高于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位采购商品或者以明显低于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位销售商品的；（三）向自己的亲友经营管理的单位采购不合格商品的。本案中，甲利用自己是国有公司 A 的总经理的职务便利，将本该属于 A 公司的 300 万元利润，交由自己的妻子设立的 C 公司赚取，甲的行为符合“将本单位的盈利业务交由自己的亲友进行经营”的情形，构成为亲友非法牟利罪。但甲的行为同时构成贪污罪，故甲成立贪污罪与为亲友非法牟利罪的想象竞合犯，应择重罪贪污罪论处。因此，B 选项错误。C 选项：《刑法》第 266 条规定的诈骗罪是指以非法占有为目的，诈骗公私财物数额较大的行为。本案中，甲未实施符合诈骗罪的行为，也没有让任何人因陷入错误认识而做出财产处分行为，故不成立诈骗罪。因此，C 选项错误。D 选项：《刑法》第 165 条规定的非法经营同类营业罪，是指国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额巨大的行为。本案中，甲利用职务上的便利将本该属于 A 公司的利润，直接转移到自己授意妻

子成立的 C 公司中，属于贪污行为，而非法经营同类营业罪是不存在直接转移资产，而是通过将商业机会让渡给自己或他人经营的企业，从而使企业获利的行为。故甲成立贪污罪，不成立非法经营同类营业罪。因此，D 选项错误。综上所述，本题答案为 A。

167、朱某系某县民政局副局长，率县福利企业年检小组到同学黄某任厂长的电气厂年检时，明知该厂的材料有虚假、残疾员工未达法定人数，但朱某以该材料为准，使其顺利通过年检。为此，电气厂享受了不应享受的退税优惠政策，获取退税 300 万元。黄某动用关系，帮朱某升任民政局局长。检察院在调查朱某时发现，朱某有 100 万元财产明显超过合法收入，但其拒绝说明来源。在审查起诉阶段，朱某交代 100 万元系在澳门赌场所赢，经查证属实。关于朱某 100 万元财产的来源，下列分析正确的是：

- A.其财产、支出明显超过合法收入，这是巨额财产来源不明罪的实行行为
- B.在审查起诉阶段已说明 100 万元的来源，故不能以巨额财产来源不明罪提起公诉
- C.在澳门赌博，数额特别巨大，构成赌博罪
- D.作为国家工作人员，在澳门赌博，应依属人管辖原则追究其赌博的刑事责任

【答案】B

【解析】

A 项错误。巨额财产来源不明罪是指国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大，不能说明来源的行为。财产、支出明显超过合法收入并不是本罪的实行行为，只是本罪的前提条件。B 项正确。巨额财产来源不明罪以行为人不能说明财产来源为要件，如果在审查起诉阶段说明了来源，并且查证属实，当然

不能再以本罪提起公诉。C项错误。根据《刑法》第6条第1款的规定，“凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。”该款中的“法律有特别规定的情况”就包括在港澳台犯罪的情况，在港澳台犯罪的，不适用中华人民共和国刑法典，而是适用当地的区域刑法。而在澳门赌博，根据澳门当地刑法，不是犯罪。D项错误。根据《刑法》第7条的规定，属人管辖是专门针对中国公民在中国“领域外”犯罪的情况的，澳门属于中国的一个特别行政区，属于中国的领域，而不是中国的领域外，所以对朱某在澳门赌博的行为不可能适用属人管辖追究刑事责任。

168、国有甲公司领导王某与私企乙公司签订采购合同，以10万元的价格向乙公司采购一批设备。后王某发现，丙公司销售的相同设备仅为6万元。王某虽有权取消合同，但却与乙公司老总刘某商议，由王某花6万元从丙公司购置设备交给乙公司，再由乙公司以10万元的价格卖给甲公司。经王某签字批准，甲公司将10万元货款支付给乙公司后，刘某再将10万元返给王某。刘某为方便以后参与甲公司采购业务，完全照办。关于本案的分析，下列哪一选项是正确的？

- A.王某利用职务上的便利套取公款，构成贪污罪，贪污数额为10万元
- B.王某利用与乙公司签订合同的机会谋取私利，应以职务侵占罪论处
- C.刘某为谋取不正当利益，事后将货款交给王某，刘某行为构成贪污罪
- D.刘某协助王某骗取公款，但因其并非国家工作人员，故构成诈骗罪

【答案】C

【解析】

A选项：国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。非国家工作人员帮助国家工作人员贪污的，成立

贪污罪的共犯。本案中，王某作为国有公司的领导，属于国家工作人员，其利用职务上的便利，套取公款的行为，构成贪污罪。王某从丙公司以6万元购买设备的行为，以及将其交给乙公司的行为，属于正常的经营行为，不成立犯罪。国家工作人员王某明知设备价值6万元，仍以10万元的价格向乙公司购买，而且与刘某约定事后将钱返还给王某，王某将其据为己有，属于利用职务之便侵吞公共财物的行为，成立贪污罪。其贪污数额应为4万元，而非10万元，因为甲公司实际获得了设备，该设备价值6万元，王某已经支付了这6万元。因此，A选项错误。B选项：依据刑法271条的规定，公司、企业或者其他单位的非国家工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，成立职务侵占罪。贪污罪和职务侵占罪的最重要的区别在于犯罪主体上的不同，贪污罪的主体是国家工作人员，职务侵占罪的主体是非国家工作人员即公司、企业或者其他单位的非国家工作人员。在本案中，由于王某的身份是国家工作人员，应认定其触犯贪污罪，不能认定为职务侵占罪。因此，B选项错误。C选项：非国家工作人员帮助国家工作人员贪污的，成立贪污罪的共犯。刘某虽然不是国家工作人员，但明知真相，帮助王某实现了贪污行为，成立贪污罪的共犯，而非成立诈骗罪。因此，C选项正确。D选项：根据刑法理论上的共同犯罪原理以及帮助犯的原理，在本案中，刘某虽不是国家工作人员，但其行为对贪污具有帮助作用，即对贪污行为具有辅助性的作用，系贪污罪的帮助犯，触犯贪污罪而不构成诈骗罪。D项错误。综上所述，本题答案为C。

169、根据《刑法》规定，国家工作人员利用本人职权或者（1）形成的便利条件，通过其他（2）职务上的行为，为请托人谋取（3），索取请托人财物或者收受请托人财物的，以（4）论处。这在刑法理论上称为（5）。将下列哪一选项内

容填充到以上相应位置是正确的？

- A. (1) 地位 (2) 国家机关工作人员 (3) 利益 (4) 利用影响力受贿罪 (5) 间接受贿
- B. (1) 职务 (2) 国家工作人员 (3) 利益 (4) 受贿罪 (5) 斡旋受贿
- C. (1) 职务 (2) 国家机关工作人员 (3) 不正当利益 (4) 利用影响力受贿罪 (5) 间接受贿
- D. (1) 地位 (2) 国家工作人员 (3) 不正当利益 (4) 受贿罪 (5) 斡旋受贿

【答案】D

【解析】

根据《刑法》第 388 条规定，国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。这在刑法理论上称为斡旋受贿。所以，答案为 D。

170、国家工作人员甲听到有人敲门，开门后有人扔进一个包就跑。甲发现包内有 20 万元现金，推测是有求于自己职务行为的乙送的。甲打电话问乙时被告知“不要问是谁送的，收下就是了”（事实上是乙安排丙送的），并重复了前几天的请托事项。甲虽不能确定是乙送的，但还是允诺为乙谋取利益。关于本案，下列哪一选项是正确的？

- A. 甲没有主动索取、收受财物，不构成受贿罪
- B. 甲没有受贿的直接故意，间接故意不可能构成受贿罪，故甲不构成受贿罪
- C. 甲允诺为乙谋取利益与收受 20 万元现金之间无因果关系，故不构成受贿罪
- D. 即使认为甲不构成受贿罪，乙与丙也构成行贿罪

【答案】D**【解析】**

A 选项：《刑法》第 385 条第 1 款规定的受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。受贿罪的行为类型不仅包括“索取他人财物”，还包括“非法收受他人财物”等，故甲虽没有主动索取、收受财物，但是被动的收受财物，仍然属于受贿行为，成立受贿罪。因此，A 选项错误。B 选项：刑法总则所阐述的故意犯罪，其故意既包含直接故意，也包含间接故意。刑法分则所规定的具体罪名中的故意犯罪同样有可能是直接故意也有可能是间接故意，而受贿罪是刑法分则所规定的具体罪名，那么受贿罪的故意内容也既可能是直接故意，也可能是间接故意。因此，B 选项错误。C 选项：《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第 13 条规定：只要国家工作人员明知他人有具体的请托事项的，就可以认定为“为他人谋取利益”。甲明知乙有求于自己职务行为，既收受了财物，又“为他人谋取利益”，已经成立受贿罪。因此，C 选项错误。D 选项：行贿罪与受贿罪属于对向犯，在通常情况下，行贿方和受贿方均成立犯罪，具有共犯关系，但不能成立彼此犯罪的帮助犯或教唆犯，而都属于实行犯。但这并不意味着一方行为成立犯罪时另一方行为也必然成立犯罪，完全存在仅一方的行为成立犯罪的情形。故即使本案中甲不构成受贿罪，乙和丙也成立行贿罪。因此，D 选项正确。综上所述，本题答案为 D。

171、刘某的弟弟犯故意伤害罪，刘某送给财政局局长屈某 50 万元作为“活动经费”，让屈某去找公安局局长王某，让自己的弟弟只受到治安管理处罚。屈某找到王某，王某办成此事，屈某给了王某 20 万元。王某不知刘某给了屈某 50

万元。关于屈某和王某的行为，下列说法正确的是？

- A.屈某、王某构成受贿罪共犯，受贿数额是 50 万元
- B.屈某构成受贿罪，数额是 50 万元；王某构成受贿罪，数额是 20 万元
- C.屈某构成侵占罪，数额是 30 万元，还构成行贿罪；王某构成受贿罪，数额是 20 万元
- D.屈某构成受贿罪，数额是 30 万元，还构成行贿罪；王某构成受贿罪，数额是 20 万元

【答案】B

【解析】

(1) 屈某的行为属于斡旋受贿，以受贿罪论处。斡旋受贿（第 388 条），是指国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。本题中，屈某身为国家工作人员，利用本人的职权形成的便利条件，通过其他国家工作人员王某的职务行为，为请托人刘某谋取不正当利益，收受刘某财物 50 万元，属于斡旋受贿，以受贿罪论处，受贿数额为 50 万元。刘某构成行贿罪。(2) 屈某将 50 万元中的 20 万元送给王某，王某予以接受，为刘某谋取了不正当利益。王某构成受贿罪，数额为 20 万元。对于王某的受贿罪而言，刘某构成行贿罪。由于王某对屈某收受 50 万元的数额并不知情，因此受贿数额不是 50 万元。就王某的受贿罪而言，屈某构成受贿罪的共犯。就刘某的行贿罪而言，屈某将 20 万元送给王某，构成行贿罪的共犯。屈某同时构成斡旋受贿型受贿罪、受贿罪的共犯、行贿罪的共犯，想象竞合，择一重罪论处。(3) 刘某将 50 万元交给屈某作为活动经费，没有明说这 50 万元中多少留给屈某，多少交给

王某，而是由屈某全权处理。这表明，刘某对于行贿给屈某的具体数额、行贿给王某的具体数额，有不超出 50 万元的概括认识和故意。因此，刘某对屈某的行贿罪数额是 50 万元，对王某的行贿罪数额也是 50 万元，不过属于一个行贿行为构成两个行贿罪，想象竞合，择一重罪论处。A 项：屈某和王某构成受贿罪共犯，是指王某构成受贿罪，屈某构成共犯。就此而言，受贿数额是 20 万元。屈某构成斡旋受贿型受贿罪，对此王某不构成共犯。因此对于屈某的受贿金额 50 万元，王某不用负责。A 项说法错误。B 项：屈某的斡旋受贿型受贿罪的金额是 50 万元，王某的受贿罪金额是 20 万元。B 项说法正确。C 项：屈某的斡旋受贿型受贿罪的金额是 30 万元，因此将其中的 30 万元留着自己使用，不构成侵占罪。屈某同时构成刘某的行贿罪的共犯。C 项说法错误。D 项：屈某的斡旋受贿型受贿罪的金额是 50 万元。因此，D 项说法错误。综上所述，本题答案为 B。

172、陈某欲得到某项市政工程，将 100 万元交给刘甲（普通公民），希望其交给管理工程的副市长刘乙（刘甲胞弟），予以说情。刘甲将陈某的请求告诉刘乙，将 100 万元要交给刘乙。刘乙说：“钱你留着，工程我会帮助的”。陈某因此获得工程。关于本案，下列说法正确的是？

- A.刘甲和刘乙构成受贿罪的共同犯罪，陈某构成行贿罪
- B.刘甲构成利用影响力的受贿罪，刘乙构成受贿罪，陈某构成对有影响力的人行贿罪
- C.刘甲构成利用影响力的受贿罪，刘乙不构成受贿罪，陈某构成对有影响力的人行贿罪
- D.刘甲同时构成利用影响力受贿罪和受贿罪的共犯，刘乙构成受贿罪，陈某构成行贿罪

【答案】A**【解析】**

利用影响力受贿罪的行为方式是，行为人（中间人，国家工作人员的近亲属或关系密切人）接受请托人钱财，利用自己的影响力，通过国家工作人员（办事人）职务上的行为，为请托人谋取不正当利益。本案中，陈某希望刘甲将 100 万元交给刘乙，表明陈某没有向刘甲行贿的意思，对刘甲不构成对有影响力的人行贿罪，刘甲也不构成利用影响力受贿罪。陈某只有向刘乙行贿的意思，构成行贿罪，数额为 100 万元。刘甲将 100 万元要交给刘乙，请求刘乙办事，刘乙让刘甲将 100 万元自己留用，为陈某谋取不正当利益，刘乙构成受贿罪，刘甲构成受贿罪共犯。虽然刘乙没有将 100 万元据为己有，但其处分给刘甲，仍表明自己占有控制，构成受贿罪既遂，数额为 100 万元。刘乙构成受贿罪，刘甲是受贿罪的共犯，故 A 项正确。BCD 项的错误在于，刘甲不构成利用影响力受贿罪，陈某也不构成对有影响力的人行贿罪。

173、甲和乙开公司，注册资本 1000 万元。甲乙向国家工作人员丙行贿，送给其 10%的股权并进行登记。之后丙持有的股票的价格涨到了 200 万元。乙又有事相求于丙，以 600 万元回购了丙的股份。丙的受贿金额共计是？

- A.100 万元
- B.200 万元
- C.500 万元
- D.600 万元

【答案】C**【解析】**

司法解释规定，收受干股（未实际出资而获得的股份）的，成立受贿罪。如果进行了股权转让登记，受贿数额以转让行为时股份价值计算。如果未进行股权转让登记，受贿数额以实际股份分红计算。基于此，甲乙送给丙 10%的股份，并进行登记，当时的股份价值是 100 万元。因此，此时丙的受贿金额是 100 万元。此后，丙的股份涨到 200 万，多的 100 万元属于犯罪所得的收益，但不属于犯罪所得的数额。受贿金额是犯罪所得的数额。丙的股份行情价是 200 万元。乙有事相求，以 600 万元购买丙的股份，这属于变相行贿和受贿。受贿金额是 400 万元。丙的受贿金额共计是 500 万元。

174、乙的孙子丙因涉嫌抢劫被刑拘。乙托甲设法使丙脱罪，并承诺事成后付其 10 万元。甲与公安局副局长丁早年认识，但多年未见面。甲托丁对丙作无罪处理，丁不同意，甲便以揭发隐私要挟，丁被迫按甲的要求处理案件。后甲收到乙 10 万元现金。关于本案，下列哪一选项是错误的？

- A.对于“关系密切”应根据利用影响力受贿罪的实质进行解释，不能仅从形式上限定为亲朋好友
- B.根据 A 选项的观点，“关系密切”包括具有制约关系的情形，甲构成利用影响力受贿罪
- C.丁构成徇私枉法罪，甲构成徇私枉法罪的教唆犯
- D.甲的行为同时触犯利用影响力受贿罪与徇私枉法罪，应从一重罪论处

【答案】D

【解析】

利用影响力受贿罪包括两种类型：一是国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，通过该国家工作人员职务上的行

为，或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物，数额较大或者有其他较重情节的行为；二是离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人，利用该离职的国家工作人员原职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物，数额较大或者有其他较重情节的行为。上述“近亲属”的范围容易确定，关键是如何确定有密切关系的人。一般来说，有密切关系的人，是指与国家工作人员或者离职的国家工作人员具有共同利益关系的人，其中的共同利益不仅包括物质利益，而且包括其他方面的利益。例如，情人关系、恋人关系、前妻前夫关系、密切的上下级关系（如国家工作人员的秘书、司机等）、密切的姻亲或血亲关系等。但是，没有必要对“有密切关系的人”作特别限定。因为客观上能够通过国家工作人员职务上的行为，或者利用国家工作人员职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益的人，基本上都是与国家工作人员有密切关系的人。制约关系，也属于密切关系，甲利用对丁的制约关系，通过丁职务的职务便利，为请托人乙谋取不正当利益，收受乙的财物，构成利用影响力受贿罪。所以，故 AB 正确。丁作为司法工作人员，徇私枉法，对明知有罪的人而故意包庇不使他受追诉，构成徇私枉法罪。丁本没有徇私枉法的犯罪故意，甲采取胁迫的方式教唆丁徇私枉法，甲是徇私枉法罪的教唆犯。C 正确。甲构成利用影响力受贿罪、

徇私枉法罪，数行为侵害数法益，应数罪并罚，而非从一重罪。D项错误。需要特别提示的是，《刑法》第399条第4款规定，司法工作人员收受贿赂，又有徇私枉法、民事、行政枉法裁判等行为，并构成本法第385条规定之罪的，依照处罚较重的规定处罚。这是一个特别规定，甲的行为显然不属于此款规定的情形。

175、甲系某国有企业出纳(国家工作人员),乙怂恿甲挪用公款300万元给自己投资,称两个月后归还,并承诺获利平分。甲照办。后乙用300万元中的100万元投资,200万元用于购房。两个月后,乙将300万元归还给甲,甲然后归还给单位。甲乙挪用公款的数额分别是?

- A.甲、乙的数额均是100万元
- B.甲、乙的数额均是300万元
- C.甲的数额是300万元,乙的数额是100万元
- D.甲的数额是100万元,乙的数额是300万元

【答案】A

【解析】

挪用公款罪有三种客观处罚条件:“进行非法活动”;“数额较大,进行营利活动”;“数额较大,超过3个月未还”。由于这三种行为方式都属于客观处罚条件,因此,不以计划用途来认定,而以实际用途来认定。例如,甲为了炒股而挪出公款(数额较大),但因为股市行情不好就一直将公款放着没用,超过3个月未还。对此就认定为挪用公款数额较大,超过3个月未还。本题中,实际用途是,100万元投资。这属于“数额较大,进行营利活动”,就此而言,甲、乙构成挪用公款罪的共同犯罪,数额是100万元。二人对100万元均要负责。200万元用于购房,两个月后归还。

这不构成挪用公款罪。综上所述,本题答案为 A。

176、甲送给国有收费站站长吴某 3 万元, 与其约定: 甲在高速公路另开出口帮货车司机逃费, 吴某想办法让人对此不予查处, 所得由二人分成。后甲组织数十人, 锯断高速公路一侧隔离栏、填平隔离沟 (恢复原状需 3 万元), 形成一条出口。路过的很多货车司机知道经过收费站要收 300 元, 而给甲 100 元即可绕过收费站继续前行。甲以此方式共得款 30 万元, 但骗吴某仅得 20 万元, 并按此数额分成。围绕吴某的行为, 下列论述正确的是:

- A.利用职务上的便利侵吞本应由收费站收取的费用, 成立贪污罪
- B.贪污数额为 30 万元
- C.收取甲 3 万元, 利用职务便利为甲谋利益, 成立受贿罪
- D.贪污罪与受贿罪成立牵连犯, 应从一重罪处断

【答案】AC

【解析】

A.选项:《刑法》第 382 条规定的贪污罪是指“国家工作人员利用职务上的便利, 侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员, 利用职务上的便利, 侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的, 以贪污论。与前两款所列人员勾结, 伙同贪污的, 以共犯论处。” 本案中, 吴某作为国有收费站站长利用职务上的便利侵吞本应由收费站收取的费用, 符合贪污罪的构成要件, 成立贪污罪。甲与吴某勾结, 伙同贪污, 应为贪污罪的共犯。因此, A 选项正确。

B.选项: 过路费属于国家应收账款, 属于公共财产性利益, 共计 90 万元, 吴某、甲、过往司机们构成贪污罪共犯, 吴某和甲分到其中 30 万元, 司机们分到其中

60 万元。本题 B 项认为，吴某只贪污了 30 万元，这和国家应收账款对不上账。60 万元属于国家应收账款，吴某免收国家应收账款，或者将其送人，也属于贪污行为。贪污罪的非法占有目的，既包括非法占有，也包括为第三人占有。吴某免收过往司机的 60 万元，属于让司机非法占有。当年官方答案 B 项说法正确，后来作了修订。因此，B 选项错误。C 选项：《刑法》第 385 条第 1 款规定的受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。本案中，国有收费站站长吴某，利用职务上的便利，非法收受甲 3 万元钱，并为甲谋取利益，成立受贿罪。因此，C 选项正确。D 选项：牵连关系是指行为人实施的数个行为之间具有方法与目的或者原因与结果的内在联系。吴某违法收受甲的财物构成受贿罪；之后利用职务上的便利侵吞本应由收费站收取的费用，构成贪污罪。吴某实施了两个违法行为，应当分别评价，二者之间不具有牵连关系，不属于牵连犯，而应该数罪并罚。因此，D 选项错误。综上所述，本题答案为 AC。

177、某国企公司里，财务室的保险柜须有钥匙和密码共同使用才能打开，会计甲掌管钥匙，出纳乙掌管密码，甲乙均是国家工作人员。下列说法正确的有？

- A.乙捡到甲的钥匙，打开保险柜，取走现金，属于利用职务便利侵吞公共财物
- B.乙骗到甲的钥匙，打开保险柜，取走现金，属于利用职务便利骗取公共财物
- C.甲偷看乙的密码，打开保险柜，取走现金，属于利用职务便利窃取公共财物
- D.甲和乙共谋打开保险柜，取走现金，属于利用职务便利侵吞公共财物

【答案】CD

【解析】

保险柜的财物由甲乙共同保管、共同占有。共同占有的一方，将共同占有的财物

转移为自己占有，属于盗窃行为。例如，甲乙各出资一半，共同购买一台电脑。甲趁乙不在，将电脑变卖。电脑是甲乙共同占有的财物。甲侵犯了乙的占有，构成盗窃罪。A项：乙捡到甲的钥匙，只是侵占了钥匙，属于侵占遗忘物，但不等于侵占了保险柜中的财物。乙用密码和钥匙打开保险柜，取走现金，属于将共同占有的财物转移为自己占有，属于盗窃行为。这个过程中，乙利用甲的钥匙不属于利用职务便利，但是乙利用自己的密码属于利用职务便利，因此属于利用职务便利窃取公共财物。A项说法错误。B项：乙骗到甲的钥匙，只是取得钥匙，不等于取得了保险柜中的财物。乙用密码和钥匙打开保险柜，取走现金，属于将共同占有的财物转移为自己占有，属于盗窃行为。这个过程中，乙利用甲的钥匙不属于利用职务便利，但是乙利用自己的密码属于利用职务便利，因此属于利用职务便利窃取公共财物，构成贪污罪。B项说法错误。C项：甲偷看乙的密码，只是取得密码，不等于取得了保险柜中的财物。甲用密码和钥匙打开保险柜，取走现金，属于将共同占有的财物转移为自己占有，属于盗窃行为。这个过程中，甲利用乙的密码不属于利用职务便利，但是甲利用自己的钥匙属于利用职务便利，因此属于利用职务便利窃取公共财物，构成贪污罪。C项说法正确。D项：甲乙二人共同占有公共财物，二人共同利用钥匙和密码打开保险柜，取走现金，属于将公家所有、自己占有的财物，变成自己所有，属于侵占行为。甲乙利用了自己的钥匙和密码，属于利用职务便利侵吞公共财物，因此构成贪污罪的共同犯罪。D项说法正确。综上所述，本题答案为CD。

178、根据《刑法》与司法解释的规定，国家工作人员挪用公款进行营利活动、数额达到1万元或者挪用公款进行非法活动、数额达到5000元的，以挪用公款罪论处。国家工作人员甲利用职务便利挪用公款1.2万元，将8000元用于购买

股票，4000 元用于赌博，在 1 个月内归还 1.2 万元。关于本案的分析，下列哪些选项是错误的？

- A.对挪用公款的行为，应按用途区分行为的性质与罪数；甲实施了两个挪用行为，对两个行为不能综合评价，甲的行为不成立挪用公款罪
- B.甲虽只实施了一个挪用公款行为，但由于既未达到挪用公款进行营利活动的数额要求，也未达到挪用公款进行非法活动的数额要求，故不构成挪用公款罪
- C.国家工作人员购买股票属于非法活动，故应认定甲属于挪用公款 1.2 万元进行非法活动，甲的行为成立挪用公款罪
- D.可将赌博行为评价为营利活动，认定甲属于挪用公款 1.2 万元进行营利活动，故甲的行为成立挪用公款罪

【答案】ABC

【解析】

挪用公款归个人使用分为三种类型，各种类型的成立条件不完全相同：（1）挪用公款归个人使用，进行赌博、走私等非法活动的，构成挪用公款罪，不受“数额较大”和挪用时间的限制。（2）挪用公款数额较大，归个人进行营利活动的，构成挪用公款罪，不受挪用时间和是否归还的限制。（3）挪用公款归个人使用，数额较大、超过 3 个月未还的，构成挪用公款罪。这是指将公款用于非法活动与营利活动以外的其他活动。对挪用公款罪的三种用途的认定，原则上应根据客观的使用性质予以判断。例如，国家工作人员为了购房而挪出公款，但因为房屋涨价而没有购房，于是将公款用于赌博。对此，应认定为挪用公款进行非法活动。再如，原本打算挪出公款赌博，但因为股市行情好而用于炒股的，应认定为挪用公款进行营利活动。又如，原本打算挪出公款炒股，一旦案发时一直没有利用公款

炒股的，亦认定为挪用公款归个人使用进行其他活动。但是，实践中经常出现这样的现象：行为人多次挪用公款，分别用于非法活动、营利活动与其他活动，但用于某项活动的公款数额未达到该项的定罪标准，或者分别来看，用于各项用途的公款数额都没有达到各项的定罪标准，但挪用公款的总数额达到某项定罪标准。此时，应当如何处理呢？显然，在分则条文规定了几种行为类型的情况下，只有行为符合其中一种或数种行为类型时，才可能认定为犯罪。如果对行为进行评价的结局是并不符合其中的任何一种行为类型，则不可能认定为犯罪。当然，行为是否符合其中一种或数种类型，需要根据法益保护目的与法定构成要件，进行妥当归纳与评价，而不能简单从表面加以判断。比如，挪用公款进行营利活动与非法活动的法益侵害性重于挪用公款进行其他活动的法益侵害性，根据举轻以明重的解释规则，可以将挪用公款进行营利活动与非法活动评价为挪用公款进行其他活动，进而可以将挪用公款进行营利活动与非法活动的数额计入挪用公款进行其他活动的数额。基于同样的道理，挪用公款进行非法活动的法益侵害性重于挪用公款进行营利活动，同时，这两种类型均没有时间要求，故可以将挪用公款进行非法活动评价为挪用公款进行营利活动，将挪用公款进行非法活动的数额计入挪用公款进行营利活动的数额。总之，当用于某项活动的公款数额未达到该项的定罪标准时，可以将重行为的数额计入轻行为的数额，但是，不能将轻行为的数额计入重行为的数额，比如，不能将挪用公款进行营利活动的数额计入挪用公款进行非法活动的数额。本案中，国家工作人员甲利用职务便利挪用公款 1.2 万元，将 8000 元用于购买股票，4000 元用于赌博，在 1 个月内归还 1.2 万元。如上所述，由于可以将挪用公款进行非法活动评价为营利活动，将挪用公款进行非法活动的数额进入营利活动的数额，故可以认为甲挪用公款 1.2 万元进行营利活动，

构成挪用公款罪。A 项中，前半句“对挪用公款的行为，应按用途区分行为的性质与罪数。”的说法是错误的。如上所述，对挪用公款行为的性质（或称之为类型）而言，原则上可以按照实际用途区分，但特殊情况下，可以根据举轻以明重的原则，将某种重行为评价为另一种轻行为。但就挪用公款罪的罪数而言，即使行为人三种类型都符合，也只能认定为挪用公款罪一罪，而不能数罪并罚，故挪用公款的用途原则上可以区分性质，但不能用来区分罪数。后半句“甲实施了两个挪用行为，对两个行为不能综合评价，甲的行为不成立挪用公款罪。”说法同样错误。结合前面的分析，甲虽然实施了两个挪用行为，但可以对两个行为进行综合评价，可以将甲挪用公款进行非法活动评价为进行营利活动，进而可以认为甲挪用公款 1.2 万元进行营利活动，认定甲构成挪用公款罪。所以，A 项错误。基于同样的理由，B 项错误，D 项正确。购买股票属于营利活动，不属于非法活动，由于营利活动的法益侵犯性轻于非法活动，故不能将挪用公款进行营利活动的数额计入非法活动的数额，对甲不能认定为挪用公款 1.2 万元进行非法活动。所以，C 项错误。

179、关于受贿相关犯罪的认定，下列哪些选项是正确的？

- A.甲知道城建局长张某吸毒，以提供海洛因为条件请其关照工程招标，张某同意。甲中标后，送给张某 50 克海洛因。张某构成受贿罪
- B.乙系人社局副局长，乙父让乙将不符合社保条件的几名亲戚纳入社保范围后，收受亲戚送来的 3 万元。乙父构成利用影响力受贿罪
- C.国企退休厂长王某（正处级）利用其影响，让现任厂长帮忙，在本厂推销保险产品后，王某收受保险公司 3 万元。王某不构成受贿罪
- D.法院院长告知某企业经理赵某“如给法院捐赠 500 万元办公经费，你们那个

案件可以胜诉”。该企业胜诉后，给法院单位账户打入 500 万元。应认定法院构成单位受贿罪

【答案】ABCD

【解析】

A 项考查受贿罪。受贿罪是指国家工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物为他人谋取利益的行为。其中，受贿的对象是财物，包括财产性利益。财物既包括合法财物，也包括非法财物，赃款、赃物、违禁品也能够成为受贿的对象。张某身为国家工作人员（城建局长），利用职务之便，为他人谋取利益，收受请托人毒品，构成受贿罪。A 项正确。BC 项考查利用影响力受贿罪。利用影响力受贿罪包括两种类型：一是国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，通过该国家工作人员职务上的行为，或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物，数额较大或者有其他较重情节的行为；二是离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人，利用该离职的国家工作人员原职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物，数额较大或者有其他较重情节的行为。B 项，乙父利用国家工作人员乙的影响力，为请托人（几名亲戚）谋取不正当利益，收受请托人财物，构成利用影响力受贿罪。B 正确。C 项，王某作为离职的国家工作人员，利用其原职权形成的便利条件，通过其他国家工作人员（现任厂长）职务上的行为，为保险公司谋取不正当利益，收受保险公司财物 3 万元，构成利用影响力受贿罪，不构成受贿罪。C 项正确。D 项考查单位受贿罪。单位受贿罪是指

国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，情节严重的行为。法院院长代表法院向赵某索要财物，为赵某所在企业谋取利益，使赵某所在企业胜诉，符合单位受贿罪的构成要件，构成单位受贿罪。D项正确。综上，本题答案为ABCD。

180、关于贿赂犯罪的认定，下列哪些选项是正确的？

- A.甲是公立高校普通任课教师，在学校委派其招生时，利用职务便利收受考生家长10万元。甲成立受贿罪
- B.乙是国有医院副院长，收受医药代表10万元，承诺为病人开处方时多开相关药品。乙成立非国家工作人员受贿罪
- C.丙是村委会主任，在村集体企业招投标过程中，利用职务收受他人财物10万元，为其谋利。丙成立非国家工作人员受贿罪
- D.丁为国有公司临时工，与本公司办理采购业务的副总经理相勾结，收受10万元回扣归二人所有。丁构成受贿罪

【答案】ABCD

【解析】

A选项：甲虽是普通任课教师，但其接受学校委派承担招生工作的职务行为系国家公务行为，故应认定甲此时的身份系国家工作人员，此时甲利用职务之便收受他人财物的，触犯受贿罪。因此，A选项正确。B选项：刑法163条：“公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。”乙的身份虽是国有医院的副院长，但是他的开处方行为是正常的医疗行为，非公务行为，因此乙在开药这一

问题上不能认定其为国家工作人员，不构成受贿罪。其为单位的工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物为他人谋取利益，构成非国家工作人员受贿罪。因此，B选项正确。C选项：村委会是村民自治组织，村委会主任不是国家工作人员，丙从事村集体企业招投标的行为非公务行为，因此丙利用职务之便收受他人财物的行为只可能构成非国家工作人员受贿罪。村委会主任只有在协助乡政府从事公务行为的时候才是国家工作人员。因此，C选项正确。D选项：国有公司副总经理，系国家工作人员，其利用职务之便收受他人财物，触犯受贿罪，丁是临时工，非国家工作人员，但其和国有公司副总经理收受贿赂，两者成立受贿罪的共犯。丁是从犯。丁构成受贿罪。因此，D选项正确。综上所述，本题答案为ABCD。

181、关于受贿罪，下列哪些选项是正确的？

- A.国家工作人员明知其近亲属利用自己的职务行为受贿的，构成受贿罪
- B.国家工作人员虚假承诺利用职务之便为他人谋利，收取他人财物的，构成受贿罪
- C.国家机关工作人员实施渎职犯罪并收受贿赂，同时构成渎职罪和受贿罪的，除《刑法》有特别规定外，以渎职罪和受贿罪数罪并罚
- D.国家工作人员明知他人有请托事项而收受其财物，视为具备“为他人谋取利益”的构成要件，是否已实际为他人谋取利益，不影响受贿的认定

【答案】ABCD

【解析】

A选项：按照司法解释的规定，在受贿罪的认定中，当与国家工作人员存在特定关系的人索取或收受他人财物后，国家工作人员在知情后未退还或者上交的，应

当认定国家工作人员具有受贿故意，成立受贿罪。在本案中，国家工作人员明知其近亲属利用自己的职务行为受贿的，系国家工作人员知情，该种情形该国家工作人员和与其存在特殊关系的人成立受贿罪，系共犯，因此，A 选项正确。B 选项：刑法 388 条规定，受贿罪是指国家工作人员利用职务的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为，成立。刑法理论认为“为他人谋取利益”指承诺为他人谋取利益，该承诺包括明示与暗示这两种方式，同时还包括真实与虚假这两种方式。因此，B 选项正确。C 选项：受贿罪中“为他人谋取利益”仅要求承诺为他人谋取利益即可，故国家工作人员收受他人财物后为他人谋取利益的行为构成其他犯罪的，除了《刑法》第 399 条第 4 款规定的以外，都应当数罪并罚。《刑法》第 399 条第 4 款规定，司法工作人员收受贿赂，又有【徇私枉法罪】【民事、行政枉法裁判罪】【执行判决、裁定失职罪】【执行判决、裁定滥用职权罪】的，依法择一重罪处罚，不数罪并罚。因此，C 选项正确。D 选项：《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》规定，为他人谋取利益包括承诺、实施和实现三个阶段的行为。只要具有其中一个阶段的行为，如国家工作人员收受他人财物时，根据他人提出的具体请托事项，承诺为他人谋取利益的，就具备了为他人谋取利益的要件。明知他人有具体请托事项而收受其财物的，视为承诺为他人谋取利益。故国家工作人员明知他人有请托事项而收受其财物，视为具备“为他人谋取利益”的构成要件，是否已实际为他人谋取利益，不影响受贿的认定。因此，D 选项正确。综上所述，本题答案为 ABCD。

182、国有公司领导王某为私企老板查某谋取不正当利益。后王某得知此事被监察机关调查，便找到监察机关的工作人员陈某，希望帮忙，陈某索要 50 万元。王某找来查某，和陈某一起商量，决定由查某给陈某账户打入 50 万元。陈某找

到负责调查的同事郭某，请求帮忙，郭某拒绝请求。下列说法正确的有？

- A. 陈某构成受贿罪，王某构成受贿罪的共犯
- B. 查某构成行贿罪，王某构成行贿罪的共犯
- C. 王某构成受贿罪的共犯与行贿罪的共犯，想象竞合
- D. 陈某斡旋失败，仍成立受贿罪既遂

【答案】ABCD

【解析】

(1) 查某给陈某送 50 万元，查某构成行贿罪。行贿罪中的“为谋取不正当利益”，既包括为自己谋取不正当利益，也包括为第三人谋取不正当利益。陈某构成斡旋受贿型受贿罪。斡旋受贿（第 388 条），是指国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。斡旋受贿也是权钱交易，请托人花钱买的是斡旋者的斡旋行为，不是办事人的职务行为。成立本罪，要求实施了斡旋行为，但不要求终端办事人答应办事。因此陈某斡旋失败，郭某拒绝请求，不影响陈某的斡旋受贿的成立和既遂。(2) 在查某给陈某行贿和陈某受贿这一过程中，王某起到了促进作用，既构成查某的行贿罪的共犯（帮助犯），也构成陈某的受贿罪的共犯（帮助犯），想象竞合，择一重罪论处，受贿罪的共犯处罚更重，最终选择受贿罪的共犯。综上所述，本题答案为 ABCD。

183、关于贿赂犯罪的认定，下列哪些说法是正确的？

- A. 甲向国家工作人员乙行贿，携带 100 元现金到乙办公室，欲交给乙。乙对甲说：“钱先放你哪儿吧！”甲遂将钱带回，保存于自己的保险箱内，直至案发。甲构成行贿罪既遂，数额是 100 万元。乙构成受贿罪既遂，数额是 100 万元

B.甲向国家工作人员乙行贿，给乙一张空白支票，让乙随意写数字支取，上限为999万元。甲为确保乙能够支取，在自己相应账户上存有数千万元资金。案发时，乙未填写及支取。甲构成行贿罪既遂，数额是999万元。乙构成受贿罪，数额是999万元

C.乙欲经营彩票业务，知道自己不符合条件，找到国家工作人员甲。甲违规审批，授权乙在当地经营彩票业务，并欺骗乙需要交10万元审批费，乙便向甲交了10万元。甲构成受贿罪既遂，数额为10万元

D.甲向乙行贿，送乙一张银行卡，告知乙卡内有500万元。乙收下，未查看也未使用。至案发时，卡内本息共600万元。甲构成行贿罪既遂，数额为500万元。乙构成受贿罪既遂，数额为600万元

【答案】ABC

【解析】

A项，受贿罪的既遂标准：国家工作人员接受了他人财物，建立了自己的占有。受贿罪的既遂，只要求在事实上建立占有，不要求在民法上取得财物的所有权。乙对甲说：“钱先放你哪儿吧！”这句话的意思是：“我接受了你的钱财，然后你替我保存起来，这样更安全”。因此乙构成受贿罪既遂，甲也构成行贿罪既遂，数额都是100万元。B项，乙接受了支票，即使没有支取现金，也构成受贿罪既遂。关于既遂数额，如果支票有具体数额，就以具体数额来定。如果没有具体数额，但是乙可以支取999万元，那么就以999万元来定。C项，受贿罪的本质是权钱交易，也即将他人的钱财与自己的职务行为形成不正当的对价关系。受贿罪中的索贿，既可以是勒索，也可以是编个“名目”索要钱财。只要请托方知道这笔钱是用来买对方的权（职务行为）即可。因此，甲构成受贿罪，而不构

成诈骗罪。甲的受贿金额是 10 万元。假如,乙符合审批条件,甲欺骗乙:“按照程序,你需要给审批机关缴纳 10 万元审批费”。乙信以为真,以为是给审批机关缴纳费用,将 10 万元给甲,让甲代缴。甲据为己有。甲构成诈骗罪,不构成受贿罪。乙不构成行贿罪,而是诈骗罪的被害人。D 项,乙收下银行卡,即使未使用,也构成受贿罪既遂,既遂数额是卡里的资金数额,也即 500 万元。至于多了 100 万元利息,这属于犯罪所得的收益,不属于犯罪所得本身。受贿罪的既遂数额是指犯罪所得的数额。

184、甲为谋取不正当利益,有求于国家工作人员乙的职务行为。下列选项中,甲构成行贿罪的有?

A.乙既利用职务为甲谋取不正当利益,又利用技术在周末为甲的公司解决技术难题。甲就这两方面,共送给乙 500 万元

B.乙的妻子赵某的公司严重亏损,没有扭亏为盈的可能。甲知道真相仍然向该公司投资 500 万元,不久该公司破产

C.乙不符合申购甲的公司原始股的条件。甲使乙具备条件,乙申购了大量原始股。公司上市后,乙抛售原始股,获利 2000 万元

D.乙因买房向甲借款 500 万元,并约定了利息。2 年后,甲有求于乙的职务行为,不再要求乙还本付息

【答案】ABD

【解析】

A 项,受贿罪是权钱交易。乙利用职务行为,收受甲的财物,构成受贿罪。乙利用自己的技术获得劳动报酬,不构成受贿罪。500 万元中,多少是行贿罪、受贿罪的数额,多少是劳动报酬,需要进一步划分。但是,500 万元中,应至少有 3 万元是职务行

为的不正当报酬。因此,甲构成行贿罪,乙构成受贿罪。因此,A项入选。B项,根据司法解释规定,由请托人出资,“合作”开办公司或者其他“合作”投资的,以受贿罪论处。受贿数额为出资额。本题中,甲明知赵某的公司没有扭亏为盈的可能,仍然投资,实际上是不计回报地为赵某纾困,等于白送500万元。赵某也获得了利益,例如,在破产清算时,由于有甲的出资,赵某的损失会少些。因此,甲属于变相行贿,构成行贿罪,行贿数额就是出资额。乙构成受贿罪,赵某构成受贿罪的共犯。B项入选。C项,行贿、受贿属于权钱交易,官员收受的贿赂只能是财物或财产性利益(债权)。而获取一种资格、条件本身不属于财物或财产性利益(债权)。因此,甲不构成行贿罪,乙也不构成受贿罪。C项不入选。D项,甲不再要求还本付息,表明乙获得了财产性利益,也即为乙免除了债务。因此,甲构成行贿罪,乙构成受贿罪。D项入选。综上所述,本题答案为A.B.D。

185、刘某的丈夫赵某涉嫌职务犯罪被监察机关留置。甲对刘某讲:“你给我50万元,我保证将赵某捞出来,这50万元全部用于打点。”实际上,甲只想用10万元打点关系。刘某给了甲50万元,并称如果赵某出来了,会另有重谢。甲将40万元用于偿还个人债务,10万元给了乙,让乙送给监察机关员丙,丙当场拒收。下列说法正确的有?

- A.甲构成诈骗罪既遂,数额为40万元
- B.甲和乙构成行贿罪未遂,数额为10万元
- C.刘某构成行贿罪既遂,数额为50万元
- D.假如丙收受后立即上交有关机关,则甲乙构成行贿罪既遂

【答案】ABD

【解析】

甲对刘某的 40 万元具有非法占有目的,也即该 40 万元并不想用于打点关系,而是想据为己有,因此甲对刘某的 40 万元构成诈骗罪。A 项说法正确。由于丙当场拒收,因此,甲、乙的行贿罪只能是未遂。未遂的数额应是 10 万元,因为甲只想送给丙 10 万元,而非 50 万元。B 项说法正确。第一,由于刘某将钱是想送给办事官员,而非送给中间人甲,因此刘某对办事官员构成行贿罪,对甲不构成对有影响力的人行贿罪。由于办事官员丙拒收,因此刘某的行贿罪构成未遂。第二,该行贿罪的未遂犯的数额应是 10 万元,而非 50 万元。虽然刘某主观上想行贿 50 万元,但实际上其中 40 万元被甲骗了,实际行贿数额只有 10 万元。刘某遭受了 40 万元的财产损失,属于被害人。因此,C 项说法错误。假如丙收受后立即上交有关机关,则丙不构成受贿罪。但是,甲、乙及刘某便构成行贿罪既遂。因为,行贿罪的既遂标准是,国家工作人员客观上接收(占有)了财物。因此,D 项说法正确。综上所述,本题答案为 A.B.D。

186、王某是某国有公司的领导(国家工作人员)。关于王某利用职务便利的挪用行为,下列说法错误的有?

- A.王某长期将公司的汽车挪作私用,构成挪用公款罪
- B.王某将救灾款转用于装修公司办公大楼,构成挪用公款罪
- C.王某挪用公款 100 万元炒期货,完全亏损。王某深感无力还债,便潜逃外地。王某构成贪污罪
- D.王某向客户企业乙公司(民营公司)的负责人吴某提出,挪用乙公司 100 万元,用于炒期货,承诺一年后归还。一年后,王某向乙公司归还了 100 万元。王某构成挪用公款罪

【答案】ABCD

【解析】

考点：贪污贿赂罪 A 项，挪用公款罪的对象是公款，也即资金，不包括财物。汽车属于财物，因此王某不构成挪用公款罪。A 项说法错误。B 项，挪用公款罪要求将公款归个人使用（挪作私用）。王某将公款用于装修公司办公大楼，不构成挪用公款罪。B 项说法错误。C 项，挪用公款罪与贪污罪的区别在于，前者在行为时没有非法占有目的，后者在行为时有非法占有目的。王某在挪用公款时具有归还意图，只是因为客观原因无法归还，仍构成挪用公款罪。注意：如果王某携带挪用的公款潜逃的，则构成贪污罪，这是因为此时王某对公款具有了非法占有目的。C 项说法错误。D 项，（1）挪用公款罪挪用的对象是本单位的公款。乙公司的 100 万元不属于王某所在单位的公款。王某不构成挪用公款罪。（2）王某也不构成受贿罪。这是因为，根据司法解释规定，以借款为名的受贿罪的认定，需要考虑以下因素：有无归还的意思，出借人是否要求国家工作人员利用职务便利为其谋取利益等。第一，王某有归还意思。第二，题中没有交代乙公司提出谋利要求。第三，题中也没有交代王某承诺为乙公司谋取利益。因此王某不构成受贿罪。有人可能认为，王某构成受贿罪，受贿对象是 100 万元的利息。然而，第一，题中没有交代乙公司提出谋利要求，也没有交代王某承诺为乙公司谋取利益。第二，借款时，支付利息不是必然的，需要双方约定。题中没有交代约定了利息。假如，双方约定了利息，事后乙公司因为有事相求，免除了利息，则王某构成受贿罪。D 项说法错误。综上所述，本题答案为 ABCD。

187、关于收受银行卡而受贿，下列说法正确的有？

- A. 官员甲收到银行卡，卡内有资金，未设密码。甲构成受贿罪既遂
- B. 官员乙收到银行卡，卡内有资金，设有密码，乙不知密码，无法支配卡内资金。

乙构成受贿罪未遂

C.官员丙收到银行卡，卡内有资金，丙知道密码，但卡内资金是定期存款，不是活期存款。丙构成受贿罪未遂

D.官员丁收到银行卡，卡内没有资金。丁构成受贿罪既遂

【答案】AB

【解析】

考点：贪污贿赂罪受贿罪的既遂标准是，接受了他人的财物，对财物建立了自己的占有，也即能够支配该财物。A项，卡内有资金，未设密码，表明甲能够支配卡内资金，因此甲构成受贿罪既遂。A项说法正确。B项，虽然卡内有资金，但是乙不知密码，无法支配卡内资金，表明乙并未实际得到他人财物，不构成受贿罪既遂，而构成未遂。B项说法正确。C项，丙知道密码，便能够支配卡内资金，表明丙得到了他人的财物，构成受贿罪既遂。卡内资金是定期存款，只是表明丙暂时不能实际提取。但是，“这盘肉”已经在丙的“盘子里”，只是暂时不能“下嘴”而已。这种情况不影响既遂的结论。C项说法错误。D项，丁没有实际收到财物，不构成受贿罪既遂，而是未遂。D项说法错误。综上所述，本题答案为AB。

188、甲送给国有收费站站长吴某3万元，与其约定：甲在高速公路另开出口帮货车司机逃费，吴某想办法让人对此不予查处，所得由二人分成。后甲组织数十人，锯断高速公路一侧隔离栏、填平隔离沟（恢复原状需3万元），形成一条出口。路过的很多货车司机知道经过收费站要收300元，而给甲100元即可绕过收费站继续前行。甲以此方式共得款30万元，但骗吴某仅得20万元，并按此数额分成。围绕吴某的行为，下列论述正确的是：

- A.利用职务上的便利侵吞本应由收费站收取的费用，成立贪污罪
- B.贪污数额为 30 万元
- C.收取甲 3 万元，利用职务便利为甲谋利益，成立受贿罪
- D.贪污罪与受贿罪成立牵连犯，应从一重罪处断

【答案】AC

【解析】

A.选项：《刑法》第 382 条规定的贪污罪是指“国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。”本案中，吴某作为国有收费站站长利用职务上的便利侵吞本应由收费站收取的费用，符合贪污罪的构成要件，成立贪污罪。甲与吴某勾结，伙同贪污，应为贪污罪的共犯。因此，A 选项正确。

B.选项：过路费属于国家应收账款，属于公共财产性利益，共计 90 万元，吴某、甲、过往司机们构成贪污罪共犯，吴某和甲分到其中 30 万元，司机们分到其中 60 万元。本题 B 项认为，吴某只贪污了 30 万元，这和国家应收账款对不上账。60 万元属于国家应收账款，吴某免收国家应收账款，或者将其送人，也属于贪污行为。贪污罪的非法占有目的，既包括非法占有，也包括为第三人占有。吴某免收过往司机的 60 万元，属于让司机非法占有。当年官方答案 B 项说法正确，后来作了修订。因此，B 选项错误。

C 选项：《刑法》第 385 条第 1 款规定的受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。本案中，国有收费站站长吴某，利用职务上的便

利，非法收受甲 3 万元钱，并为甲谋取利益，成立受贿罪。因此，C 选项正确。

D 选项：牵连关系是指行为人实施的数个行为之间具有方法与目的或者原因与结果的内在联系。吴某违法收受甲的财物构成受贿罪；之后利用职务上的便利侵吞本应由收费站收取的费用，构成贪污罪。吴某实施了两个违法行为，应当分别评价，二者之间不具有牵连关系，不属于牵连犯，而应该数罪并罚。因此，D 选项错误。综上所述，本题答案为 AC。

189、朱某系某县民政局副局长，率县福利企业年检小组到同学黄某任厂长的电气厂年检时，明知该厂的材料有虚假、残疾员工未达法定人数，但朱某以该材料为准，使其顺利通过年检。为此，电气厂享受了不应享受的退税优惠政策，获取退税 300 万元。黄某动用关系，帮朱某升任民政局局长。检察院在调查朱某时发现，朱某有 100 万元财产明显超过合法收入，但其拒绝说明来源。在审查起诉阶段，朱某交代 100 万元系在澳门赌场所赢，经查证属实。关于朱某 100 万元财产的来源，下列分析正确的是：

- A.其财产、支出明显超过合法收入，这是巨额财产来源不明罪的实行行为
- B.在审查起诉阶段已说明 100 万元的来源，故不能以巨额财产来源不明罪提起公诉
- C.在澳门赌博，数额特别巨大，构成赌博罪
- D.作为国家工作人员，在澳门赌博，应依属人管辖原则追究其赌博的刑事责任

【答案】B

【解析】

A 项错误。巨额财产来源不明罪是指国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大，不能说明来源的行为。财产、支出明显超过合法收入并不是本罪

的实行行为，只是本罪的前提条件。B项正确。巨额财产来源不明罪以行为人不说明财产来源为要件，如果在审查起诉阶段说明了来源，并且查证属实，当然不能再以本罪提起公诉。C项错误。根据《刑法》第6条第1款的规定，“凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。”该款中的“法律有特别规定的情况”就包括在港澳台犯罪的情况，在港澳台犯罪的，不适用中华人民共和国刑法典，而是适用当地的区域刑法。而在澳门赌博，根据澳门当地刑法，不是犯罪。D项错误。根据《刑法》第7条的规定，属人管辖是专门针对中国公民在中国“领域外”犯罪的情况的，澳门属于中国的一个特别行政区，属于中国的领域，而不是中国的领域外，所以对朱某在澳门赌博的行为不可能适用属人管辖追究刑事责任。

190、甲是A公司（国有房地产公司）领导，因私人事务欠蔡某600万元。蔡某让甲还钱，甲提议以A公司在售的商品房偿还债务，蔡某同意。甲遂将公司一套价值600万元的商品房过户给蔡某，并在公司财务账目上记下自己欠公司600万元。三个月后，甲将账作平，至案发时亦未归还欠款。（事实一）A公司有工程项目招标。为让和自己关系好的私营公司老板程某中标，甲刻意安排另外两家公司与程某一起参与竞标。甲让这两家公司和程某分别制作工程预算和标书，但各方约定，若这两家公司中标，就将工程转包给程某。程某最终在A公司预算范围内以最优报价中标。为感谢甲，程某花5000元购买仿制古董赠予甲。甲以为是价值20万元的真品，欣然接受。（事实二）甲曾因公务为A公司垫付各种费用5万元，但由于票据超期，无法报销。为挽回损失，甲指使知情的程某虚构与A公司的劳务合同并虚开发票。甲在合同上加盖公司公章后，找公司财务套取“劳务费”5万元。（事实三）关于事实一的分析，下列选项正确的是：

- A.甲将商品房过户给蔡某的行为构成贪污罪
- B.甲将商品房过户给蔡某的行为构成挪用公款罪
- C.甲虚假平账，不再归还 600 万元，构成贪污罪
- D.甲侵占公司 600 万元，应与挪用公款罪数罪并罚

【答案】C

【解析】

A 选项：《刑法》第 382 条规定的贪污罪是指“国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。”甲虽然将公司一套价值 600 万元的商品房过户给蔡某，但是其在公司财务账目上记下自己欠公司 600 万元。即该房屋可视为由甲购买，且以市值购买，而不是甲利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有该房屋，故甲的行为不构成贪污罪。因此，A 选项错误。B 选项：《刑法》第 384 条规定的挪用公款罪是指“国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的行为。”挪用公款需要存在转移公款的占有和使用公款的行为。甲虽然将公司一套价值 600 万元的商品房过户给蔡某，但是其在公司财务账目上记下自己欠公司 600 万元，甲并不存在直接转移公款和使用公款的行为。故甲丁的行为不构成挪用公款罪。因此，B 选项错误。C 选项：“甲在三个月后，将欠账作平，至案发时亦未归还欠款”的行为说明甲对 600 万元具有非法占有的目的，且其利用职务上

的便利，将该国有财产（600 万元）非法据为己有，符合贪污罪的构成要件，构成贪污罪。因此，C 选项正确。D 选项：虽然挪用公款罪与贪污罪之间并非非此即彼的对立关系，而是包容关系，即构成挪用公款罪也有可能构成贪污罪。但是

“甲利用职务上的便利，将该国有财产据为己有”的行为已经评价为贪污罪，将不再构成挪用公款罪。甲使单位损失了 600 万元的行为只有一个，即甲只存在一个违法行为，亦不能数罪并罚。因此，D 选项错误。综上所述，本题答案为 C。

191、甲是 A 公司（国有房地产公司）领导，因私人事务欠蔡某 600 万元。蔡某让甲还钱，甲提议以 A 公司在售的商品房偿还债务，蔡某同意。甲遂将公司一套价值 600 万元的商品房过户给蔡某，并在公司财务账目上记下自己欠公司 600 万元。三个月后，甲将账作平，至案发时亦未归还欠款。（事实一）A 公司有工程项目招标。为让和自己关系好的私营公司老板程某中标，甲刻意安排另外两家公司与程某一起参与竞标。甲让这两家公司和程某分别制作工程预算和标书，但各方约定，若这两家公司中标，就将工程转包给程某。程某最终在 A 公司预算范围内以最优报价中标。为感谢甲，程某花 5000 元购买仿制古董赠予甲。甲以为是价值 20 万元的真品，欣然接受。（事实二）甲曾因公务为 A 公司垫付各种费用 5 万元，但由于票据超期，无法报销。为挽回损失，甲指使知情的程某虚构与 A 公司的劳务合同并虚开发票。甲在合同上加盖公司公章后，找公司财务套取“劳务费”5 万元。（事实三）关于事实三的分析，下列选项错误的是：

- A.甲以非法手段骗取国有公司的财产，构成诈骗罪
- B.甲具有非法占有公共财物的目的，构成贪污罪
- C.程某协助甲对公司财务人员进行欺骗，构成诈骗罪与贪污罪的想象竞合犯
- D.程某并非国家工作人员，但帮助国家工作人员贪污，构成贪污罪的帮助犯

【答案】ABCD

【解析】

A.B 选项：《刑法》第 266 条规定的诈骗罪是指以非法占有为目的，诈骗公私财物数额较大的行为。本案中的 5 万元钱本身就是甲先行垫付的，虽然其获取的行为违反相应制度，但在主观层面上，甲并没有非法占有为目的。故甲不成立犯罪。因此，A.B 选项错误。C 选项：在本题交代的信息中，程某和甲的行为没有任何法益侵害性，不能认定两者的行为是犯罪行为。因此，C 选项错误。D 选项：按照刑法理论上的共犯从属性原理，既然甲的行为不成立犯罪，那么对其实施帮助行为的程某也不构成犯罪。因此，D 选项错误。综上所述，本题答案为 ABCD。

192、某地政府为村民发放扶贫补贴，由各村村委会主任审核本村申请材料并分发补贴款。某村村委会主任王某、会计刘某以及村民陈某合谋伪造申请材料，企图每人套取 5 万元补贴款。王某任期届满，周某继任村委会主任后，政府才将补贴款拨到村委会。周某在分发补贴款时，发现了王某、刘某和陈某的企图，便只发给三人各 3 万元，将剩余 6 万元据为己有。三人心知肚明，但不敢声张。(事实一)后周某又想私自非法获取土地征收款，欲找县国土局局长张某帮忙，遂送给县工商局局长李某 10 万元，托其找张某说情。李某与张某不熟，送 5 万元给县财政局局长胡某，让胡某找张某。胡某找到张某后，张某碍于情面，违心答应，但并未付诸行动。(事实二)周某为感谢胡某，从村委会账户取款 20 万元购买玉器，并指使会计刘某将账做平。周某将玉器送给胡某时，被胡某拒绝。周某只好将玉器退还商家，将退款 20 万元返还至村委会账户，并让刘某再次平账。(事实三)关于事实一的分析，下列选项正确的是？

A.王某拿到补贴款时已经离任，不能认定其构成贪污罪

- B.刘某参与伪造申请材料，构成贪污罪，贪污数额为 3 万元
- C.陈某虽为普通村民，但参与他人贪污行为，构成贪污罪
- D.周某擅自侵吞补贴款，构成贪污罪，贪污数额为 6 万元

【答案】C

【解析】

A 选项：根据司法解释的规定，协助人民政府从事行政管理工作的村民委员会等基层工作人员，属于国家工作人员。本案中，村委会主任王某、会计刘某协助政府审核申请、发放扶贫补贴款，属于依法从事公务的人员，应认定为国家工作人员。虽然王某在离任时才拿到贪污款，但是贪污的实行行为发生在履行公务活动期间，构成贪污罪既遂。因此，A 选项错误。B 选项：在本案中，王某、刘某、陈某是贪污罪的共同犯罪，故三人应当对共同的贪污数额 15 万元负责，刘某的贪污数额应当认定为 15 万元，而不是 3 万元。因此，B 选项错误。C 选项：《关于〈中华人民共和国刑法〉第九十三条第二款的解释》规定，村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事下列行政管理工作，属于刑法第 93 条第 2 款规定的“其它依照法律从事公务的人员”：（1）救灾、抢险、防洪、优抚、扶贫、移民、救济款物的管理；（2）社会捐助公益事业款物的管理；（3）国有土地的经营和管理；（4）土地征用补偿费用的管理；（5）代征、代缴税款；（6）有关计划生育、户籍、征兵工作；（7）协助人民政府从事的其它行政管理工作。据此，本案中，村委会主任王某、会计刘某属于上述第（1）种情形即：“救灾、抢险、防洪、优抚、扶贫、移民、救济款物的管理”。陈某虽然是普通村民，但是伙同他人贪污的，以贪污罪的共同犯罪处理。因此，C 选项正确。D 选项：依据共犯理论，周某、王某、刘某、陈某系贪污罪的共犯；由于四人均均为贪污的 15 万元

的违法事实发挥了作用，按照一人实行，全体负责的原则，应将贪污 15 万元的违法事实归属于四人，而不能仅将每个人实际获取的贪污数额归属于每个犯罪人。因此，D 选项错误。综上所述，本题答案为 C。

193、村民甲为了多获土地补偿款，找到负责核定土地面积的国家机关工作人员乙，让其核定面积时多写面积，并且送了十万元感谢费给乙。乙答应照办，甲因此多获了四十万的土地补偿款。下列说法正确的是？

- A.甲、乙二人成立贪污罪的共犯，贪污的金额为 40 万元
- B.甲送给乙十万元构成行贿罪
- C.乙收受甲提供的十万元，构成受贿罪
- D.甲送给乙行贿的十万元，不应从其非法所得的 40 万元补偿款中扣除

【答案】BCD

【解析】

贪污罪的成立要求行为人必须利用其职务上主管、管理、经营、经手财物的方便与便利条件，本案中，乙只有负责丈量土地面积的权利，而无主管、管理、经营、经手财物的方便与便利条件，故甲乙二人成立诈骗罪的共同犯罪，而非贪污罪的共同犯罪。A 项错误。为了谋取不正当利益，给予国家人员以财物的，成立行贿罪。本案中，甲为多分征地补偿款，而给国家机关工作人员乙行贿，符合行贿罪的构成要件。B 项正确。国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，成立受贿罪。本案中，国家机关工作人员乙，非法收受甲的财物，为甲谋取不正当利益，符合受贿罪的构成要件。C 项正确。本案中，乙的行贿行为与甲乙二人的共同诈骗行为系两个不同的犯罪行为，犯罪金额应彼此分开计量。故甲给乙行贿的金额为 10 万元，且不应从其非

法所得的 40 万元中扣除。D 项正确。

194、张某为谋取不正当利益，给李某(国家机关工作人员)的妻子钱某 10 万元，后李某知道后，让妻子退还给张某，钱某假装同意，后并未将 10 万元退还给张某，并将 10 万元用于家庭生活。下列说法正确的是？

- A.李某的行为不构成犯罪
- B.李某的行为构成受贿罪
- C.钱某的行为构成受贿罪的共犯
- D.钱某的行为构成利用影响力受贿罪

【答案】A

【解析】

受贿罪的本质在于权钱交易，本案中，李某显然不存在以自己的权利交换利益的行为与想法，故李某的行为不构成犯罪；钱某当然也不成立受贿罪的共同犯罪。A 项正确：BC 项错误。所谓利用影响力受贿罪，是指国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，通过该国家工作人员职务上的行为，或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物，数额较大或者有其他较重情节的，以及离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人，利用该离职的国家工作人员原职权或者地位形成的便利条件实施上述行为的行为。理论上认为，利用影响力受贿罪的法益是国家工作人员职务行为的不可收买性，据此，如果关系人索取或者收受了请托人的财物，但并没有要求国家工作人员为请托人谋取不正当利益；或者虽然要求国家工作人员为请托人谋取不正当利益，但国家工作人员并未承诺的，此时不存在权钱交易的本质，

不成立利用影响力受贿罪，而是涉嫌成立财产类犯罪。据此，D项是错误的。

195、王某想请李某（国家工作人员）帮忙进行非法获利活动。由于不认识李某，王某遂请李某的妻子陈某说情，并交付 10 万元，作为感谢费。陈某对李某提及此事，被李某拒绝，并要求陈某把钱退回。后陈某欺骗李某说钱已退回，实际却全部用于家庭生活支出。下列说法错误的有？

- A.王某构成行贿罪既遂
- B.陈某没有退回 10 万元感谢费.对王某构成侵占罪
- C.由于陈某已经实际收到钱，所以构成受贿罪的片面共犯
- D.李某对陈某的退钱行为没有进行细致监督，所以构成受贿罪

【答案】ABCD

【解析】

请托人将一大笔钱财交给有影响力的人，想让其占有一部分，将另一部分转交给国家支配，想谋取不正当利益。这表明请托人有概括故意，想犯行贿罪与对有影响力的人行贿罪。有影响力的人客观接收了自己的那部分，则请托人对有影响力的人行贿罪便既遂。国家工作人员客观接收了自己那部分，则请托人的行贿罪便既遂。由于请托人只有一个行为，两罪属于想象竞合，择一重罪论处。如果有影响力的人主动接受了钱财，留下自己那部分，给国家工作人员送另一部分时，被拒绝，未送出去，则国家工作人员不构成受贿罪，有影响力的人不构成利用影响力受贿罪（成立该罪，要求国家工作人员许诺办事），其若不给请托人退钱，多数观点认为不构成侵占罪。但是，此时请托人仍构成对有影响力的人行贿罪既遂，并构成行贿罪未遂。本题的情形与上述情形相同。王某构成对有影响力的人行贿罪既遂，构成行贿罪未遂。依据多数观点，陈某对王某不构成侵占罪，因为王某

送出去的钱属于贿赂款，失去了返还请求权。陈某收到钱，如果李某答应办事，则陈某构成利用影响力受贿罪和受贿罪共犯，想象竞合，但是李某拒绝，则陈某不构成利用影响力受贿罪；李某不构成受贿罪，相应的，陈某也不构成受贿罪的共犯。李某构成受贿罪的条件是答应办事。李某不会因为未监督陈某退钱而构成受贿罪，何况，李某没有这种监督义务。

196、某地政府为村民发放扶贫补贴，由各村村委会主任审核本村申请材料并分发补贴款。某村村委会主任王某、会计刘某以及村民陈某合谋伪造申请材料，企图每人套取5万元补贴款。王某任期届满，周某继任村委会主任后，政府才将补贴款拨到村委会。周某在分发补贴款时，发现了王某、刘某和陈某的企图，便只发给三人各3万元，将剩余6万元据为己有。三人心知肚明，但不敢声张。(事实一)后周某又想私自非法获取土地征收款，欲找县国土局局长张某帮忙，遂送给县工商局局长李某10万元，托其找张某说情。李某与张某不熟，送5万元给县财政局局长胡某，让胡某找张某。胡某找到张某后，张某碍于情面，违心答应，但并未付诸行动。(事实二)周某为感谢胡某，从村委会账户取款20万元购买玉器，并指使会计刘某将账做平。周某将玉器送给胡某时，被胡某拒绝。周某只好将玉器退还商家，将退款20万元返还至村委会账户，并让刘某再次平账。(事实三)关于事实二的分析，下列选项正确的是？

- A.周某为达非法目的，向国家工作人员行贿，构成行贿罪
- B.李某请托胡某帮忙，并送给胡某5万元，构成行贿罪
- C.李某未利用自身职务行为为周某谋利，但构成受贿罪既遂
- D.胡某收受李某财物进行斡旋，但未成功，构成受贿罪未遂

【答案】ABC

【解析】

A 选项：刑法 389 条：“为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。” 本案中，周某为谋取不正当利益，想私自非法获取土地征收款，而给予国家工作人员县工商局局长李某 10 万元，触犯行贿罪。因此，A 选项正确。

B 选项：刑法 389 条：“为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。” 本案中，李某以谋取不正当利益为目的，给予国家工作人员县财政局局长胡某 5 万元，满足行贿罪的构成要件触犯了行贿罪。因此，B 选项正确。C

选项：根据《刑法》第 388 条的规定，国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。该种情形理论上称之为斡旋受贿。斡旋受贿国家工作人员利用的不是自身的职务行为，而是利用自己的职权或者地位形成的便利条件。通过其他国家工作人员的职务行为，为请托人谋取不正当利益，从而索取或者收受贿赂。本案中，李某以为周某谋取不正当利益为目的，收受请托人周某 10 万元贿赂，同时，胡某利用其职权和职责形成的影响力和便利条件，找国家工作人员胡某帮助为李某谋取不正当利益，但胡某给虚假承诺的，即使该承诺系虚假的承诺，依然应当认定李某成立斡旋方式的受贿罪既遂。因此，C 选项正确。D 选项：根据《刑法》第 388 条的规定，国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。本案中，身为国家工作人员的胡某为替李某谋取不正当利益而进行斡旋，收受李某财物 5 万元，即使李某尚未实际谋取利益，也应认定为受贿罪既遂，因为受贿罪中“为他人谋取利益”仅要求承诺为他人谋取利益。因此，D 选项错误。综上

所述，本题答案为 ABC。

197、关于生产、销售伪劣商品罪，下列哪些选项是正确的？

A.甲未经批准进口一批药品销售给医院。虽该药品质量合格，甲的行为仍构成销售假药罪

B.甲大量使用禁用农药种植大豆。甲的行为属于“在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料”，构成生产有毒、有害食品罪

C.甲将纯净水掺入到工业酒精中，冒充白酒销售。甲的行为不属于“在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料”，不成立生产、销售有毒、有害食品罪

D.甲利用“地沟油”大量生产“食用油”后销售。因不能查明“地沟油”的具体毒害成分，对甲的行为不能以生产、销售有毒、有害食品罪论处

【答案】B

【解析】

A 错误。2019 年修订后的《药品管理法》第 98 条规定：假药包括，所含成分与国家药品标准规定的成分不符的药品，以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品，变质的药品，所标明的适应症或者功能主治超出规定范围的药品。根据这一规定，假药应限定为内容（效用）上的假药。程序上未经批准的，不属于刑法上的“假药”。故本选项中，质量合格的药品不属于假药，行为人的行为不构成销售假药罪。故根据新修订的《药品管理法》，A 错误。B 正确。《刑法》第 144 条（生产、销售有毒、有害食品罪）规定，在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料，或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的，成立生产、销售有毒、有害食品罪。本案中，甲大量使用禁用农药种植大豆，会使大

豆中含有毒药成分，相当于在生产食品中掺入有毒、有害的非食品原料，构成生产有毒、有害食品罪。C 错误。甲的行为属于“在生产、销售食品中掺入有毒、有害的非食品原料”，成立生产、销售有毒有害食品罪。不能因为是在“工业用酒”中掺入“水”，继而认为“水”是无毒、无害的，否认该行为成立犯罪。对“掺入”应作广义理解，掺入与被掺入之间无非是一个顺序的问题，刑法惩罚生产、销售有毒有害食品罪的本质就在于生产、销售食品中含有“有毒、有害”成分。故甲的行为成立生产、销售有毒有害食品罪。D 错误。不能查明“地沟油”的具体毒害成分，只要能证明该成分是“有毒、有害”的，成立生产、销售有毒、有害食品罪。确定一种物质是否属于有害的非食品原料，不需要查明其具体的毒害成分，只要足以造成严重食物中毒或者其他严重食源性疾患即可。“地沟油”属于不能用于食用的非食品原料，对人体健康的危害不言而喻，甲利用“地沟油”大量生产“食用油”后销售，即使不能查明“地沟油”的具体毒害成分，对甲也应认定为生产、销售有毒、有害食品罪。2012 年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于依法严惩“地沟油”犯罪活动的通知》指出：“对于利用“地沟油”生产“食用油”的，依照《刑法》第 144 条生产有毒、有害食品罪的规定追究刑事责任。”

198、下列哪一犯罪属抽象危险犯？

- A.污染环境罪
- B.投放危险物质罪
- C.破坏电力设备罪
- D.生产、销售假药罪

【答案】D

【解析】

A 选项：危险犯是将对法益侵害的危险作为处罚根据的犯罪。抽象危险犯是危险犯的一种，其以一般社会生活经验为根据，认定行为是否具有发生侵害结果的可能性。《刑法》第 338 条规定的污染环境罪是指：“违反国家规定，排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质，严重污染环境的行为。”该罪是结果犯，以发生严重污染环境的结果为处罚根据。因此，A 选项错误。B 选项：投放危险物质罪是指“投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质危害公共安全的行为。”投放危险物质是否危害公共安全，在司法上应以行为当时的具体情况为根据，认定行为是否具有发生侵害结果的紧迫即危险，该罪是具体的危险犯。因此，B 选项错误。C 选项：《刑法》第 118 条规定的破坏电力设备罪是指：“破坏电力、燃气或者其他易燃易爆设备，危害公共安全，尚未造成严重后果的行为。”破坏电力设备是否危害公共安全，未造成严重后果，应以在司法上以行为当时的具体情况为根据，认定行为是否具有发生侵害结果的紧迫，该罪是具体的危险犯。因此，C 选项错误。D 选项：《刑法》第 141 规定，生产、销售假药的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；致人死亡或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。本条所称假药，是指依照《中华人民共和国药品管理法》的规定属于假药和按假药处理的药品、非药品。由法条可看出，该罪并不要求具体的危害可能性，所以该罪属于抽象危险犯，即只要实施了生产、销售假药的行为，原则上就成立生产、销售假药罪。因此，D 选项正确。综上所述，本题答案为 D。

199、甲系外贸公司总经理，在公司会议上拍板：为物尽其用，将公司以来料加工方式申报进口的原材料剩料在境内销售。该行为未经海关许可，应缴税款 90 万元，公司亦未补缴。关于本案，下列哪一选项是正确的？

- A.虽未经海关许可，但外贸公司擅自销售原材料剩料的行为发生在我国境内，不属于走私行为
- B.外贸公司的销售行为有利于物尽其用，从利益衡量出发，应认定存在超法规的犯罪排除事由
- C.外贸公司采取隐瞒手段不进行纳税申报，逃避缴纳税款数额较大且占应纳税额的 10%以上，构成逃税罪
- D.如海关下达补缴通知后，外贸公司补缴应纳税款，缴纳滞纳金，接受行政处罚，则不再追究外贸公司的刑事责任

【答案】C

【解析】

A 选项：《刑法》第 154 条规定，“未经海关许可并且未补缴应缴税额，擅自将批准进口的来料加工、来件装配、补偿贸易的原材料、零件、制成品、设备等保税货物，在境内销售牟利的，成立走私普通货物、物品罪。”所以外贸公司未经海关许可，擅自销售原材料剩料的行为，属于走私行为，成立走私普通货物、物品罪。因此，A 选项错误。B 选项：“超法规的犯罪排除事由”是指虽无法律规定，但是仍应该排除犯罪的事由。在刑法理论上，被害人承诺、自损行为、自救行为、义务冲突等属于超法规的犯罪排除事由。但“物尽其用”并不属于超法规的犯罪排除事由。，因此，B 选项错误。C 选项：《刑法》第 201 条（逃税罪）规定，纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款

数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。该外贸公司的行为构成逃税罪。因此，C 选项正确。D 选项：刑法第 201 条第 4 款（逃税罪）规定，纳税人经税务机关依法下达追缴通知后，补缴应纳税款，缴纳滞纳金，并且接受行政处罚的，不予追究刑事责任；但是，五年内曾因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚的除外。本案中，上述行为构成逃税罪与走私普通货物、物品罪的竞合。即使补缴税款以后，不追究逃税罪的刑事责任，但不能免除其走私犯罪的刑事责任。因此，D 选项错误。综上所述，本题答案为 C。

200、甲向乙借款 50 万元注册成立 A 公司，乙与甲约定在 A 公司取得营业执照的第二天，乙的 B 公司向 A 公司借款 50 万元。A 公司取得营业执照后，由甲经手将 A 公司 50 万元借给 B 公司。关于甲的行为性质，下列哪一选项是正确的？

- A.虚报注册资本罪
- B.虚假出资罪
- C.抽逃出资罪
- D.无罪

【答案】D

【解析】

虚报注册资本罪是指申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。本题中，甲向乙借款 50 万元注册公司，甲在公司成立时，已经如数缴纳了注册资金，并没有虚报注册资本的行为，不构

成虚报注册资本罪。虚假出资、抽逃出资罪是一个选择罪名，是指公司发起人、股东违反公司法的规定，未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。甲在注册公司时，已经交付了 50 万元，不存在虚假出资行为，不构成虚假出资罪。此外，甲只是将自己成立的 A 公司的 50 万元“借”给了乙的 B 公司，也没有抽逃出资的情形，不构成抽逃出资罪。甲以公司名义将 50 万元借给其他公司的行为，属于单位之间的资金拆借行为，属于行政违法行为，不构成犯罪。D 项正确。

201、关于货币犯罪，下列哪一选项是错误的？

- A.伪造货币罪中的“货币”，包括在国内流通的人民币、在国内可兑换的境外货币，以及正在流通的境外货币
- B.根据《刑法》规定，伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照伪造货币罪从重处罚。据此，行为人伪造美元，并运输他人伪造的欧元的，应按伪造货币罪从重处罚
- C.将低额美元的纸币加工成高额英镑的纸币的，属于伪造货币
- D.对人民币真币加工处理，使 100 元面额变为 50 元面额的，属于变造货币

【答案】B

【解析】

A 选项：伪造货币罪规定于《刑法》的第 170 条，本罪针对的“货币”，包括正在流通的货币（含硬币、普通纪念币、贵金属纪念币），港元、澳门元、新台币以及其他国家及地区的法定货币。因此，A 选项正确。B 选项：出售、购买、运输假币罪规定于《刑法》的第 171 条，“伪造货币并出售或者运输伪造的货

币的”，按照伪造货币罪从重处罚；但这仅限于行为人出售、运输自己伪造的假币的情形，如果行为人不仅伪造货币，而且出售或者运输他人伪造的货币，即伪造的假币与出售、运输的假币不具有同一性时，则应实行数罪并罚。行为人伪造美元，并运输他人伪造的欧元的，该假币不具有同一性，应数罪并罚，故对行为人应按伪造假币罪和运输假币罪数罪并罚。因此，B选项错误。C选项：“伪造”货币的本质在于非法使非属于此种货币的材料取得此种货币的形式，而“变造”货币的本质在于非法使同一种货币材料改变数额、数量。将低额美元的纸币加工成高额英镑的纸币的，属于非法使非属于此种货币的材料取得此种货币的形式，改变了货币的同一性，是伪造货币的行为。因此，C选项正确。D选项：变造货币罪规定于《刑法》的第173条，变造是对真货币的加工行为，故变造的货币与变造前的货币具有同一性。如果加工的程度导致其与真货币丧失同一性，则属于伪造货币。本案中，对人民币真币加工处理，使100元面额变为50元面额的，变造前和变造后的货币具有同一性，属于变造货币。因此，D选项正确。综上所述，本题答案为B。

202、关于破坏社会主义市场经济秩序罪的认定，下列哪一选项是错误的？

- A.采用运输方式将大量假币运到国外的，应以走私假币罪定罪量刑
- B.以暴力、胁迫手段强迫他人借贷，情节严重的，触犯强迫交易罪
- C.未经批准，擅自发行、销售彩票的，应以非法经营罪定罪处罚
- D.为项目筹集资金，向亲戚宣称有高息理财产品，以委托理财方式吸收10名亲戚300万元资金的，构成非法吸收公众存款罪

【答案】D

【解析】

A 选项：《刑法》第 171 条规定的出售、购买、运输假币罪，是指出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的行为。该运输一般是指在国内进行运输，一旦越出国界，应以走私假币罪论处，故采用运输方式将大量假币运到国外的，成立走私假币罪。因此，A 选项正确。B 选项：《刑法》第 226 条规定的强迫交易罪，是指以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的：

（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。根据 2014 年 4 月 17 日最高人民检察院《关于强迫借贷行为适用法律问题的批复》，“以暴力、胁迫手段强迫他人借贷，属于《刑法》第 226 条第 2 款规定的‘强迫他人提供或者接受服务’，情节严重的，以强迫交易罪论处。”因此，B 选项正确。

C 选项：最高法、最高检 2005 年发布的《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第 6 条规定：未经国家批准擅自发行、销售彩票，构成犯罪的，依照刑法第二百二十五条第（四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。故未经批准，擅自发行、销售彩票的，应以非法经营罪定罪处罚。因此，C 选项正确。D

选项：《刑法》第 176 条规定的非法吸收公众存款罪，是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。2010 年 12 月 13 日最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第 1 条规定：“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款是向社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。”即“公众”是指多数人或者不特定人（包括单位），未向社会宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者

变相吸收公众存款。本案中，为项目筹集资金，向亲戚宣称有高息理财产品，以委托理财方式吸收 10 名亲戚 300 万元资金的，由于吸收存款的对象确定，故不满足“公众”的要件，不构成非法吸收公众存款罪。因此，D 选项错误。综上所述，本题答案为 D。

203、下列哪一行为不成立使用假币罪（不考虑数额）？

- A.用假币缴纳罚款
- B.用假币兑换外币
- C.在朋友结婚时，将假币塞进红包送给朋友
- D.与网友见面时，显示假币以证明经济实力

【答案】D

【解析】

使用假币，是将假币作为真币而使用。既可以是以外表合法的方式使用假币，如购买商品、兑换另一货币、存入银行、赠与他人，或者将假币用于交纳罚金或者罚款等，也可以是以非法的方式使用货币，如将假币用于赌博。此外，将假币交付给不知情的他人使用的，以及向自动售货机中投入假币以取得商品的，均成立使用假币罪。本题中，A、B、C 项均属于典型的使用假币的情形，成立使用假币罪。同时需要注意，使用假币一定要将假币置于流通领域，否则不成立使用假币罪。比如将假币作为证明自己信用能力的资本而给他人查看的，为了与对方签订合同，将假币给对方查看，以证明自己有能力和履行合同的，均不是使用假币的行为。D 项，与网友见面时，显示假币以证明经济实力，但并没有将假币置于流通领域，不成立假币使用罪。本题答案选 D。

204、甲、乙为朋友。乙出国前，将自己的借记卡（背面写有密码）交甲保管。

后甲持卡购物，将卡中 1.3 万元用完。乙回国后发现卡里没钱，便问甲是否用过此卡，甲否认。关于甲的行为性质，下列哪一选项是正确的？

- A. 侵占罪
- B. 信用卡诈骗罪
- C. 诈骗罪
- D. 盗窃罪

【答案】B

【解析】

A 选项：《刑法》第 270 条规定的侵占罪是指将代为保管的他人财物非法据为己有，数额较大，拒不退还的行为。侵占罪中有变合法占有为非法占有的行为。乙将自己的借记卡交给甲保管，但并没有将卡中的钱交与甲保管的意思，甲未曾占有过该金钱，故甲不成立侵占罪。因此，A 选项错误。B 选项：《刑法》第 196 条规定了信用卡诈骗罪：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，成立信用卡诈骗罪：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。本案中，甲使用乙的借记卡的行为属于“冒用他人信用卡的行为”，故甲的行为成立信用卡诈骗罪。因此，B 选项正确。C 选项：甲的行为满足诈骗罪的构成要件，但信用卡诈骗罪与诈骗罪之间是特殊法条和普通法条的关系（法条竞合关系），故应适用特殊法条信用卡诈骗罪的规定，甲的行为成立信用卡诈骗罪。因此，C 选项错误。D 选项：《刑法》第 264，265 条规定了盗窃罪，盗窃是违背他人的意志，将他人占有的财物转移为自己或第三者（包括单位）占有。

《刑法》第 196 条第 3 款规定：“盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十

四条（盗窃罪）的规定定罪处罚。”本案中，甲是用密码刷卡购物，甲不存在盗窃行为，也不存在盗窃信用卡并使用的情形，故甲不构成盗窃罪。因此，D选项错误。综上所述，本题答案为B。

205、甲冒充房主王某与乙签订商品房买卖合同，约定将王某的住房以220万元卖给乙，乙首付100万元给甲，待过户后再支付剩余的120万元。办理过户手续时，房管局工作人员识破甲的骗局并报警。根据司法解释，关于甲的刑事责任的认定，下列哪一选项是正确的？

- A.以合同诈骗罪220万元未遂论处，酌情从重处罚
- B.以合同诈骗罪100万元既遂论处，合同诈骗120万元作为未遂情节加以考虑
- C.以合同诈骗罪120万元未遂论处，合同诈骗100万元既遂的情节不再单独处罚
- D.以合同诈骗罪100万元既遂与合同诈骗罪120万元未遂并罚

【答案】B

【解析】

A.C选项：合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺骗手段，骗取对方数额较大财物行为。行为人实际取得的财物是合同诈骗罪的既遂。在本案中，当甲实际获得100万元时，甲成立合同诈骗罪既遂。甲想在过户完成后再获取乙120万元的余款，因被房管局工作人员识破而未能得逞，则应认定为未遂（属于未实行终了的未遂）的情形。因此，A.C选项错误。B选项：2011年4月8日起实施的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定，诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以

诈骗罪既遂处罚。在合同诈骗罪中，案件中的 100 万抑或是 120 万，都系刑法分则规定的诈骗数额特别巨大的情形，在同一量刑幅度，依据上述司法解释，应当认定行为人成立合同诈骗罪 100 万既遂，并将合同诈骗的 120 万认定为未遂情节。因此，B 选项正确。D 选项：由于只有一个诈骗行为，只有同一个罪名（合同诈骗罪既遂与合同诈骗罪未遂），不能数罪并罚。因此 D 选项错误。综上所述，本题答案为 B。

206、国家工作人员王某是国有银行网上银行系统管理员，掌握客户网上银行账号和密码的权限。王某与其朋友李某共谋非法占有储户资金。李某吸引许多人到王某所在银行存款，储户存款时会取得银行配套的 U 盾，内有银行卡信息资料。王某通过自己的权限，在银行网络系统获取了这些 U 盾内的银行卡信息资料，从而复制了 U 盾，通过这些 U 盾在网上将储户账户里的资金转移到李某的银行账户。关于本案，下列说法正确的是？

- A.王某利用职务便利盗取本银行的财产，构成贪污罪
- B.王某吸引多名储户到银行存款，构成集资诈骗罪
- C.王某盗取储户的财产，以盗窃罪论处
- D.王某非法取得储户的财产，以信用卡诈骗罪论处

【答案】D

【解析】

A 项：王某是国有银行网上银行系统管理员，掌握客户网上银行账号和密码的权限，王某通过自己的权限，在银行网络系统获取了这些 U 盾内的银行卡信息资料。就此而言，王某的确利用了职务便利。王某是否构成贪污罪的焦点问题是，行为对象是国有银行的财产还是私人财产？对此涉及到存款的属性问题。存款包

括两层含义：一是存款人对银行享有债权，注意：存款人此时享有的不是所有权；二是存款债权所指向的现金。①存款人占有债权。例如，甲利用技术手段将乙存折里的资金（实际是指存款债权）划到自己存折里，构成盗窃罪，盗窃存款债权。②存款指向的现金由银行占有，存款人没有占有。例如，甲盗窃到乙的银行卡，在ATM机上取走2万元现金。甲盗窃卡的行为本身不构成盗窃罪。甲取走现金的行为构成犯罪，该行为针对乙构成盗窃罪，盗窃对象是乙的存款债权，乙的2万元存款债权丧失了；该行为针对银行构成盗窃罪，盗窃对象是银行2万元现金。甲的一个行为触犯两个罪，想象竞合，择一重罪论处，两个犯罪处罚一样重，定盗窃罪即可。本题中，王某将储户账户里的资金转到自己账户，这里的资金是指储户的存款债权，而不是现实中的现金。因此，行为对象不是银行的财产而是储户的财产（针对银行的存款债权），因此王某不构成贪污罪。B项：根据刑法第192条规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。行为结构是：实施欺骗行为（虚假承诺会有回报），使不特定人产生认识错误，对方基于认识错误而处分财产给行为人，行为人因此取得财产。本题中，王某、李某欺骗储户，使储户将钱存到银行。储户将钱存到银行不等于处分给王某、李某。王某、李某取得储户财产是通过技术手段盗取到的。因此，由于储户没有诈骗罪的第三步“基于认识错误而将财物处分给行为人”，因此，王某、李某不构成诈骗罪及集资诈骗罪。CD项非法获取他人信用卡信息资料，然后非法使用，获取他人财产，按照正常原理，对人使用，定信用卡诈骗罪，对机器使用或不存在对人使用，定盗窃罪。但是，司法解释在此制造特殊规定：窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的，以信用卡诈骗罪论处。这是一种特殊规定。考试应当按照司法解

释来答题（以下将该司法解释简称为 09 年司法解释）。由此可以总结一句话：以非法方式获取他人信用卡信息资料，无论对人还是对机器使用，一律定信用卡诈骗罪。这里有两个要求：一是非法方式获取；二是信用卡的信息资料。本题中，U 盾是银行推出的用于网上银行电子签名和数字认证的工具。使用 U 盾登录个人网上银行之后，如需办理转账、汇款等支付业务，输入 U 盾密码，并经银行系统验证无误，即可完成支付业务。王某通过自己的权限，在银行网络系统盗取了这些 U 盾内的银行卡信息资料，通过网上银行，将储户账户里的资金划到共犯李某账户。按照 09 年司法解释，对王某、李某定信用卡诈骗罪。也即，二人的行为原本属于盗划他人资金，构成盗窃罪，但是应当按照 09 年司法解释，作特殊处理，定信用卡诈骗罪。综上所述，本题答案为 D。

207、乙在某银行领取银行卡及配套的 U 盾，U 盾中有银行卡信息资料。银行大厅经理甲（非国家工作人员）假意指导乙如何使用 U 盾，偷换了乙的 U 盾，并欺骗乙：“只能在一周后使用 U 盾。”乙信以为真。后甲利用乙的 U 盾，在网上将乙银行卡账户内的 3 万元转入自己的银行卡账户。对甲的处理，下列说法正确的是？

- A.盗窃罪
- B.职务侵占罪
- C.诈骗罪
- D.信用卡诈骗罪

【答案】D

【解析】

非法获取他人信用卡信息资料，然后非法使用，获取他人财产，按照正常原理，

对人使用，定信用卡诈骗罪，对机器使用或不存在对人使用，定盗窃罪。但是，司法解释在此制造特殊规定：①窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的，以信用卡诈骗罪论处。这是一种特殊规定。考试应当按照司法解释来答题（以下将该司法解释简称为 09 年司法解释）。由此可以总结一句话：以非法方式获取他人信用卡信息资料，无论对人还是对机器使用，一律定信用卡诈骗罪。这里有两个要求：一是非法方式获取；二是信用卡的信息资料。本题中，U 盾是银行推出的用于网上银行电子签名和数字认证的工具。使用 U 盾登录个人网上银行之后，如需办理转账、汇款等支付业务，输入 U 盾密码，并经银行系统验证无误，即可完成支付业务。甲盗窃了乙的 U 盾，就盗窃了乙的银行卡信息资料，通过网上银行，将乙账户里的资金划到自己账户。按照 09 年司法解释，对甲定信用卡诈骗罪。也即，甲的行为原本属于盗划他人资金，构成盗窃罪，但是应当按照 09 年司法解释，作特殊处理，定信用卡诈骗罪。综上所述，本题答案为 D。

208、王某捡到李某丢失的手机，发现李某的微信支付软件与储蓄卡绑定。王某猜出支付密码后，通过微信支付，将李某储蓄卡中的 3 万元资金转到自己的银行卡账户。下列说法正确的是？

- A.对王某以诈骗罪论处
- B.对王某以盗窃罪论处
- C.相关司法解释规定，拾得他人信用卡并在 ATM 机上使用的，以信用卡诈骗罪论处。基于此，对王某以信用卡诈骗罪论处
- D.相关司法解释规定，以非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网使用的，以信用卡诈骗罪论处。基于此，对王某以信用卡诈骗罪论处

【答案】B**【解析】**

AB 项，王某是在李某不知情的情况下实施盗刷行为，不构成对李某的诈骗罪，而构成盗窃罪。B 项说法正确。C 项，2008 年司法解释规定，拾得他人信用卡并在 ATM 机上使用的，以信用卡诈骗罪论处。然而，题中，王某拾得的不是李某的信用卡，而是李某的手机，而且也没有在 ATM 机上使用。因此，王某的行为不适用该司法解释。C 项说法错误。D 项，2018 年司法解释规定，以非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网使用的，以信用卡诈骗罪论处。然而，题中，王某使用的是李某的微信支付密码，而非使用李某的银行卡密码。因此，王某的行为不适用该司法解释。D 项说法错误。

209、甲盗窃了丙的一部手机，发现手机上开通了“蚂蚁花呗”功能。甲破解了支付密码并欺骗乙，谎称该手机是自己捡来的，让乙使用上面的“蚂蚁花呗”透支消费。乙便在网上购物，透支消费了 3 万元。“蚂蚁花呗”是蚂蚁金服公司推出的一款消费信贷产品，申请开通后，可获得数万元的消费透支额度，先消费，后还款。下列说法正确的是？

- A.甲、乙均触犯盗窃罪
- B.甲、乙均触犯信用卡诈骗罪
- C.甲、乙对商家不构成诈骗罪，因为商家没有财产损失
- D.甲盗窃乙的蚂蚁花呗的信息资料并使用，属于盗窃信用卡并使用，根据刑法第 196 条第 3 款规定，以盗窃罪论处

【答案】C**【解析】**

第一，甲盗窃丙的手机，构成盗窃罪。但甲的这个盗窃罪与乙无关，乙不构成这个盗窃罪的共犯。第二，信用卡信息资料问题。09年司法解释规定：以非法方式获取他人信用卡信息资料，无论对人还是对机器使用，一律定信用卡诈骗罪。这里有两个要求：一是非法方式获取；二是信用卡的信息资料。第三，蚂蚁花呗。这是蚂蚁金服公司推出的一款透支消费的借贷服务，申请开通后，可获得数万元的消费透支额度，先消费，后还款。蚂蚁花呗的这种透支消费服务类似于可以透支的信用卡服务，是否属于电子方式的信用卡，在民法上有争议。但是，在刑法上多数观点认为，蚂蚁花呗不属于信用卡，主要理由是，信用卡诈骗罪的第196条第2款规定，信用卡是由发卡银行发行的，而蚂蚁金服公司虽然是金融机构，但不属于发卡银行。基于此，蚂蚁花呗的信息资料不属于信用卡信息资料，对此不需要适用09年司法解释，按照正常原理处理。第四，由于蚂蚁花呗不属于信用卡，因此乙不构成信用卡诈骗罪。乙的行为在性质上类似于冒用他人信用卡透支消费，交易流程也相似。按照正常原理，乙冒用丙的蚂蚁花呗账户，欺骗商家，但是直接受害人是花呗公司，乙属于三角诈骗，构成诈骗罪。甲的行为在性质上类似于冒用他人信用卡透支消费，交易流程也相似。第一，受骗人是商家。商家对使用者的合法身份具有审查义务（使用者是不是合法使用者），如果知道使用者是非法使用，具有拒绝义务。因此，商家误以为甲是合法使用者，受骗了。第二，商家是处分人，顾客委托商家完成结算。第三，直接受害人是花呗公司。花呗公司将自己的资金支付给了商家，遭受了财产损失。此处根据是电子商务法第57条第2款规定：“未经授权的支付造成的损失，由电子支付服务提供者承担；电子支付服务提供者能够证明未经授权的支付是因用户的过错造成的，不承担责任。”第五，共犯问题。乙构成诈骗罪，甲构成诈骗罪的教唆犯（指使）和帮助

犯（提供手机和信息资料）。第六，甲的问题。刑法第 196 条第 3 款规定：“盗窃信用卡并使用的，以盗窃罪论处。”这里的盗窃对象限于实体卡，不包括信用卡信息资料。其一，盗窃他人信用卡信息资料，无论对人或机器使用，一律定信用卡诈骗罪。这是 09 年司法解释的规定。其二，盗窃他人信用卡信息资料，复制一张实体卡（伪造信用卡），然后使用伪造的信用卡，无论对人或机器使用，一律定信用卡诈骗罪。因此，本题中，甲盗窃乙的蚂蚁花呗的信息资料并使用，不属于刑法第 196 条第 3 款的“盗窃信用卡并使用，定盗窃罪”。综上所述，本题答案为 C。

210、王某没有户籍,经同名同姓的堂兄同意,拿着堂兄的户口本为自己办理了身份证。王某用该身份证办理了银行卡后注册了支付宝,后系统提示还有一张银行卡可以绑定支付宝,赵某推测另一张卡为其堂兄的,随即予以绑定。次日,王某用支付宝消费了 3 万元,从堂兄的银行卡中扣款。王某的行为构成?

- A.抢夺罪
- B.信用卡诈骗犯罪
- C.盗窃罪
- D.侵占

【答案】C

【解析】

支付宝账户不属于银行卡账户,支付宝的支付密码不属于银行卡信息资料,因此不适用信用卡诈骗罪的相关规定。王某在堂兄不知情的情况下,将堂兄银行卡中的资金予以消费,属于将堂兄所有的财物,通过平和手段,转移为自己占有,这种盗刷行为构成盗窃罪。由于王某没有实施欺骗行为,堂兄也没有产生认识错误,不存在

基于认识错误处分财物,因此,王某不构成诈骗罪,也不构成信用卡诈骗罪。综上所述,本题答案为 C。

211、关于食品犯罪,下列说法正确的是?

- A.钱某从山林间拾得许多蘑菇,明知是毒蘑菇还卖给他人,其行为构成销售有毒、有害食品罪
- B.李某欲杀害妻子,在鸡汤中加入毒药,妻子中毒死亡。李某除构成故意杀人罪以外,还构成生产有毒、有害食品罪
- C.有证据证明赵某在生产食品时加入了非食品原料,但检测部门未检测出有毒、有害物质。赵某仍构成生产有毒、有害食品罪
- D.孙某用工业甲醇兑水,冒充白酒出售,导致数人中毒。孙某的行为不构成生产、销售有毒、有害食品罪,而构成投放危险物质罪

【答案】A

【解析】

考点:破坏社会主义市场经济秩序罪:生产、销售伪劣商品罪 A 项生产、销售有毒、有害食品罪中的食品包括未经加工的原始食材,例如打捞有毒的鱼并出售。因此,钱某构成销售有毒、有害食品罪。A 项说法正确。 B 项,生产、销售有毒、有害食品罪是选择性罪名,可以分解出生产有毒、有害食品罪。这里的“生产”要求具有销售的目的,也即带着销售目的而生产。单纯为了自用或其他用途而生产有毒、有害食品,不构成生产有毒、有害食品罪。因此,李某不构成生产有毒、有害食品罪,仅构成故意杀人罪。B 项说法错误。 C 项,根据法条规定,生产、销售有毒、有害食品罪,是指在生产、销售的食物中掺入有毒、有害的非食品原料。虽然赵某掺入了非食品原料,但是未能检测出有毒、有害物质,因此

不属于掺入有毒、有害的非食品原料，所以不构成生产、销售有毒、有害食品罪。

C项说法错误。D项，孙某用工业甲醇冒充白酒出售，构成生产、销售有毒、有害食品罪。该罪与投放危险物质罪不是对立排斥关系，而是可以想象竞合。生产、销售有毒、有害食品罪是行为犯（抽象危险犯），投放危险物质罪是具体危险犯。孙某的行为导致数人中毒，表明已经对公众产生了实害结果，因此构成投放危险物质罪。两罪想象竞合，择一重罪论处。D项说法错误。综上所述，本题答案为A。

212、关于洗钱罪，下列说法正确的是？

- A.《刑法》对洗钱罪的原规定是“明知是毒品犯罪……的所得及其产生的收益”，《刑法修正案（十一）》删除了“明知”。这表明，洗钱罪可以由过失构成
- B.诈骗罪、盗窃罪等财产犯罪的行为人，实施自洗钱行为，不可能构成洗钱罪
- C.洗钱罪的上游犯罪未经审判确定有罪，不得审判洗钱罪
- D.上游犯罪超过追诉时效，洗钱罪没有超过追诉时效的，可以追究洗钱罪的刑事责任

【答案】D

【解析】

考点：破坏社会主义市场经济秩序罪：破坏金融管理秩序罪 A项洗钱罪是故意犯罪，要求明知是上游犯罪的犯罪所得。删除“明知”并不能改变这一结论。实际上，大多数故意犯罪的条文中并没有“明知”的表述。A项说法错误。B项，《刑法修正案（十一）》增设规定，上游犯罪的行为人自己为自己洗钱，也构成洗钱罪。虽然洗钱罪的条文在描述上游犯罪时，没有“财产犯罪”的字眼，但并不意味着财产犯罪不能成为洗钱罪的上游犯罪。B项说法错误。C项，洗钱罪

的成立，应当以上游犯罪的犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪的犯罪事实已经查证属实，但对上游犯罪在程序上尚未审判的，不影响对洗钱罪的审判。因此，C项说法错误。D项，上游犯罪的追诉时效与洗钱罪的追诉时效互不干扰，各自算各自的。D项说法正确。综上所述，本题答案为D。

213、张某是甲工厂的领导，指示下属梁某“想办法”从乙工厂的技术人员田某处获取乙工厂的技术秘密。梁某给田某30万元，田某拒绝提供技术秘密。梁某拿出电锯威胁田某，不答应使用电锯锯死田某。田某被迫说出技术秘密。梁某给了田某30万元，田某收下。后甲工厂利用该技术秘密制作产品，销量大增。下列说法错误的是？

- A.梁某构成侵犯商业秘密罪的直接正犯
- B.张某构成侵犯商业秘密罪的教唆犯
- C.田某是侵犯商业秘密罪的胁从犯
- D.田某构成非国家工作人员受贿罪

【答案】C

【解析】

考点：破坏社会主义市场经济秩序罪：侵犯知识产权罪 AB项，根据刑法第219条，以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密，情节严重的，构成侵犯商业秘密罪。张某是教唆犯，梁某是直接正犯。AB项说法正确。C项，胁从犯，是指被胁迫参加犯罪的人。如果行为人身完全被强制或意志自由完全被剥夺，则不构成胁从犯，符合紧急避险条件的，可以成立紧急避险。梁某拿出电锯威胁田某，不答应使用电锯锯死田某。田某已经被压制了反抗，意志自由完全被剥夺，因此不构成胁从犯，并且构成紧急避险，因

为田某为了保护较大法益（自己的生命），不得已损害了较小法益（乙工厂的技术秘密）。C项说法错误。D项，梁某、张某的手段既包含贿赂，也包含胁迫，也即这两种手段不是对立排斥关系，可以并存。不能因为存在胁迫，便否定贿赂手段。因此，二人构成对非国家工作人员行贿罪。田某收了钱，构成非国家工作人员受贿罪。这种受贿属于事后型受贿，也即在提供了技术秘密后，田某收钱，属于收取对价（不正当报酬）。D项说法正确。综上所述，本题答案为C。

214、关于生产、销售伪劣商品罪，下列哪些判决是正确的？

A.甲销售的假药无批准文号，但颇有疗效，销售金额达500万元，如按销售假药罪处理会导致处罚较轻，法院以销售伪劣产品罪定罪处罚。

B.甲明知病死猪肉有害，仍将大量收购的病死猪肉，冒充合格猪肉在市场上销售。法院以销售有毒、有害食品罪定罪处罚

C.甲明知贮存的苹果上使用了禁用农药，仍将苹果批发给零售商。法院以销售有毒、有害食品罪定罪处罚

D.甲以为是劣药而销售，但实际上销售了假药，且对人体健康造成严重危害。法院以销售劣药罪定罪处罚

【答案】CD

【解析】

A选项：第一，按照2019年新的药品管理法规定，颇有疗效的药品不属于假药，甲不构成销售假药罪。同时，由于该颇有疗效的药品不属于假药，也就不属于伪劣产品，因此甲也不构成销售伪劣产品罪。第二，2021年《刑法修正案（十一）》增设了妨害药品管理罪。但是，甲的行为不构成妨害药品管理罪，因为该罪是具体危险犯，要求足以严重危害人体健康。而颇有疗效的药品没有这种危险，因此

A 选项错误。B.C 选项：根据刑法分则 144 条的规定，行为人掺入有毒、有害的非食品原料，或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的，触犯销售有毒、有害食品罪；刑法 146 条规定，行为人销售不符合食品安全标准的食品，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的，触犯销售不符合安全标准食品罪。在本案中，病死的猪肉不属于有毒有害食品，仅仅是一种过期、腐烂和变质的食品，应当认定其属于不符合安全标准的食品；但禁用农药具有巨大的毒性，满足刑法中的“有毒”的标准，系有毒有害物质。因此，B 选项错误，C 选项正确。D 选项：本案中，甲主观上认为销售的是劣药，但客观上销售的是假药且该种假药对人体健康造成了严重的危害，该种情形在刑法理论上被称之为事实认识错误，而且属于抽象的认识错误，故根据主客观相一致的原理，在主观层面上甲销售了劣药，在客观层面上销售了假药，假药可以包容评价为劣药，故二者在销售劣药罪的范围内相重合，因此，应认定其触犯销售劣药罪。因此，D 选项正确。综上所述，本题答案为 CD。

215、关于生产、销售伪劣商品罪，下列哪些选项是正确的？

- A.甲既生产、销售劣药，对人体健康造成严重危害，同时又生产、销售假药的，应实行数罪并罚
- B.乙为提高猪肉的瘦肉率，在饲料中添加“瘦肉精”。由于生猪本身不是食品，故乙不构成生产有毒、有害食品罪
- C.丙销售不符合安全标准的饼干，足以造成严重食物中毒事故，但销售金额仅有 500 元。对丙应以销售不符合安全标准的食品罪论处
- D.丁明知香肠不符合安全标准，足以造成严重食源性疾患，但误以为没有毒害而销售，事实上香肠中掺有有毒的非食品原料。对丁应以销售不符合安全标准的食

品罪论处

【答案】ACD

【解析】

A 选项：生产、销售劣药罪和生产、销售假药罪是两个独立的罪名。甲既生产、销售劣药，对人体健康造成严重危害，系触犯生产、销售劣药罪；同时甲还生产、销售假药，触犯生产、销售假药罪。甲具有生产、销售劣药和生产、销售假药两个行为，触犯两个犯罪，故应数罪并罚。因此，A 选项正确。 B 选项：《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第 9 条 2 款：“在食用农产品种植、养殖、销售、运输、贮存等过程中，使用禁用农药、兽药等禁用物质或者其他有毒、有害物质的，适用前款的规定定罪处罚（依照刑法第一百四十四条的规定以生产、销售有毒、有害食品罪定罪处罚）。”故乙为提高猪肉的瘦肉率，在饲料中添加“瘦肉精”，触犯生产、销售有毒、有害食品罪。因此，B 选项错误。 C 选项：《刑法》第 143 条规定：“生产、销售不符合食品安全标准的食品，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；后果特别严重的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”丙销售不符合安全标准的饼干，足以造成严重食物中毒事故，其行为触犯了销售不符合安全标准的食品罪。但金额只有 500 元，销售金额未达到 5 万元，其未触犯销售伪劣产品罪，仅仅触犯销售不符合安全标准的食品罪。因此，C 选项正确。 D 选项：丁明知香肠不符合安全标准，足以造成严重食源性疾患，在主观层面上，其具有销售不符合安全标准的食品罪的故意。但在客观层面上，其是销售有毒有害食品罪的行为。按照刑法理

论的主、客观相一致的原则，认定丁仅仅触犯销售不符合安全标准的食品罪。因此，D选项正确。综上所述，本题答案为ACD。

216、下列哪些行为（不考虑数量），应以走私普通货物、物品罪论处？

- A.将白银从境外走私进入中国境内
- B.走私国家禁止进出口的旧机动车
- C.走私淫秽物品，有传播目的但无牟利目的
- D.走私无法组装并使用（不属于废物）的弹头、弹壳

【答案】AD

【解析】

A选项：根据刑法第151条第2款，走私贵重金属罪是指将国家禁止出口的文物、黄金、白银和其他贵重金属出口的行为，进口上述物品并不构成本罪。但可将黄金、白银和其他贵重金属包容评价为普通货物、物品，故可评价为走私普通货物、物品罪。因此，A选项正确。B选项：根据刑法第151条第3款，走私珍稀植物及其制品等国家禁止进出口的其他货物、物品的，构成走私国家禁止进出口货物、物品罪。故走私国家禁止进出口的旧机动车的，触犯走私国家禁止进出口货物、物品罪。因此，B选项错误。C选项：根据刑法第152条第1款，以牟利或者传播为目的，走私淫秽的影片、录像带、录音带、图片、书刊或者其他淫秽物品的，构成走私淫秽物品罪。成立该罪只要求具有传播目的或者具有牟利目的其一即可，并不要求两者兼备。因此，C选项错误。D选项：《关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第4条2款：“走私报废或者无法组装并使用的各种弹药的弹头、弹壳，构成犯罪的，依照刑法第一百五十三条的规定，以走私普通货物、物品罪定罪处罚；属于废物的，依照刑法第一百五十二条

第二款的规定，以走私废物罪定罪处罚。”在本案中，若行为人走私的是既无法组装并使用，同时也不属于废物的弹头、弹壳的，其触犯走私普通货物、物品罪；若行为人走私的是废物的，其触犯走私废物罪；若行为人走私的是能被组装并使用的弹头、弹壳的，其触犯走私弹药罪。因此，D选项正确。综上所述，本题答案为AD。

217、关于走私犯罪，下列说法正确的有？

- A.王某以传播为目的，在家中登录境外网站，下载淫秽影片，发给几位朋友观看，构成走私淫秽物品罪
- B.陈某向境外网站购买枪支，邮寄到境内陈某家中，陈某构成走私武器罪
- C.张某不知道法律是否允许，将贴身佩戴的小金佛吊坠放在行李里带出国，构成走私贵重金属罪
- D.李某携带假币前往公海出售，没有卖掉，又带回境内，构成走私假币罪

【答案】BD

【解析】

A项，走私淫秽物品罪，是指违反海关法规，逃避海关监管，以牟利或者传播为目的，非法运输、携带、邮寄淫秽物品进出境的行为。王某在家中登录境外网站，下载淫秽影片。此时境外网站的注册地虽然在境外，但是下载行为发生在国内，因此不属于将淫秽物品从国外携带至国内，也即不属于进出境的行为，因此不属于走私行为。并且，王某只给少数几位朋友观看，也不属于传播淫秽物品罪。后者要求传播给不特定人或多数人。B项，陈某从境外购买枪支，邮寄到国内，构成走私武器罪。C项，走私贵重金属罪是故意犯罪，要求明知该金属属于国家禁止出境的贵重金属。由于张某对此并不明知，因此不构成走私贵重金属罪。

D 项，走私假币罪，是指违反海关法规，逃避海关监管，非法运输、携带假币进出境的行为。李某携带假币从境内进入公海，表明已经出境，构成走私假币罪。李某将假币从公海带进境内，再次构成走私假币罪。不过由于这两次行为具有连续性，可以以一罪处理。

218、钱某是某快递公司的业务员。快递公司对员工承诺，按照承揽业务额的 20% 给予奖励。钱某请表哥李某冒充某公司老总。钱某介绍李某与快递公司签订合同。李某虚构大量快递订单，业务量总计 30 万元。快递公司对钱某奖励 6 万元，并让钱某向李某的公司收取 30 万元快递费。钱某利用自己的信用卡恶意透支了 6 万元，交给快递公司。经发卡银行两次有效催收后超过 3 个月，钱某仍不还款。关于本案，下列说法正确的有？

- A. 钱某对快递公司不构成侵犯财产罪，因为快递公司没有财产损失
- B. 钱某对快递公司构成职务侵占罪
- C. 钱某对快递公司构成诈骗罪
- D. 钱某对银行构成信用卡诈骗罪

【答案】CD

【解析】

A 项：钱某虚构事实，欺骗快递公司的领导对其奖励 6 万元，此时快递公司便遭受了财产损失。至于事后钱某向快递公司交付 6 万元，不影响快递公司遭受财产损失这一事实的认定。因此，钱某构成侵犯财产犯罪。A 选项错误。BC 项：根据刑法第 271 条规定，职务侵占罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。职务侵占罪要求行为人利用职务便利，而侵占罪、盗窃罪、诈骗罪的行为人没有利用职务便利。

“利用职务便利”中的“职务”，是指具有一定管理权限的职务。例如，主管、管理、经营等职务。具体到诈骗这种行为方式，这里的利用职务便利，是指在实施欺骗时，行为人的职权、职务发挥了实质贡献或影响力。受骗人之所以受骗并处分财物，是因为相信了行为人的职权行为，也即有行为人的职权行为把关，自己只需形式审查。本题中，钱某对快递公司的财产没有一定的管理权限。快递公司领导受骗，并不是因为相信了钱某的职权行为，钱某没有职权行为。因此，钱某并没有“利用职务便利”，因此不构成职务侵占罪，构成普通的诈骗罪。B选项错误，C选项正确。D项：信用卡诈骗罪第四种行为类型“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次有效催收后超过3个月仍不归还。(1)行为主体是合法持卡人。这是指以自己的真实身份证申领到信用卡的持卡人。(2)“经发卡银行两次有效催收后超过3个月仍不归还”是客观处罚条件。本题中，钱某利用自己的信用卡恶意透支了6万元，经发卡银行两次有效催收后超过3个月，钱某仍不还款。钱某构成信用卡诈骗罪。D选项正确。综上所述，本题答案为CD。

219、甲和女友乙在网吧上网时，捡到一张背后写有密码的银行卡。甲持卡去ATM机取款，前两次取出5000元。在准备再次取款时，乙走过来说：“注意，别出事”，甲答：“马上就好。”甲又分两次取出6000元，并将该6000元递给乙。乙接过钱后站了一会儿说：“我走了，小心点。”甲接着又取出7000元。关于本案，下列哪些选项是正确的？

- A.甲拾得他人银行卡并在ATM机上使用，根据司法解释，成立信用卡诈骗罪
- B.对甲前两次取出5000元的行为，乙不负刑事责任
- C.乙接过甲取出的6000元，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪

D.乙虽未持银行卡取款，也构成犯罪，犯罪数额是 1.3 万元

【答案】ABD

【解析】

根据司法解释，拾得他人信用卡并在自动柜员机（ATM 机）上使用的行为，属于《刑法》第 196 条第 1 款第 3 项规定的“冒用他人信用卡”的情形，构成犯罪的，以信用卡诈骗罪追究刑事责任。A 项正确。根据题干表述，对甲在 ATM 机上前两次取出 5000 元的行为，乙是不知情的，乙没有为甲的这两次取钱行为提供任何物理或心理帮助，此时甲乙尚不是共同犯罪，而是甲自己一个人在犯罪，所以，乙对甲的该行为不负刑事责任。B 项正确。在甲再次取出 6000 元、7000 元时，乙已经知情，而且告诉甲“注意，别出事”“小心点”，这说明乙为甲的后面取钱的行为提供了心理上、精神上的支持和帮助，甲乙属于共同犯罪，乙需要对后面的 6000 元和 7000 元负责，数额为 1.3 万元。D 项正确。掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪主体不包括本犯，因为自己掩饰自己的犯罪所得不具有期待可能。在甲取 6000 元时，甲乙已经属于共同犯罪，甲乙均属于信用卡诈骗罪的本犯，所以乙不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。C 项错误。

220、2016 年 4 月，甲利用乙提供的作弊器材，安排大学生丙在地方公务员考试中代替自己参加考试。但丙考试成绩不佳，甲未能进入复试。关于本案，下列哪些选项是正确的？

- A.甲组织他人考试作弊，应以组织考试作弊罪论处
- B.乙为他人考试作弊提供作弊器材，应按组织考试作弊罪论处
- C.丙考试成绩虽不佳，仍构成代替考试罪
- D.甲让丙代替自己参加考试，构成代替考试罪

【答案】CD

【解析】

《刑法》第 284 条之一规定了组织考试作弊罪。组织作弊，是指组织、策划、指挥多人进行考试作弊，或者从事考试作弊的经营行为。行为人为特定的应考人寻找替考者，而没有组织多人替考的，不应认定为组织考试作弊罪。行为人为不特定的应考人与替考者之间从事中介服务的，则应认定为组织考试作弊罪。而代替考试罪，是指代替他人或者让他人代替自己参加法律规定的国家考试的行为。本案中，甲和丙均构成代替考试罪。乙为特定的应考人考试作弊提供帮助，但没有实施“组织”行为，不构成组织考试作弊罪。因此，A、B 选项错误，C、D 选项正确。

221、关于信用卡诈骗罪，下列哪些选项是错误的？

- A.以非法占有为目的，用虚假身份证明骗领信用卡后又使用该卡的，应以妨害信用卡管理罪与信用卡诈骗罪并罚
- B.根据司法解释，在自动柜员机(ATM 机)上擅自使用他人信用卡的，属于冒用他人信用卡的行为，构成信用卡诈骗罪
- C.透支时具有归还意思，透支后经发卡银行两次催收，超过 3 个月仍不归还的，属于恶意透支，成立信用卡诈骗罪
- D.《刑法》规定，盗窃信用卡并使用的，以盗窃罪论处。与此相应，拾得信用卡并使用的，就应以侵占罪论处

【答案】ACD

【解析】

根据《刑法》第 196 条第 1 款的规定，以非法占有为目的，用虚假身份证明骗领

信用卡后又使用该卡的，应以信用卡诈骗罪处罚。选项 A 错误。在自动柜员机（ATM 机）上擅自使用他人信用卡的行为，属于《刑法》第 196 条第 1 款第 3 项规定的“冒用他人信用卡”的情形，构成信用卡诈骗罪。选项 B 正确。“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过 3 个月仍不归还的行为。透支时没有非法占有的目的，具有归还意思的不属于恶意透支。选项 C 错误。拾得信用卡并使用的行为属于《刑法》第 196 条第 1 款第 3 项规定的“冒用他人信用卡”的情形，构成信用卡诈骗罪。选项 D 错误。

222、甲偷到乙的手机，破解了乙手机上的支付宝密码，使用里面的“蚂蚁花呗”在网上商家购买了 3 万元商品。“蚂蚁花呗”是蚂蚁金服公司推出的一款消费信贷产品，申请开通后，可获得数万元的消费透支额度，先消费，后还款。关于本案，下列说法正确的有？

- A.通过蚂蚁花呗可以透支消费，类似于信用卡，因此甲对乙构成信用卡诈骗罪
- B.商家没有财产损失，因此甲对商家不构成诈骗罪
- C.甲对蚂蚁金服公司构成贷款诈骗罪
- D.甲盗窃乙的手机，构成盗窃罪，与贷款诈骗罪并罚

【答案】BCD

【解析】

（1）信用卡信息资料问题。2018 年司法解释规定：以非法方式获取他人信用卡信息资料，无论对人还是对机器使用，一律定信用卡诈骗罪。这里有两个要求：一是非法方式获取；二是信用卡的信息资料。

（2）蚂蚁花呗。这是蚂蚁金服公司推出的一款透支消费的借贷服务，申请开通

后,可获得数万元的消费透支额度,先消费,后还款。蚂蚁花呗的这种透支消费服务类似于可以透支的信用卡服务,是否属于电子方式的信用卡,在民法上有争议。但是,在刑法上多数观点认为,蚂蚁花呗不属于信用卡,主要理由是,信用卡诈骗罪的第196条第2款规定,信用卡是由发卡银行发行的,而蚂蚁金服公司虽然是金融机构,但不属于发卡银行。基于此,蚂蚁花呗的信息资料不属于信用卡信息资料,对此不需要适用2018年司法解释,按照正常原理处理。

(3) 正常原理的分析。甲冒用乙的蚂蚁花呗账户,欺骗蚂蚁金服公司发放消费类贷款,使其遭受财产损失,因此构成诈骗罪。贷款诈骗罪是指诈骗银行或者其他金融机构的贷款。由于蚂蚁金服公司属于“其他金融机构”,因此,甲进而构成贷款诈骗罪。

提示:可能有人认为,蚂蚁金服公司不是受害人,乙才是受害人。然而,蚂蚁金服公司至少是直接受害人,至于能否向乙追偿,还需要进一步考察。刑法只关注直接受害人。此处根据是《电子商务法》第57条第2款规定:“未经授权的支付造成的损失,由电子支付服务提供者承担;电子支付服务提供者能够证明未经授权的支付是因用户的过错造成的,不承担责任。”

A项说法错误。蚂蚁花呗不属于信用卡,因此甲不构成信用卡诈骗罪,而构成贷款诈骗罪。

B项说法正确。商家不是受害人,因为商家获得了贷款,没有财产损失。

C项说法正确,蚂蚁金服公司是直接受害人。甲对其构成贷款诈骗罪。

D项说法正确。甲盗窃手机构成盗窃罪,后欺骗行为构成贷款诈骗罪。甲先后实施了两个行为,针对两个对象,因此应当数罪并罚。

综上所述,本题答案为BCD。。

223、甲盗窃了丙的一张银行卡，卡里有3万元。甲告诉乙该卡是捡来的，让乙在商场购物。乙在商场冒用该卡购买了3万元商品。关于本案，下列说法正确的有？

- A.甲、乙均触犯盗窃罪
- B.甲、乙均触犯信用卡诈骗罪
- C.甲触犯信用卡诈骗罪的教唆犯和帮助犯
- D.乙触犯信用卡诈骗罪的正犯

【答案】BCD

【解析】

第一，盗窃信用卡的行为定性。一般的非法取得行为本身不构成犯罪，只有非法使用(冒用)了银行卡，处分了卡里资金才构成犯罪。如果只取得，不使用，不构成犯罪。第二，乙在商场冒用。乙以为卡是甲捡来的，实际是甲盗窃来的。这种认识错误并不重要，因为乙至少认识到这是他人的卡，自己在非法使用。乙拿着卡到商场冒用，购买商品，商家不知情，提交交易单据和支付指令，丙卡里资金被划到商家账户。商家将商品交给乙。受骗人是商家，受害人是丙及其开户银行，乙这种冒用行为属于三角诈骗，构成信用卡诈骗罪。具体而言：(1)受骗人是商家。商家对持卡人的合法身份具有审查义务(持卡人是不是合法使用)，如果知道持卡人是非法使用，具有拒绝义务。这项审查义务体现在持卡人需要在交易单据上签名。因此，商家误以为乙是合法持卡人，受骗了，但商家不是受害人。(2)商家是处分人。顾客委托商家进行结算，由商家指令划账。(3)直接受害人是丙，开户银行也可能是受害人。此处根据是2019年1月1日生效的电子商务法，第57条规定：“未经授权的支付造成的损失，由电子支付服务提供者承担；电

子支付服务提供者能够证明未经授权的支付是因用户的过错造成的，不承担责任。”在民法上，丙和开户银行之间有民事责任的分配问题，都可能是受害人。刑法无法细分谁是受害人，就可以认为丙及其开户银行都是受害人。受害人是谁，对于认定行为人的诈骗罪没有影响，因为无论谁是受害人，行为人都构成诈骗罪。第三，共犯问题。乙构成信用卡诈骗罪的实行犯。甲构成信用卡诈骗罪的教唆犯（指使）和帮助犯（提供卡）。第四，甲的最终处理。虽然从共同犯罪角度看，甲构成信用卡诈骗罪的教唆犯（指使）和帮助犯（提供卡），但是，根据刑法第196条第3款规定，盗窃信用卡并使用，即使对人使用，应定信用卡诈骗罪，也拟制为盗窃罪，因此对甲最终应定盗窃罪。但甲不是盗窃罪的直接实行犯，因为甲没有亲自使用。甲也不是盗窃罪的教唆犯和帮助犯，因为若如此，则盗窃罪的实行犯在哪里？乙不可能构成盗窃罪的实行犯，乙构成信用卡诈骗罪。最终，甲构成盗窃罪的间接正犯。综上所述，本题答案为BCD。

224、甲伪造身份证，身份信息是虚假的，用该身份证申领了信用卡，持该信用卡到商场透支消费4万元，立即还款。银行误以为甲信用良好，将甲的信用额度提高至10万元额度。甲透支消费10万元后，立即注销电话号码，后经银行两次催收后超过3个月仍不还款。下列说法正确的有？

- A.甲触犯伪造身份证件罪
- B.甲触犯妨害信用卡管理罪
- C.甲触犯信用卡诈骗罪，属于该罪第一种行为类型“使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡”
- D.甲触犯信用卡诈骗罪，属于该罪第四种行为类型“恶意透支”

【答案】ABC

【解析】

A 项：根据《刑法》第 280 的规定，伪造身份证件罪是指伪造居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的行为。甲的行为触犯了伪造身份证件罪。A 选项正确。B 项，刑法第 177 条之一规定：有下列情形之一，妨害信用卡管理的，构成妨害信用卡管理罪：(1)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(2)非法持有他人信用卡，数量较大的；(3)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(4)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。因此，本题中的甲使用虚假的身份证明骗领信用卡，构成妨害信用卡管理罪。注意，甲不属于伪造信用卡。伪造信用卡构成伪造金融票证罪。B 选项正确。C 项，甲的行为属于信用卡诈骗罪第一种行为类型“使用以虚假的身份证明骗领的信用卡”，构成信用卡诈骗罪。具体而言，甲构成三角诈骗，受骗人是商家，受害人是发卡银行。受骗人是商家，这是因为，由于甲的行为属于违法犯罪行为，商家对持卡人的行为是否属于违法犯罪行为负有审查义务。如果知道持卡人的行为属于违法犯罪行为，具有拒绝义务，如果配合，则构成共犯。持卡人隐瞒了非法目的，使商家陷入认识错误，误以为持卡人没有非法占有目的。同时，商家是处分人，顾客委托商家完成结算。C 选项正确。D 项，甲的行为虽然属于恶意透支，但不属于信用卡诈骗罪第四种行为类型“恶意透支”。后者的恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次有效催收后超过 3 个月仍不归还。(1)行为主体是合法持卡人。这是指以自己的真实身份证申领到信用卡的持卡人。(2)“经发卡银行两次有效催收后超过 3 个月仍不归还”是客观处罚条件。实施完恶意透支，便触犯信用卡诈骗罪，但是此时

立法者为了缩小打击面,给行为人一个机会“赶紧还款”,如果“经发卡银行两次有效催收后超过3个月仍不归还”,则启动刑罚处罚。该规定的性质类似于逃税罪第4款规定的处罚阻却事由。应注意的是,甲的行为属于信用卡诈骗罪第一种行为类型“使用以虚假的身份证明骗领的信用卡”。追究这种信用卡诈骗罪的刑事责任,不存在客观处罚条件“经发卡银行两次有效催收后超过3个月仍不归还”,也即不给“赶紧还款”的机会,因为这里的行为人不是合法持卡人,而是非法持卡人。应注意的是,甲的第一次透支4万元,立即还款,不属于信用卡诈骗罪的实行行为,而属于预备行为,也即制造条件的行为,对此不能单独定罪处罚,也即不能将这4万元作为犯罪数额加以计算。最后,罪数问题。甲触犯的伪造身份证件罪、妨害信用卡管理罪、信用卡诈骗罪,相互之间都是牵连犯关系,也即手段与目的的关系,并且具有常见、常发、常伴随的特征,因此按照牵连犯处理,在三个罪名中择一重罪论处,一般而言,信用卡诈骗罪处罚最重,最终以信用卡诈骗罪论处。D选项错误。综上所述,本题答案为ABC。

225、关于药品犯罪的认定,下列说法正确的是?

- A.生产、销售、提供假药罪是抽象危险犯,生产、销售、提供劣药罪是具体危险犯
- B.生产、销售国务院药品监督管理部门禁止使用的药品的,构成生产、销售假药罪
- C.药品使用单位或其人员销售、提供假药给他人的,成立销售、提供假药罪
- D.擅自进口有疗效的药品在国内销售的,不成立销售假药罪,也不构成妨害药品管理罪

【答案】CD

【解析】

A项,根据《刑法》第141和142条规定,生产、销售、提供假药罪是抽象危险犯,也即行为犯,只要有这类行为就构成犯罪。生产、销售、提供劣药罪是实害犯,不是具体危险犯;成立该罪,要求对人体健康造成实害结果。A项的第二句说法错误。

B项,第一,根据新的《药品管理法》,假药的种类:药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符;以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品;变质的药品;(4)药品所标明的适应症或者功能主治超出规定范围。第二,本题中的“国务院药品监督管理部门禁止使用的药品”不一定是假药,还包括在某些场合禁止使用的真药。因此,B项说法错误。第三,根据《刑法》第142条之一的规定《刑法修正案(十一)》增设,生产、销售国务院药品监督管理部门禁止使用的药品,足以严重危害人体健康的,构成妨害药品管理罪。C项,根据《刑法》第141条的规定《刑法修正案(十一)》修订,药品使用单位或其人员销售、提供假药给他人的,成立销售、提供假药罪。也即,这种犯罪可以由单位构成,也可以由自然人构成。C项说法正确。D项,擅自进口有疗效的药品不属于假药,因此不构成销售假药罪,也不构成妨害药品管理罪。该罪的行为类型之一是,未取得药品批准证明文件生产、进口药品或者明知是上述药品而销售。D项说法正确。提示:成立妨害药品管理罪,要求足以严重危害人体健康。私自进口、销售印度仿制药,如果不足以严重危害人体健康,则不会构成该罪。因此,影片《我不是药神》中的男主角不会构成该罪,因为该药具有疗效。综上所述,本题答案为C.D。

226、关于洗钱罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的认定,下列说法正确的有?

A.甲欲向王某行贿,王某让甲直接将贿赂款汇到境外王某的账户,甲照办。甲构成行贿罪与洗钱罪的想象竞合

B.乙协助贩毒分子将贩毒所得赃款汇到境外,成立洗钱罪与转移毒赃罪的想象竞

合

C.贩毒分子丙将自己贩毒所得赃款汇到境外,成立洗钱罪,但不成立转移毒赃罪

D.犯受贿罪的国家工作人员丁将受贿款汇到境外的,应以受贿罪与洗钱罪实行数罪并罚

【答案】ABCD

【解析】

A项,贪污贿赂犯罪是洗钱罪的上游犯罪。洗钱罪的行为方式之一是跨境转移资产。甲向乙的账户打入贿赂款,构成行贿罪。甲直接将贿赂款打入乙的境外账户,也构成洗钱罪。甲整体上是一个行为,同时触犯两个罪,属于想象竞合,择一重罪论处。A项说法正确。B项,毒品犯罪是洗钱罪的上游犯罪。本题中乙的行为构成洗钱罪。毒赃,是指通过贩卖毒品获得的赃款。转移毒赃罪是指帮助贩毒分子转移毒赃,属于事后的赃物犯罪。本题中,乙协助贩毒分子转移毒赃,构成转移毒赃罪。乙的一个行为同时触犯洗钱罪与转移毒赃罪,属于想象竞合,择一重罪论处。B项说法正确。C项,《刑法修正案(十一)》规定,自己给自己洗钱,也构成洗钱罪。这是一种特殊规定,是期待可能性原理的例外。基于此,贩毒分子给自己洗钱,也构成洗钱罪。但是,转移毒赃罪是事后的赃物犯罪,应遵循期待可能性原理,也即贩毒分子给自己转移毒赃,不构成转移毒赃罪,因为不具有期待可能性;同理,也不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。C项说法正确。D项,自己给自己洗钱,也构成洗钱罪。因此,丁将受贿款汇到境外,为自己洗钱,构成洗钱罪。而丁之前还构成受贿罪。前后两个行为构成两个罪,应数罪并罚。在此不能根据期待可能性原理,认为洗钱罪属于不可罚的事后行为。这是因为,既然《刑法修正案(十一)》规定了,自洗钱行为构成洗钱罪,那么就不能将这种洗钱行为视为不可罚的事后行为。D项说法正确。

综上所述,本题答案为 A.B.C.D。

227、甲盗窃他人的银行卡,然后在银行柜台冒用该银行卡,欺骗柜员,将卡中资金 50 万元转入自己银行账户。次日,甲来到另一银行柜台,向柜员乙告知真相,指示乙将该 50 万元汇往境外。下列说法正确的有?

- A.甲构成盗窃罪
- B.乙仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪
- C.由于甲实施了信用卡诈骗罪的行为,所以乙构成洗钱罪
- D.如果对乙以洗钱罪论处,那么必须对甲以信用卡诈骗罪论处,否则违反罪刑法定原则

【答案】AC

【解析】

A 项,《刑法》第 196 条第 3 款规定:盗窃信用卡并使用的,以盗窃罪论处。普通盗窃信用卡的行为本身不构成盗窃罪,只有使用才构成犯罪。按照原理,对机器使用,原本就定盗窃罪。对此,第 196 条第 3 款的结论是定盗窃罪。就此而言,该款规定是注意规定。按照原理,对人使用,骗人,原本应定信用卡诈骗罪,但是第 196 条第 3 款的结论是定盗窃罪,这意味着将信用卡诈骗罪拟制为盗窃罪,属于法律拟制。本题中,甲对人使用,欺骗人,实施了信用卡诈骗罪的行为,但最终拟制为盗窃罪。A 项说法正确。B.C 项,洗钱罪的上游犯罪包括金融诈骗罪,而信用卡诈骗罪属于金融诈骗罪,所以洗钱罪的上游犯罪包括信用卡诈骗罪。洗钱罪的上游犯罪是指犯罪事实、犯罪行为,不限于罪名。基于此,由于甲实施了信用卡诈骗罪的犯罪事实、犯罪行为,因此乙构成洗钱罪,而非仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。B 项说法错误,C 项说法正确。D 项,将洗钱罪的上游犯罪解释为,不限于罪名,还包括犯罪行为,没有

明显超出国民预测可能性,因此不属于类推解释,而属于扩大解释,所以不违反罪刑法定原则。因此,对乙以洗钱罪论处,不需要对甲以信用卡诈骗罪论处。D项说法错误。综上所述,本题答案为A.C。

228、关于财产犯罪和人身犯罪,下列说法正确的有?

- A.甲盗窃丙的财物,被发现后逃跑,丙追赶。甲逃跑途中遇见乙,告知乙真相,请乙帮助自己殴打丙、拦住丙。乙便对丙实施暴力,将丙打倒,致丙轻伤。甲、乙构成抢劫罪的共同犯罪
- B.甲欲入户抢劫丙家,进入丙家,用迷药将丙迷晕,甲欲将丙家的保险柜抬走,无奈由于太重而搬不动。甲便电话告知乙,请其来帮忙,乙答应,来到丙家,与甲共同搬走保险柜。甲、乙构成抢劫罪的共同犯罪
- C.乙在水果摊位购买水果后,不付钱便离开。摊主甲追上前讨要水果钱,抓住乙的肩膀不让走,乙在挣脱中摔倒在地,导致重伤。甲构成过失致人重伤罪
- D.甲是无业游民,购买了一批假药,打算免费赠送老年人,骗取信任,以此诈骗其钱财。然而,存储假药的仓库发生火灾,假药全部被毁。甲构成诈骗罪的犯罪预备和提供假药罪的犯罪预备

【答案】AB

【解析】

考点:破坏社会主义市场经济秩序罪(1):生产、销售伪劣商品罪A项,事后转化抢劫=前提事实(实施前罪)+实行行为(事后使用暴力)。“前罪实施者”类似于一种身份,只有具有这种身份才能构成转化抢劫的实行犯。因此,转化抢劫类似于一种真正身份犯。可用该原理来指导转化抢劫的共犯问题。本题中,(1)从转化抢劫的角度分析。乙不是前罪实施者,没有特定身份,不能担任转化抢劫

的实行犯角色。甲不能构成转化抢劫的教唆犯，因为如此，会缺少转化抢劫的实行犯，乙不构成转化抢劫的实行犯。为此，只能让甲成为转化抢劫的间接正犯，乙构成转化抢劫的帮助犯。二人构成转化抢劫的共同犯罪。传统观点认为，间接正犯是单独犯罪的现象，与被利用人不能构成共同犯罪。这种说法过于绝对，并不准确。(2) 从故意伤害罪的角度分析，乙构成故意伤害罪的实行犯，甲构成故意伤害罪的教唆犯。(3) 综合结论，乙同时构成故意伤害罪的实行犯和转化抢劫的帮助犯，想象竞合，择一重罪论处。甲同时构成故意伤害罪的教唆犯和转化抢劫的间接正犯，想象竞合，择一重罪论处。A 项说法正确。B 项，抢劫罪的实行行为包括暴力等强制行为和取财行为。乙中途参与取财行为，构成甲的抢劫罪的承继的共同犯罪。B 项说法正确。C 项，(1) 甲抓住乙的行为是为了实现债权（财产性利益），是一种追财行为，该行为并没有超过必要限度，因此属于合法行为，不是危害行为，在客观要件板块便直接得出无罪结论。也即，甲的无罪结论不需要用后面“违法阻却事由”板块中的正当防卫来论证。(2) 乙摔倒在地，属于被害人自陷风险，自己负责。因此，甲不构成过失致人重伤罪。C 项说法错误。D 项，(1) 犯罪预备，是指为了着手实行犯罪，准备工具，制造条件，因意志以外的原因未能着手。甲准备假药的行为属于准备诈骗用的工具，属于预备行为。由于意志以外的原因，甲未能着手，因此，甲构成诈骗罪的犯罪预备。有同学可能认为，甲准备假药的行为对老年人没有制造危险，属于生活行为，因此不构成诈骗罪的犯罪预备。然而，甲准备的是假药，是违法物品，不是正常的生活用品。如果甲为了诈骗，购买巧克力，则不构成诈骗罪的犯罪预备。(2) 提供假药罪的主体是特殊主体，要求是药品使用单位及其人员，例如医院或医生。甲不是药品使用单位的人员，所以不构成提供假药罪。D 项说法错误。综上所述，本题答案

为 AB。

229、甲无意竞拍土地，得知报名参加竞拍，会有人收购其竞拍资格，遂让自己的公司报名参加某市自然资源与国土资源管理局组织的土地竞拍。甲的公司连续报名参加两次竞拍，果然有人收购其竞拍资格，获利 600 万，第三次参加竞拍，因无人收购而自动丧失竞拍资格。甲的行为构成？

- A.串通投标罪
- B.强迫交易罪
- C.非法经营罪
- D.非国家工作人员受贿罪

【答案】D

【解析】

A 项，投标与拍卖是性质不同的事项。若将拍卖解释为投标，属于类推解释。本案是对土地的竞拍，是拍卖活动。对串通拍卖不能定串通投标罪。B 项，司法解释规定，如果强迫他人退出投标、拍卖活动，可定强迫交易罪。但是本题中，甲和收购者之间不存在强迫，而是自愿买卖，因此双方均不构成强迫交易罪。C 项，没有司法解释将串通拍卖认定为非法经营罪，因此，对串通拍卖不能定非法经营罪。D 项，非国家工作人员受贿罪（第 163 条），是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大（6 万元以上）的行为。“为他人谋取利益”，既包括正当利益，也包括不正当利益。“为他人谋取利益”只要求许诺为他人谋取利益，不要求实际上为他人谋取了利益。这一点与受贿罪相同。题中，甲的行为符合非国家工作人员受贿罪的构成要件。原型出处：《刑事审判参考》（第 1136 号）“张

建军、刘祥伟对非国家工作人员行贿案”。其中裁判要旨指出：“从刑法规定来看，尚没有对挂牌竞买人相互串通，情节严重，追究刑事责任的规定，也无相关司法解释。因此，在国有建设用地使用权挂牌出让过程中，通过贿赂指使参与竞买的其他人放弃竞买、串通报价，最终使请托人竞买成功的，不属于串通投标罪的行为，只能按照对非国家工作人员行贿罪追究相关人员的刑事责任。”

230、甲将私家车借给无驾照的乙使用。乙夜间驾车与其叔丙出行，途中遇刘某过马路，不慎将其撞成重伤，车辆亦受损。丙下车查看情况，对乙谎称自己留下打电话叫救护车，让乙赶紧将车开走。乙离去后，丙将刘某藏匿在草丛中离开。刘某因错过抢救时机身亡。（事实一）为逃避刑事责任，乙找到有驾照的丁，让丁去公安机关“自首”，谎称案发当晚是丁驾车。丁照办。公安机关找甲取证时，甲想到若说是乙造成事故，自己作为被保险人就无法从保险公司获得车损赔偿，便谎称当晚将车借给了丁。（事实二）后甲找到在私营保险公司当定损员的朋友陈某，告知其真相，请求其帮忙向保险公司申请赔偿。陈某遂向保险公司报告说是丁驾车造成事故，并隐瞒其他不利于甲的事实。甲顺利获得7万元保险赔偿。

（事实三）关于事实三的分析，下列选项正确的是：

- A.甲对发生的保险事故编造虚假原因，骗取保险金，触犯保险诈骗罪
- B.甲既触犯保险诈骗罪，又触犯诈骗罪，由于两罪性质不同，应数罪并罚
- C.陈某未将保险金据为己有，因欠缺非法占有目的不构成职务侵占罪
- D.陈某与甲密切配合，骗取保险金，两人构成保险诈骗罪的共犯

【答案】AD

【解析】

根据《刑法》第198条的规定，保险诈骗罪是指以非法获取保险金为目的，违

反保险法规，采用虚构保险标的、保险事故、对发生的保险事故编造虚假的原因或者制造保险事故等方法，向保险公司骗取保险金，数额较大的行为。甲的行为已经构成本罪。A 正确。保险诈骗罪与诈骗罪是特别法与一般法的法条竞合关系，甲的行为不再另行构成诈骗罪。B 错误。陈某和甲构成共同犯罪，根据“部分行为全部责任”的共同犯罪理论，陈某是否从保险赔偿中获取利益并不影响对其行为的定性。根据有关司法解释，认定其行为构成保险诈骗罪还是职务侵占罪的关键在于谁在共同犯罪中具有关键地位。本案中，甲显然在共同犯罪中占主导地位。因此应当认定甲与陈某构成保险诈骗罪的共同犯罪。C 错误，D 正确。

231、甲是 A 公司（国有房地产公司）领导，因私人事务欠蔡某 600 万元。蔡某让甲还钱，甲提议以 A 公司在售的商品房偿还债务，蔡某同意。甲遂将公司一套价值 600 万元的商品房过户给蔡某，并在公司财务账目上记下自己欠公司 600 万元。三个月后，甲将账作平，至案发时亦未归还欠款。（事实一）A 公司有工程项目招标。为让和自己关系好的私营公司老板程某中标，甲刻意安排另外两家公司与程某一起参与竞标。甲让这两家公司和程某分别制作工程预算和标书，但各方约定，若这两家公司中标，就将工程转包给程某。程某最终在 A 公司预算范围内以最优报价中标。为感谢甲，程某花 5000 元购买仿制古董赠予甲。甲以为是价值 20 万元的真品，欣然接受。（事实二）甲曾因公务为 A 公司垫付各种费用 5 万元，但由于票据超期，无法报销。为挽回损失，甲指使知情的程某虚构与 A 公司的劳务合同并虚开发票。甲在合同上加盖公司公章后，找公司财务套取“劳务费”5 万元。（事实三）关于事实二的分析，下列选项正确的是：

A.程某虽与其他公司串通参与投标，但不构成串通投标罪

B.甲安排程某与他人串通投标，构成串通投标罪的教唆犯

C.程某以行贿的意思向甲赠送仿制古董，构成行贿罪既遂

D.甲以受贿的意思收下程某的仿制古董，构成受贿罪既遂

【答案】A

【解析】

A 选项：根据《中华人民共和国刑法》第 223 条规定，串通投标罪，指投标者相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，或者投标者与招标者串通投标，损害国家、集体、公民的合法权益，情节严重的行为。因此，不管是投标人之间相互串通，抑或是招标人与投标人之间相互串通，均要求导致公司的损失。

本案中，我们可以看到程某最后是在 A 公司预算范围内以最优报价中标的，这就可以推定 A 公司并没有受到损失，故未触犯串通投标罪。因此，A 选项正确。

B 选项：按照 A 选项的理解，程某没有串通投标的犯罪行为，未触犯串通投标罪。

按照共犯从属性原理，甲也不构成串通投标罪的教唆犯。因此，B 选项错误。C

选项：理由一，刑法第 389 条：“为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。”因此，成立行贿罪要求行为人谋取的是不正当的利益，即非法利益。在本案中，程某的行为属于按照正常程序获得的利益，未触犯行贿罪；

理由二，按照最新司法解释的规定，行贿罪的入罪数额通常是 3 万元以上，在本案中，行贿数额未达到行贿罪的入罪标准。因此，C 选项错误。D 选项：甲虽然具有受贿故意，但未达受贿罪所要求的立案标准，不应以犯罪论处。因此，D 选项错误 综上所述，本题答案为 A。

232、甲怀疑医院救治不力致其母死亡，遂在医院设灵堂、烧纸钱，向医院讨说法。结合社会主义法治理念和刑法规定，下列哪一看法是错误的？

A.执法为民与服务大局的理念要求严厉打击涉医违法犯罪，对社会影响恶劣的涉

医犯罪行为，要依法从严惩处

B.甲属于起哄闹事，只有造成医院的秩序严重混乱的，才构成寻衅滋事罪

C.如甲母的死亡确系医院救治不力所致，则不能轻易将甲的行为认定为寻衅滋事罪

D.如以寻衅滋事罪判处甲有期徒刑 3 年、缓刑 3 年，为有效维护医疗秩序，法院可同时发布禁止令，禁止甲 1 年内出入医疗机构

【答案】D

【解析】

A 选项：涉医犯罪严重影响着社会秩序，医疗事业又是国家的基础事业，是关乎民众健康的基础事业，故严厉打击涉医违法犯罪是执法为民与服务大局的理念的必然要求；对社会影响恶劣的涉医犯罪行为，应当按照法律规定从严惩处。因此，A 选项正确。B 选项：《刑法》第 293 条规定了寻衅滋事罪，其中规定“在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的，是寻衅滋事罪。”医院是公共场所，甲的行为属于起哄闹事，但是只有造成医院的秩序严重混乱的，才能构成寻衅滋事罪。因此，B 选项正确。C 选项：如甲母的死亡确系医院救治不力所致，则医院则可能存在医疗过错，家属因为亲人的离去而产生悲伤心理，从而采取不理智的方法维权，也是情有可原的。因此，C 选项正确。D 选项：《刑法》第 72 条第 2 款规定：“宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。”虽然甲被判处缓刑，符合禁止令适用条件，但是禁止令的适用不得妨碍犯罪分子的正常社会生活，医疗机构对于社会中的人来说是救死扶伤的地方，不可以发布“限制进入医疗机构”的禁止令。因此，D 选项错误。综上所述，本题答案为 D。

233、下列哪一行为应以妨害公务罪论处？

- A.甲与傅某相互斗殴，警察处理完毕后让各自回家。傅某当即离开，甲认为警察的处理不公平，朝警察小腿踢一脚后逃走
- B.乙夜间入户盗窃时，发现户主戴某是警察，窃得财物后正要离开时被戴某发现。为摆脱抓捕，乙对戴某使用暴力致其轻微伤
- C.丙为使其弟逃跑，将前来实施行政拘留的警察打倒在地，其弟顺利逃走
- D.丁在组织他人偷越国（边）境的过程中，以暴力方法抗拒警察检查

【答案】C

【解析】

A 选项：《刑法》第 277 条规定了妨害公务罪的四种类型：（1）以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，属于妨害公务罪的基本类型。暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，按该情况处理。（2）以暴力、威胁方法阻碍人大代表依法执行代表职务。（3）在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责。（4）阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务。A 项中，警察已经履行公务完毕，所以甲的行为不能认定为妨害公务的行为；如果甲把警察踢伤的，直接认定为故意伤害罪，不成立妨害公务罪。因此，A 选项错误。B 选项：戴某虽为警察，但是没有履行公务的行为，乙的行为直接认定为抢劫（《刑法》第 269 条的事后抢劫），不成立妨害公务罪。因此，B 选项错误。C 选项：当警察正在实施行政拘留行为时，应认定警察正在依法履行公务，此时丙认识到警察执行公务仍然实施妨害行为的，触犯妨害公务罪。因此，C 选项正确。D 选项：根据《刑法》第 318 条的规定，组织他人偷越国（边）境，以暴力、威胁方法抗拒检查的，属于情节加重犯，仍应以组织他

人偷越国（边）境罪论处，适用升格的法定刑。组织他人偷越国（边）境，以暴力威胁方法抗拒检查的，属于该罪的加重情节之一，不再单独认定为妨害公务罪。

因此，D 选项错误。综上所述，本题答案为 C。

234、甲杀人后将凶器忘在现场，打电话告诉乙真相，请乙帮助扔掉凶器。乙随即把凶器藏在自家地窖里。数月后，甲生活无着落准备投案自首时，乙向甲汇款 2 万元，使其继续在外生活。关于本案，下列哪一选项是正确的？

- A.乙藏匿凶器的行为不属毁灭证据，不成立帮助毁灭证据罪
- B.乙向甲汇款 2 万元不属帮助甲逃匿，不成立窝藏罪
- C.乙的行为既不成立帮助毁灭证据罪，也不成立窝藏罪
- D.甲虽唆使乙毁灭证据，但不能认定为帮助毁灭证据罪的教唆犯

【答案】D

【解析】

A 选项：帮助毁灭、伪造证据罪是指《刑法》第 307 条之一规定的帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的行为。帮助毁灭证据罪并不要求必须将证据毁灭，妨害证据效力实现的一切行为均可构成帮助毁灭证据罪。甲杀人后将凶器忘在现场后，请求乙帮助扔掉凶器，乙明知是凶器但仍将该凶器藏在自家地窖的行为符合帮助毁灭证据罪的构成要件，成立帮助毁灭证据罪。因此，A 选项错误。B 选项：《刑法》第 310 条规定的窝藏、包庇罪是指明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的行为。本案中，乙明知甲是犯罪分子，但仍给其汇款，帮助其逃匿。乙的行为符合窝藏罪的构成要件，成立窝藏罪。因此，B 选项错误。C 选项：根据 A、B 项的分

析，乙藏匿凶器和向甲汇款是两个独立的行为，应当分别评价，分别成立帮助毁灭证据罪与窝藏罪，应当数罪并罚。因此，C选项错误。

D选项：甲虽唆使乙毁灭证据，该行为应当认定为不可罚的事后行为，犯罪分子在犯罪后隐匿自己罪证的行为不具有期待可能性，不必再行惩罚。甲的行为不认为是帮助毁灭证据罪的教唆犯，不构成犯罪。因此，D选项正确。综上所述，本题答案为D。

235、《刑法》第64条前段规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔”。关于该规定的适用，下列哪一选项是正确的？

- A.甲以赌博为业，但手气欠佳输掉200万元。输掉的200万元属于赌资，应责令甲全额退赔
- B.乙挪用公款炒股获利500万元用于购买房产（案发时贬值为300万元），应责令乙退赔500万元
- C.丙向国家工作人员李某行贿100万元。除向李某追缴100万元外，还应责令丙退赔100万元
- D.丁与王某共同窃取他人财物30万元。因二人均应对30万元负责，故应向二人各追缴30万元

【答案】B

【解析】

A选项：所谓责令退赔，是指责令犯罪分子向原主退还或赔偿非法取得的财物等。责令退赔的只能是被害人的合法财产，对于非法财产、违法财产、不法原因给付给对方的财物都是不能返还。根据司法解释，赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。赌资应当依法予以追缴；赌博用具、

赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。据此，行为人已经输掉的财物，对于行为人而言，不属于赌资，不可能再没收，也不存在责令退赔问题。因此，A 选项错误。B 选项：犯罪违法所得财物包括犯罪行为所得之物（不仅包括违法所得的财物本身，而且包括违法所得的财物产生的收益）和作为犯罪行为的报酬而得到的财物。单位的公款本身和所获利益都属于被害人的合法财产，所以行为人挪用公款所获利益是应该予以退赔。退赔的数额以其违法所得的财物为准，而不是以其拿到违法所得财物之后进一步进行投资、消耗而转化后的财物为准的。乙挪用公款炒股获利的 500 万元属于违法所得，其用 500 万购买房产，无论其贬值与否都不影响因挪用公款炒股获利的数额，所以应责令乙退赔的金额为 500 万元。因此，B 选项正确。C 选项：本案中，丙向李某行贿 100 万，系因不法原因给付给他人的财物，即该款额是不法财产，刑法主流观点认为此时丙不享有返还请求权，而是应直接没收。若在向李某追缴 100 万元之后，又责令丙退赔 100 万元的，就等于对同一行为进行了两次评价，即重复评价，这是不符合罪刑法定原则的。因此，C 选项错误。D 选项：按照共同犯罪当理论，行为人只要在一个违法行为中发挥了作用力，无论其作用力的大小，就应该把这个违法事实归到所有行为人身上，即所有共犯人的行为与违法事实存在刑法上的因果关系。具体在本案中，两人都要对 30 万元负刑事责任，但追缴的数额总额只能是 30 万元。否则就有重复评价之嫌。因此，D 选项错误。综上所述，本题答案为 B。

236、医生甲退休后，擅自为人看病 2 年多。某日，甲为乙治疗，需注射青霉素。乙自述以前曾注射过青霉素，甲便未做皮试就给乙注射青霉素，乙因青霉素过敏而死亡。关于本案，下列哪一选项是正确的？

- A.以非法行医罪的结果加重犯论处
- B.以非法行医罪的基本犯论处
- C.以过失致人死亡罪论处
- D.以医疗事故罪论处

【答案】A

【解析】

A 选项：《刑法》第 336 条规定的非法行医罪，是指未取得医生执业资格的人非法行医，情节严重的行为。退休医生的执业证书自动失效，即退休医生不具有医生职业资格证，故退休医生属于“未取得医生职业资格证”的情形。甲可以成为非法行医罪的主体，此外，非法行医致造成就诊人死亡的，属于非法行医罪的结果加重犯，本案中，甲非法行医，并造成就诊者乙死亡的行为成立非法行医罪的结果加重犯，应以非法行医罪的结果加重犯论处。因此，A 选项正确，B 选项错误。C 选项：甲的行为满足过失致人死亡罪的构成要件，但过失致人死亡罪和非法行医罪的结果加重犯是普通法条和特殊法条的关系（法条竞合），对此应适用特殊法条非法行医罪的结果加重犯的规定。因此，C 选项错误。D 选项：《刑法》第 335 条规定的医疗事故罪，是指医务人员由于严重不负责任，造成就诊人死亡或者严重损害就诊人身体健康的行为。“医务人员”是指直接从事诊疗护理工作的人员，包括国家、集体医疗单位的医生、护士、药剂人员，以及经主管部门批准开业的个体行医人员，还包括从事医疗管理、后勤服务等人员。甲已经退休，也未经主管部门批准成为个体行医人员，故不属于医务人员，甲不能成立医疗事故罪。因此，D 选项错误。综上所述，本题答案为 A。

237、甲公司竖立的广告牌被路边树枝遮挡，甲公司在未取得采伐许可的情况下，

将遮挡广告牌的部分树枝砍掉，所砍树枝共计 6 立方米。关于本案，下列哪一选项是正确的？

- A.盗伐林木包括砍伐树枝，甲公司的行为成立盗伐林木罪
- B.盗伐林木罪是行为犯，不以破坏林木资源为要件，甲公司的行为成立盗伐林木罪
- C.甲公司不以非法占有为目的，只成立滥伐林木罪
- D.不能以盗伐林木罪判处甲公司罚金

【答案】D

【解析】

A.B.D 选项：《刑法》第 345 条第 1 款规定的盗伐林木罪，是指盗伐森林或者其他林木，数量较大的行为。“盗伐林木”是指以非法占有为目的，擅自砍伐森林或者其他林木，数量较大的行为。本案中，甲公司砍树枝是为了将广告牌显露出来，不具有非法占有的目的，故甲公司的行为不成立盗伐林木罪。既然甲公司不构成盗伐林木罪，自然也不能以盗伐林木罪判处甲公司罚金。因此，A.B 选项错误，D 选项正确。C 选项：《刑法》第 345 条第 2 款规定的滥伐林木罪，是指违反森林法的规定，滥伐森林或者其他林木，数量较大的行为。本罪“数量较大”，以 10—20 立方米或者幼树 500—1000 株为起点。甲公司所砍树枝共计 6 立方米，不构成滥伐林木罪。因此，C 选项错误。综上所述，本题答案为 D。

238、关于盗伐林木罪，下列哪一选项是正确的？

- A.甲盗伐本村村民张某院落外面的零星树木，如果盗伐数量较大，构成盗伐林木罪
- B.乙在林区盗伐珍贵林木，数量较大，如同时触犯其他法条构成其他犯罪，应数

罪并罚

C.丙将邻县国有林区的珍贵树木移植到自己承包的林地精心养护使之成活的,不属于盗伐林木

D.丁在林区偷扒数量不多的具有药用价值的树皮,致使数量较大的林木枯死的,构成盗伐林木罪

【答案】D

【解析】

A选项:根据《刑法》第345条的规定,盗伐林木罪是指盗伐森林或者其他林木,数量较大的行为。盗伐林木罪中的“林木”限于森林或者其他林木,不包括居民屋前屋后个人所有的零星树木。盗伐国家、集体或者他人所有并且已经伐倒的树木、他人房前屋后、自留地种植的零星树木、已经枯死、病死的林木的,成立盗窃罪。故甲盗伐本村村民张某院落外面零星树木的行为成立盗窃罪。因此,A选项错误。

B选项:乙在林区盗伐珍贵林木,数量较大,如同时触犯其他法条构成其他犯罪,此种情形属于一个行为触犯数罪的情形,原则上,无论是属于法条竞合还是属于想象竞合,都均应该按照重罪处罚,而不可能数罪并罚。因此,B选项错误。C选项:盗伐林木罪需要具有非法占有的目的。且盗伐行为不限于非法砍伐行为,还包括非法采伐行为。丙将邻县国有林区的珍贵树木移植到自己承包的林地精心养护使之成活的,属于非法采伐林木的行为并具有非法占有的目的,即属于盗伐林木行为(同时触犯非法采伐国家重点保护植物罪)。因此,C选项错误。D选项:根据《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案

件具体应用法律若干问题的解释》的规定，非法实施采种、采脂、挖笋、掘根、剥树皮等行为，牟取经济利益数额较大的，依照《刑法》第 264 的规定，以盗窃罪定罪处罚，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。丁在林区偷扒具有药用价值的树皮，因其数量不多，不成立盗窃罪；但其行为致使数量较大的林木枯死，侵犯了林木资源，本质上属于盗伐林木数量较大的行为，构成盗伐林木罪。因此，D 选项正确。综上所述，本题答案为 D。

239、高空抛物罪要求“从建筑物或者其他高空抛掷物品”。下列说法正确的是？

- A. 行为人只有从高空抛物的,才可能构成高空抛物罪
- B. 行为人从平地抛起物品、从高空落下的行为适用该规定
- C. 从建筑物抛下物品,只要是二层,就属于高空抛物
- D. 成立高空抛物罪,要求伤害到他人

【答案】C

【解析】

高空抛物罪(第 291 条之二):“从建筑物或者其他高空抛掷物品,情节严重的,处一年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。有前款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。这是《刑法修正案(十一)》增设的条文。

A 项,明知井下有人作业,仍从井口向下扔东西,也属于高空抛物。也即“高空”是个相对概念。因此,A 项说法过于绝对。B 项,从地面向上抛物,使物品从高空坠落,不属于高空抛物。也即,高空抛物,要求从“高空”向下抛物。因此,B 项说法错误。

C 项,多高算“高”空?高度是二层楼或 3 米左右。因此,从建筑物抛下物品,只要是二层,就属于高空抛物。但是注意,属于高空抛物,不等于构成高空抛物罪。成立

本罪,要求情节严重。因此,C项说法正确。D项,本罪是情节犯,要求情节严重。本罪不是结果犯(实害犯),不要求造成实害结果,不要求伤害到他人。如果伤害到他人,会触犯故意伤害罪、过失致人重伤罪等,与高空抛物罪想象竞合,择一重罪论处。因此,D项说法错误。综上所述,本题答案为C。

240、甲购买乙公司一批车辆,双方约定分期付款,乙公司交付了车辆,等到甲付完货款,车辆所有权归甲。为了防止甲不继续支付货款,乙公司在这些车辆上安装了定位监控系统。甲找丙通过技术手段破坏了定位监控系统后,将车辆变卖。丙构成?

- A.破坏计算机信息系统罪
- B.非法侵入计算机信息系统罪
- C.非法控制计算机信息系统罪
- D.帮助信息网络犯罪活动罪

【答案】A

【解析】

A项,相关司法解释认为,计算机信息系统,是指具备自动处理数据功能的系统,包括计算机、网络设备、通信设备、自动化控制设备的系统。本题出处:本题出自最高人民法院指导案例103号(徐强破坏计算机信息系统案)。裁判要旨:企业的机械远程监控系统属于计算机信息系统;违反国家规定,对企业的机械远程监控系统功能进行破坏,造成计算机信息系统不能正常运行,构成破坏计算机信息系统罪。基于此,本题中丙的行为构成破坏计算机信息系统罪(第286条)。B项,非法侵入计算机信息系统罪(第285条)。本罪的计算机信息系统,仅包括

国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统, 不包括一般的计算机信息系统。例如, 不包括一般公司企业的计算机信息系统。因此, B 项不入选。C 项, 非法控制计算机信息系统罪(第 285 条)。本罪的计算机信息系统, 是指国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统以外的一般的计算机信息系统。本题中, 丙实施的是破坏行为, 而非控制行为, 因此不构成非法控制计算机信息系统罪。C 项不入选。D 项, 帮助信息网络犯罪活动罪(第 287 条之二), 是指明知他人利用信息网络实施犯罪, 为其犯罪提供互联网接入、网络存储、通讯传输等技术支持的行为。丙不构成该罪。综上所述, 本题答案为 A。

241、①虚假诉讼罪是《刑法修正案(九)》新增的罪名;②普通公民通过虚假诉讼骗取他人财物,法官受骗作出判决,虚假诉讼行为人构成虚假诉讼罪与诈骗罪的想象竞合;③虚假诉讼行为人与审理法官串通,法官枉法裁决,虚假诉讼行为人构成虚假诉讼罪与诈骗罪的想象竞合;④虚假诉讼行为人没有与审理法官串通,法官明知真相仍枉法裁决,虚假诉讼行为人构成虚假诉讼罪,法官不构成虚假诉讼罪。下列哪一选项是正确的?

- A.①②③④均正确
- B.①②③正确,④错误
- C.①②正确,③④错误
- D.①正确,②③④错误

【答案】C

【解析】

第①句,说法正确。虚假诉讼罪是2015年《刑法修正案(九)》新增的罪名。第②句,说法正确。虚假诉讼行为人欺骗了法官,使法官做出对被告人不利判决,将被告人财产处分给行为人,构成三角诈骗,也即受骗人是法官,受害人是被告人。同时,虚假诉讼行为人也构成虚假诉讼罪。一个行为同时触犯两罪,属于想象竞合。第③句,例如,甲与法官串通,由甲提起虚假诉讼,由法官判被告人乙败诉,将乙的财产处分给甲。第一,甲构成虚假诉讼罪的实行犯,法官构成帮助犯,也即法官帮助甲一起欺骗法院。第二,法官构成枉法裁判罪的实行犯,甲构成教唆犯。第三,甲不构成诈骗罪,因为甲和法官勾结,甲没有欺骗法官。第四,乙的财产遭受损失,甲和法官应构成财产犯罪,具体而言是盗窃罪,也即,甲和法官通过平和手段,将乙占有的财物转移为甲占有。甲和法官构成虚假诉讼罪、枉法裁判罪、盗窃罪的共同犯罪,想象竞合,择一重罪论处。第③句认为,甲还构成诈骗罪。该说法错误。第④句,例如,甲提起虚假诉讼,欲欺骗法官,法官发现真相,但仍判处被告人乙败诉,将乙的财物处分给甲。甲不知道法官暗中相助。第一,甲构成虚假诉讼罪的实行犯,法官构成片面的帮助犯。第二,法官构成枉法裁判罪,但甲不构成该罪的教唆犯,因为甲没有教唆法官枉法裁判,甲以为法官受骗。第三,甲想欺骗法官,但法官未受骗,甲构成诈骗罪未遂,实务中对普通的诈骗罪未遂一般不予刑罚处罚。第四,甲取得财物这一环节构成盗窃罪,法官是盗窃罪的片面正犯。第④句认为,法官不构成虚假诉讼罪。该说法错误。法官构成虚假诉讼罪的片面的帮助犯。综上所述,本题答案为C。

242、甲、乙两村因水源发生纠纷。甲村 20 名村民手持铁锹等农具，在两村交界处强行修建引水设施。乙村 18 名村民随即赶到，手持木棍、铁锹等与甲村村民互相谩骂、互扔石块，甲村 3 人被砸成重伤。因警察及时疏导，两村村民才逐渐散去。关于本案，下列哪些选项是正确的？

- A.村民为争水源而斗殴，符合聚众斗殴罪的主观要件
- B.不分一般参加斗殴还是积极参加斗殴，甲、乙两村村民均触犯聚众斗殴罪
- C.因警察及时疏导，两村未发生持械斗殴，属于聚众斗殴未遂
- D.对扔石块将甲村 3 人砸成重伤的乙村村民，应以故意伤害罪论处

【答案】AD

【解析】

A 选项：《刑法》第 292 条规定的是聚众斗殴罪，是指聚集多人攻击对方身体或者互相攻击对方身体的行为。聚众斗殴罪要求行为人主观上是故意，村民明知是聚众斗殴的行为，但是仍然参与，即使村民的动机是为了争夺水源，并不影响聚众斗殴罪主观要件的认定。因此，A 选项正确。B 选项：刑法分则规定，聚众斗殴罪只有首要分子和其他积极参加者才成立本罪，一般参加者不成立本罪。故需区分一般参加斗殴还是积极参加斗殴，并非甲、乙两村村民均触犯聚众斗殴罪。因此，B 选项错误。C 选项：聚众斗殴罪是行为犯，只要实施了聚众斗殴的行为，即存在聚集多人进行斗殴的行为，则成立聚众斗殴罪。本案中，村民虽因警察的及时疏导，而未发生持械斗殴，但不影响之前的聚众斗殴行为构成聚众斗殴罪的既遂。因此，C 选项错误。D 选项：《刑法》第 292 条第 2 款规定：“聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条（故意伤害罪）、第二百三十二条（故意杀人罪）的规定定罪处罚。”该规定属于法律拟制，适用于直接造成死

亡的斗殴者和首要分子。故对扔石块将甲村 3 人砸成重伤的乙村村民，应以故意伤害罪论处。因此，D 选项正确。综上所述，本题答案为 AD。

243、甲在公园游玩时遇见仇人胡某，顿生杀死胡某的念头，便欺骗随行的朋友乙、丙说：“我们追逐胡某，让他出洋相。”三人捡起木棒追逐胡某，致公园秩序严重混乱。将胡某追到公园后门偏僻处后，乙、丙因故离开。随后甲追上胡某，用木棒重击其头部，致其死亡。关于本案，下列哪些选项是正确的？

- A.甲触犯故意杀人罪与寻衅滋事罪
- B.乙、丙的追逐行为是否构成寻衅滋事罪，与该行为能否产生救助胡某的义务是不同的问题
- C.乙、丙的追逐行为使胡某处于孤立无援的境地，但无法预见甲会杀害胡某，不成立过失致人死亡罪
- D.乙、丙属寻衅滋事致人死亡，应从重处罚

【答案】ABC

【解析】

寻衅滋事罪是指无事生非，起哄闹事，肆意挑衅，随意骚扰，破坏社会秩序的行为。根据《刑法》第 293 条的规定和最高人民法院、最高人民检察院 2013 年 7 月 15 日《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第 1 条的规定，甲让乙、丙和自己一起在公园用木棒追逐胡某导致公园秩序严重混乱的行为，符合寻衅滋事罪的构成要件，已经触犯了寻衅滋事罪。甲在乙、丙离开后，独自将胡某杀死的行为，还触犯了故意杀人罪，故 A 项正确。就本案而言，判断乙、丙的追逐行为能否产生救助胡某的义务，关键看乙、丙的追逐行为是否

对胡某制造了法益侵害危险,而不是看他们的追逐行为是否构成寻衅滋事罪。只要乙、丙的追逐行为对胡某制造了法益侵害危险,无论该追逐行为是否构成寻衅滋事罪,都会产生对胡某的救助义务。也就是说,乙、丙的追逐行为是否能够产生对胡某的救助义务和该行为是否构成寻衅滋事罪,没有必然联系,是两个不同的问题。B项正确。乙、丙从始至终都不知道甲具有杀害胡某的故意,也无法预见到甲会杀害胡某,对胡某的死亡既无故意,也无过失,既不成立故意杀人罪,也不成立过失致人死亡罪。C项正确。由于胡某的死亡和乙、丙的追逐行为之间不存在因果关系,所以也就谈不上乙、丙寻衅滋事致人死亡的问题。D项错误。

244、黑社会性质的组织应当同时具备下列哪些特征?

- A.形成稳定的犯罪组织,人数较多,有明确的组织者
- B.有组织地多次进行违法犯罪
- C.通过违法犯罪获取经济利益,具有经济实力
- D.有官员提供保护,为其称霸一方提供支持

【答案】ABC

【解析】

根据刑法 294 条规定,黑社会性质的组织应当同时具备以下特征:(1)形成较稳定的犯罪组织,人数较多,有明确的组织者、领导者,骨干成员基本固定;(2)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益,具有一定的经济实力,以支持该组织的活动;(3)以暴力、威胁或者其他手段,有组织地多次进行违法犯罪活动,为非作恶,欺

压、残害群众；(4)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。简言之，“黑社会性质组织”的界定标准：第一，具有稳定组织；第二，具有经济实力；第三，手段具有非法性、破坏性；第四，形成非法控制。注意：不要求必须有“政治保护伞”。综上所述，本题答案为 ABC。

245、甲于 2011 年借给乙 50 万元。一年后乙通过银行转账将 50 万元转给甲。因为有银行转账记录，乙未向甲索要回欠条。甲将欠条涂改为 2017 年借给乙 50 万元，并向法院起诉，要求乙还款（本息 52 万元）。乙以银行转账记录为证据，主张自己已经还款。法官经过调查，最终作出乙败诉的判决，判决乙应向甲还款 52 万元。关于本案，下列说法正确的有？

- A.甲的行为构成虚假诉讼罪与诈骗罪，两罪在一审判决作出时便既遂
- B.甲的行为构成诉讼诈骗，法官是受骗人，乙是受害人
- C.甲的行为构成虚假诉讼罪和诈骗罪的想象竞合
- D.法官虽然受骗，但是不构成民事枉法裁判罪

【答案】BCD

【解析】

虚假诉讼罪（第 307 条之一），是指以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的行为。根据司法解释，本罪的既遂标准有：(1)致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施的；(2)致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动的。本题中，甲以捏造的证据提起民事诉讼，导致人民法院开庭审理，便妨害了司法秩序。此时甲便构成虚假诉讼罪既遂。甲的

行为同时构成诈骗罪，法官是受骗人，乙是受害人，属于三角诈骗。这种三角诈骗发生在诉讼领域，又称为诉讼诈骗。甲的诈骗罪的既遂标准是骗取到财物。该既遂标准与虚假诉讼罪有所不同。根据刑法第 307 条之一规定，构成虚假诉讼罪的同时，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成诈骗罪的，属于想象竞合，择一重罪论处。民事枉法裁判罪，是指司法工作人员在民事、行政审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判，情节严重的行为。该罪是故意犯罪。本题中，法官不是故意枉法裁判，而是受骗，因此不构成民事枉法裁判罪。综上所述，本题答案为 BCD。

246、关于行为人的行为定性，下列说法正确的有？

- A.甲诈骗丙的钱款，丙受骗将钱款汇入甲的银行账户。甲告知乙真相，让乙拿着自己的银行卡到 ATM 机上取出该笔钱款现金。乙的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪
- B.乙因涉嫌受贿罪被监察委留置，在留置期间脱逃。乙的行为不构成脱逃罪
- C.甲非法吸收公众存款 3 亿元。乙明知该款系甲非法吸收公众存款所得，还帮助甲换汇并汇往境外。乙的行为构成洗钱罪
- D.被执行人甲，以虚假诉讼的方式将财产转移给乙，以逃避执行。甲构成虚假诉讼罪和拒不执行判决罪的想象竞合

【答案】ACD

【解析】

A 项：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（第 312 条），是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。根据司法解释规定，其他方法包括：

居间介绍，买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等。本题中，乙帮助甲，将甲的犯罪所得的钱款取现，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。A 选项正确。B 项，脱逃罪（第 316 条第 1 款），是指依法被关押的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人脱逃的行为。关于监察机关的留置措施，《监察法》第 22 条规定：“被调查人涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪，监察机关已经掌握其部分违法犯罪事实及证据，仍有重要问题需要进一步调查，并有下列情形之一的，经监察机关依法审批，可以将其留置在特定场所：（一）涉及案情重大、复杂的；（二）可能逃跑、自杀的；（三）可能串供或者伪造、隐匿、毁灭证据的；（四）可能有其他妨碍调查行为的。对涉嫌行贿犯罪或者共同职务犯罪的涉案人员，监察机关可以依照前款规定采取留置措施。留置场所的设置、管理和监督依照国家有关规定执行。”第 29 条规定：“依法应当留置的被调查人如果在逃，监察机关可以决定在本行政区域内通缉，由公安机关发布通缉令，追捕归案。通缉范围超出本行政区域的，应当报请有权决定的上级监察机关决定。”根据上述规定，被监察机关采取留置的犯罪嫌疑人属于依法被关押的犯罪嫌疑人。因此乙在留置期间脱逃构成脱逃罪。B 选项错误。C 项，洗钱罪（第 191 条），是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的行为：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转

换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪的上游犯罪有破坏金融管理秩序犯罪。非法吸收公众存款罪属于破坏金融管理秩序犯罪中的一个罪名，因此属于洗钱罪的上游犯罪。乙帮助甲换取外汇，并汇往境外，属于洗钱罪的行为方式，因此构成洗钱罪。洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪是特殊法条与一般法条的法条竞合关系，优先认定为特殊法条也即洗钱罪。C 选项正确。D 项，（1）虚假诉讼罪（第 307 条之一），是指以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的行为。根据司法解释规定，“以捏造的事实提起民事诉讼”，包括：与被执行人恶意串通，捏造债权或者对查封、扣押、冻结财产的优先权、担保物权的。实施本罪，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成诈骗罪，职务侵占罪，拒不执行判决、裁定罪，贪污罪等犯罪的，择一重罪论处。（2）拒不执行判决、裁定罪（第 313 条），是指对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的行为。具体行为方式主要有隐藏、转移财产。本题中，甲一方面构成拒不执行判决罪，另一方面构成虚假诉讼罪，属于一个行为同时触犯两个罪名，想象竞合，择一重罪论处。D 选项正确。综上所述，本题答案为 ACD。

247、套路贷是以非法占有为目的，假借民间借贷之名诱使、迫使被害人签订借贷或变相借贷、抵押、担保等相关协议，通过虚增借贷金额，恶意制造违约，肆意认定违约，毁匿还款证据等方式，形成虚假债权债务，并采用暴力威胁等非法手

段，占有被害人的财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。下列说法正确的有？

- A. 套路贷既可能构成诈骗，也可能构成敲诈勒索罪，过程中可能构成非法拘禁罪、虚假诉讼罪、寻衅滋事罪、绑架罪
- B. 平等主体之间基于自由意志形成的民间借贷关系，出借人要求借款人按照协议约定内容还款付息的，不属于套路贷
- C. 明知他人实施套路贷，而组织发送贷款信息、广告，吸引、介绍他人贷款的，构成共犯
- D. 因套路贷产生的利息、保险金、中介费、服务费、违约金等名目，被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物，应计入套路贷的犯罪数额中

【答案】ABCD

【解析】

2019年4月9日最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》规定：第一，“套路贷”，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁置还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。第二，“套路贷”与平等主体之间基于意思自治而形成的民事借贷关系存在本质区别，民间借贷的出借人是为了到期按照协议约定的内容收回本金并获取利息，不具有非法占有他人财物的，也不会签订、履行借贷协议过程中实施虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹、恶意制造违约、肆意认定违约、毁置还款证据等行为第三，实施“套路贷”过程中，未采用明显的暴力或者威胁手段，其行为

特征从整体上表现为以非法占有为目的,通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的,一般以诈骗罪定罪处罚;对于在实施“套路贷”过程中多种手段并用,构成诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼、寻衅滋事、强迫交易、抢劫、绑架等多种犯罪的,应当根据具体案件事实,区分不同情况,依照刑法及有关司法解释的规定数罪并罚或者择一重处罚。第四,明知他人实施“套路贷”犯罪,具有以下情形之一的,以相关犯罪的共犯论处:(1)组织发送“贷款”信息、广告,吸引、介绍被害人“借款”的;(2)提供资金、场所、银行卡、账号、交通工具等帮助的;(3)出售提供、帮助获取公民个人信息的;(4)协助制造走账记录等虚假给付事实的;(5)协助办理公证的;(6)协助以虚假事实提起诉讼或者仲裁的;(7)协助套现、取现、办理动产或不动产过户等,转移犯罪所得及其产生的收益的。第五,在认定“套路贷”犯罪数额时,应当与民间借贷相区别,从整体上予以否定性评价,“虚高债务”和以“利息”“保证金”“中介费”“服务费”“违约金”等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物,均应计入犯罪数额。犯罪嫌疑人、被告人实际给付被害人的本金数额,不计入犯罪数额。综上所述,本题答案为ABCD。

248、甲的下列哪些行为成立帮助毁灭证据罪(不考虑情节)?

- A.甲、乙共同盗窃了丙的财物。为防止公安人员提取指纹,甲在丙报案前擦掉了两人留在现场的指纹
- B.甲、乙是好友。乙的重大贪污罪行被丙发现。甲是丙的上司,为防止丙作证,将丙派往境外工作
- C.甲得知乙放火致人死亡后未清理现场痕迹,便劝说乙回到现场毁灭证据
- D.甲经过犯罪嫌疑人乙的同意,毁灭了对乙有利的无罪证据

【答案】CD**【解析】**

A 项，帮助毁灭证据罪毁灭的是他人作为当事人的案件的证据。毁灭自己是当事人的案件的证据的，因为缺乏期待可能性，不构成本罪。在共同犯罪的场合，如果专门为了本人或者既为本人，也为其他共犯人毁灭证据，同样因为缺乏期待可能性而不成立本罪。当然，如果行为人所毁灭的证据在客观上仅对（或者主要对）其他当事人起作用，或者行为人主观上专门（或主要）为了其他人而毁灭证据，则存在期待可能性，应认定为帮助毁灭证据罪。A 项中，甲乙属于共同犯罪，甲毁灭的是两人留在现场的指纹，属于既为本人，也为其他共犯人毁灭证据，缺乏期待可能性，不成立本罪。故 A 项不应选。B 项，帮助毁灭证据罪中的“证据”，应限于物证、书证、鉴定结论、勘验、检查笔录与视听资料，物体化（转化为书面或者视听资料）的证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等（当然，在查证属实之前，所谓的“证据”实际上是证据资料或者证据的原始素材。）隐匿证人与被害人的行为，符合妨害作证罪的构成要件（阻止证人作证），而不以本罪论处。B 项中，甲为防止丙作证，将丙派往境外的行为属于隐匿证人的行为，不构成本罪。B 项不应选。C 项，帮助毁灭证据罪包括：第一，行为人单独为当事人毁灭证据的；第二，行为人与当事人共同毁灭证据，在这种情况下，行为人与当事人并不成立共犯；第三，行为人为当事人毁灭证据提供各种便利条件，在这种情况下，行为人并不是帮助犯，而是正犯；第四，行为人唆使当事人毁灭证据，在这种情况下，行为人并不是教唆犯，而是正犯（实行犯）。C 项中，甲劝说乙回到现场毁灭证据的行为，属于帮助当事人毁灭证据的方式之一，构成本罪。C 项应选。D 项，在刑事诉讼中，由于举证责任在公诉一方，而公诉

方也有义务收集被告人无罪、罪轻的证据。因此，即使经过犯罪嫌疑人、被告人同意，帮助其毁灭无罪证据，也妨害了刑事司法的客观公正性，应当认定为帮助毁灭证据罪。D项应选。本题答案为C、D。

249、关于毒品犯罪，下列哪些选项是正确的？

- A.甲无牟利目的，为江某代购仅用于吸食的毒品，达到非法持有毒品罪的数量标准。对甲应以非法持有毒品罪定罪
- B.乙为蒋某代购仅用于吸食的毒品，在交通费等必要开销之外收取了若干“劳务费”。对乙应以贩卖毒品罪论处
- C.丙与曾某互不知情，受雇于同一雇主，各自运输海洛因500克。丙将海洛因从一地运往另一地后，按雇主吩咐交给曾某，曾某再运往第三地。丙应对运输1000克海洛因负责
- D.丁盗窃他人200克毒品后，将该毒品出卖。对丁应以盗窃罪和贩卖毒品罪实行数罪并罚

【答案】ABD

【解析】

A选项：《全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》：“有证据证明行为人不以牟利为目的，为他人代购仅用于吸食的毒品，毒品数量超过刑法第三百四十八条规定的最低数量标准的，对托购者、代购者应以非法持有毒品罪定罪。代购者从中牟利，变相加价贩卖毒品的，对代购者应以贩卖毒品罪定罪。”依据上述规定，甲无牟利目的，为江某代购仅用于吸食的毒品，达到非法持有毒品罪的数量标准。甲触犯非法持有毒品罪定罪。因此，A选项正确。B选项：乙收取的若干“劳务费”属于必要开销之外的费用，系变相的贩卖，触犯贩卖毒品罪。因

此，B 选项正确。C 选项：两人以上同行运输毒品的，应当从是否明知他人带有毒品，有无共同运输毒品的意思联络，有无实施配合、掩护他人运输毒品的行为等方面综合审查认定是否成立共同犯罪。丙与曾某互不知情，各自运输，相互独立，不成立共同犯罪，丙只对自己运输的 500 克负责，不对曾某运输的 500 克负责。因此，C 选项错误。D 选项：丁盗窃他人 200 克毒品，触犯盗窃罪；之后将该毒品出卖的行为，侵犯了新的法益，其触犯贩卖毒品罪，丁实施了两个行为触犯了两罪，应数罪并罚。因此，D 选项正确。综上所述，本题答案为 ABD。

250、关于毒品犯罪，下列哪些选项是正确的？

- A.甲容留未成年人吸食、注射毒品，构成容留他人吸毒罪
- B.乙随身携带藏有毒品的行李入关，被现场查获，构成走私毒品罪既遂
- C.丙乘广州至北京的火车运输毒品，快到武汉时被查获，构成运输毒品罪既遂
- D.丁以牟利为目的容留刘某吸食毒品并向其出卖毒品，构成容留他人吸毒罪和贩卖毒品罪，应数罪并罚

【答案】ABCD

【解析】

A 选项：容留他人吸食、注射毒品，是指允许他人在自己事先管理、支配的场所吸食、注射毒品或者为他人吸食、注射毒品提供场所的行为。对容留的对象没有限制。故容留未成年人吸食、注射毒品的，当然构成容留他人吸毒罪。因此，A 选项正确。B 选项：《关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第 23 条规定，实施走私犯罪，具有下列情形之一的，应当认定为犯罪既遂：①在海关监管现场被查获的；②以虚假申报方式走私，申报行为实施完毕的；③以保税货物或者特定减税、免税进口的货物、物品为对象走私，在境内销售的，或者申请

核销行为实施完毕的。在本案中，故“乙随身携带藏有毒品的行李入关，被现场查获，”系在海关监管现场被查获的情形，满足上述司法解释中第一种情形，其行为成立走私毒品罪既遂。因此，B选项正确。C选项：刑法理论上的运输毒品罪是指在我国领域内通过携带、邮寄、利用他人或者使用交通工具等方式转移毒品得行为。在运输毒品的行为中行为人使得毒品离开原处或行为人使毒品的存放地发生转移的，则认定为既遂。在本案中，行为人丙乘坐广州至北京的火车而运输毒品，当快到武汉时被查获，满足在运输毒品的行为中行为人使得毒品离开原处或行为人使毒品的存放地发生转移的要求，其成立运输毒品罪既遂。因此，C选项正确。D选项：《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第12条第2款规定，向他人贩卖毒品后又容留其吸食、注射毒品，或者容留他人吸食、注射毒品并向其贩卖构成犯罪的，以贩卖毒品罪和容留他人吸毒罪数罪并罚。丁以牟利为目的容留刘某吸食毒品并向其出卖毒品，同时触犯容留他人吸毒罪和贩卖毒品罪，应数罪并罚。因此，D选项正确。综上所述，本题答案为ABCD。

251、李某制造50克海洛因，运输30克甲基苯丙胺，贩卖500克鸦片。下列说法正确的有？

- A.如果被判十年以上有期徒刑或无期徒刑，则不得假释
- B.在量刑上，可将500克鸦片折算为海洛因的数量
- C.在量刑上，可以不考虑毒品种类，以580克毒品量刑
- D.应以贩卖、运输、制造毒品罪定罪处罚，不数罪并罚

【答案】BD

【解析】

A项：刑法规定，禁止假释的对象：一是累犯；二是因故意杀人、强奸、抢劫、

绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处10年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子。毒品犯罪不是这些暴力性犯罪。因此，李某如果被判10年以上有期徒刑，有可能适用假释。A项说法错误。B项：司法解释规定，走私、贩卖、运输制造、非法持有两种以上毒品的，可以将不同种类的毒品分别折算为海洛因的数量，以折算后累加的毒品总量作为量刑的根据。B项说法正确。C项：刑法第347条规定：“走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量的。”这表明在量刑时需要按照不同毒品的种类来考虑，但是可以将不同种类的毒品分别折算为海洛因的数量。因此在数量上不应当以总的“毒品”来计算。C项说法错误。D项：走私、贩卖、运输、制造的毒品，如果是同一宗毒品，在数量上不重复计算；如果是不同宗毒品，在数量上需要累加计算。不过无论是否同宗毒品，在定罪上都只定走私、贩卖、运输、制造毒品罪，不数罪并罚，因为该罪名是选择性罪名。D项说法正确。综上所述，本题答案为BD。

252、关于赌博犯罪,下列说法正确的有?

- A.甲以营利为目的,邀请人员加入微信群,利用微信群进行控制管理,以抢红包方式进行赌博,以开设赌场罪论处
- B.乙以营利为目的,邀请人员加入微信群,根据竞猜游戏网站的开奖结果“比大小”等方式进行赌博,利用微信群进行控制管理,以开设赌场罪论处。
- C.丙为某境外赌博网站提供资金结算服务,以开设赌场罪的共犯论处
- D.丁组织我国境内旅游团赴境外旅游,期间组织旅游团成员进入当地合法赌场参与赌博。丁构成开设赌场罪

【答案】ABC**【解析】**

A 项,本题出自最高人民法院第 106 号指导案例(谢某开设赌场案)。题干表述就是裁判要旨。因此,A 项说法正确。B 项,本题出自最高人民法院第 105 号指导案例(洪某开设赌场案)。题干表述就是裁判要旨。因此,B 项说法正确。C 项,根据司法解释规定,明知是赌博网站(包括境内赌博网站和境外赌博网站),而为其提供技术支持、资金结算等帮助,构成开设赌场罪的共犯(帮助犯)。因此,C 项说法正确。D 项,此前有司法解释将丁的行为认定为开设赌场罪。但是,2021 年 3 月 1 日《刑法修正案(十一)》增设了组织参与国(境)外赌博罪后,该司法解释自然失效,对丁的行为应认定为组织参与国(境)外赌博罪。因此,D 项说法错误。综上所述,本题答案为 A.B.C。

253、关于网络犯罪,下列说法正确的有?

- A.乙以为甲可能利用网络实施诈骗,为甲提供了网络接入服务。实际上,甲根本未实施犯罪。乙构成帮助信息网络犯罪活动罪
- B.乙明知甲欲利用网络实施诈骗,仍为其提供了网络接入服务。甲利用了乙的网络接入服务实施了诈骗罪。乙构成帮助信息网络犯罪活动罪和诈骗罪(帮助犯),想象竞合,择一重罪论处
- C.甲为了实施网络诈骗,建立了 10 个微信群,成员有 2000 人。甲准备实施诈骗时被公安机关抓捕。甲构成非法利用信息网络罪
- D.某民营公司职员甲无权登录公司的某个网络系统,利用技术手段偷偷登录,获取公司采取保密措施的客户名单(十几位客户),然后离职,联系相关客户,让客户选择与自己合作。甲构成侵犯商业秘密罪

【答案】BCD**【解析】**

考点：妨害社会管理秩序罪（1）：扰乱公共秩序罪 A 项，帮助信息网络犯罪活动罪的成立，应遵守共犯从属性原则。也即，如果实行者不构成犯罪，则帮助者不构成帮助信息网络犯罪活动罪。因此，乙不构成帮助信息网络犯罪活动罪。A 项说法错误。B 项，甲构成诈骗罪的实行犯。乙提供帮助，一方面构成诈骗罪的帮助犯，另一方面构成帮助信息网络犯罪活动罪，想象竞合，择一重罪论处。B 项说法正确。C 项，根据刑法第 287 条之一规定，设立用于实施诈骗犯罪的通讯群组，情节严重的，构成非法利用信息网络罪。根据司法解释，建立了 10 个微信群，成员有 2000 人，属于情节严重。因此，甲构成非法利用信息网络罪。不难看出，非法利用信息网络罪是将诈骗罪的预备行为作为独立罪名来认定。C 项说法正确。D 项，（1）公司采取保密措施的客户名单和相关信息，是公司的商业秘密。甲通过电子侵入的方式非法获取该商业秘密，构成侵犯商业秘密罪。（2）甲不构成非法侵入计算机信息系统罪，因为该罪的系统要求是国家事务、国防建设方面的系统。（3）甲不构成非法获取计算机信息系统数据罪，因为该罪的数据要求达到一定的数量。（4）甲不构成非法利用信息网络罪，因为该罪的行为方式要求设立网站、群组、发布消息等。甲没有实施这些行为。D 项说法正确。综上所述，本题答案为 BCD。

254、某旅游公司法定代表人王某组织 12 人偷越国边境，王某让下属吴某将 12 人带至国内边境某城市，然后将人分成两组，由甲带领其中 7 人，由乙带领其中 5 人，分别偷越边境。甲带领这组人顺利偷越了边境。乙带领的这组人尚未出境便被抓。下列说法正确的有？

- A.甲构成犯罪既遂
- B.王某和吴某构成犯罪既遂
- C.乙构成犯罪既遂
- D.本案应按照单位犯罪处理

【答案】AB

【解析】

考点：妨害社会管理秩序罪（3）：妨害国（边）境管理罪 A 项，组织偷越国（边）境罪的既遂标准是，被组织者非法出境或入境。甲构成该罪既遂。A 项说法正确。B 项，王某、吴某与甲构成共同犯罪，根据“部分实行、全部负责”原则，当甲构成犯罪既遂，则王某、吴某也构成犯罪既遂。B 项说法正确。C 项，甲、乙相互之间不构成共同犯罪。第一，甲、乙只是王某的“马仔”，只是执行者的角色，并不是领导层成员。第二，甲、乙各自分别执行，对对方的执行任务并没有提供物理性的贡献。第三，甲、乙虽然在主观上可能知道对方和自己一样，在组织偷渡，但是这种“知道”并不会给自己或对方产生实质的心理性贡献。第四，如果组织中的某个成员知道其他成员在犯罪，便让其对其他成员的犯罪负责，则与该成员的角色地位明显不符。因此，乙不用对甲的既遂结果负责，乙构成犯罪未遂。C 项说法错误。D 项，组织偷越国（边）境罪是自然人犯罪，不是单位犯罪。即使是单位行为，也仅对主管人员和其他直接责任人追究自然人的刑事责任。D 项说法错误。综上所述，本题答案为 AB。

255、关于运输毒品罪，下列说法正确的有？

A.刘某为了自己吸食毒品，向张某购买了毒品，给张某发送了收件地址。张某顺利将毒品寄了过来。尽管刘某没有亲自运输毒品，但依然构成运输毒品罪的共犯

B.马某携带毒品前往某地，准备交给赵某，到了该地后未能联系到赵某，又携带毒品返回原地。马某构成运输毒品罪的既遂

C.张某发现某种电子烟中的大麻素能够使人精神成瘾，但不知道其具体成分，仍出售这种电子烟。张某构成贩卖毒品罪

D.李某为了吸食，在外地购买毒品，携带毒品回程，中途被警方抓住。李某构成运输毒品罪

【答案】BCD

【解析】

考点：妨害社会管理秩序罪（7）：走私、贩卖、运输、制造毒品罪 A 项，刑法不处罚为了自己吸食的购买毒品行为。例如，甲为了自己吸食，向乙购买毒品，乙向甲出售毒品。乙构成贩卖毒品罪，甲不构成贩卖毒品罪的共犯（教唆犯、帮助犯）。同理，本题中，张某构成贩卖、运输毒品罪，但刘某不构成贩卖、运输毒品罪的共犯。A 项说法错误。B 项，运输毒品罪的既遂标准是，毒品离开原存放地，发生较长距离的位移。马某运输毒品，发生较长距离的位移，便构成运输毒品罪。至于未能找到接收者，不影响既遂的成立。B 项说法正确。C 项，贩卖毒品罪的行为对象是“毒品”，毒品是指能够使人精神成瘾的精神药品。张某只要认识到大麻素是能够使人精神成瘾的物品，就认识到贩卖这种物品会产生危害社会的结果，便具有了贩卖毒品罪的犯罪故意，构成贩卖毒品罪。至于张某不知道大麻素的具体成分，不知道大麻素已经属于“毒品”，这一点并不重要。“毒品”只是对能够使人成瘾的精神药品的一种称谓、名称。这种称谓、名称不需要行为人认识到。行为人需要认识到的是物品的实质特征。例如，狗蛋认为自己贩卖的是“毛片”，声称自己没有认识到贩卖的是“淫秽物品”。但是，狗蛋只要

认识到自己贩卖的物品是露骨描述性器官、性行为、专门刺激人性欲的影像制品，便具有贩卖淫秽物品的犯罪故意。C项说法正确。D项，实际上，为了自己吸食而运输毒品，应定非法持有毒品罪。但是，司法解释规定，为了自己吸食而运输毒品，定运输毒品罪。答案应以司法解释为准。因此，李某构成运输毒品罪，并且，已经使毒品发生较长距离的位移，构成运输毒品罪既遂。D项说法正确。综上所述，本题答案为BCD。

256、下列情形，构成危害公共安全犯罪的有？

- A.盗窃井盖，导致车辆发生交通事故，致多人伤亡
- B.公交司机驾驶途中与乘客互殴，致多人伤亡
- C.乘客抢夺公共汽车方向盘，致多人伤亡
- D.高空抛燃烧的蜂窝煤球，引发火灾，致多人伤亡

【答案】ABCD

【解析】

这里的“公共”，是指公众（多数人或不特定人）。危害公共安全，是指危险的危及范围无法预料，具有危及多数人的可能性。A项，2020年《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于印发《关于办理涉窨井盖相关刑事案件的指导意见》的通知》第1条规定，盗窃、破坏正在使用中的社会机动车通行道路上的窨井盖，足以使汽车、电车发生倾覆、毁坏危险，尚未造成严重后果的，依照刑法第一百一十七条的规定，以破坏交通设施罪定罪处罚；造成严重后果的，依照刑法第一百一十九条第一款的规定处罚。A选项中盗窃井盖导致车辆发生交通事故，应当以破坏交通设施罪定罪处罚，属于危害公共安全犯罪。BC项，《刑法修正案十一》在《刑法》中新增第133条之二：对行驶中的公共交通工具的驾驶人员

使用暴力或者抢控驾驶操纵装置,干扰公共交通工具正常行驶,危及公共安全的,处一年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。前款规定的驾驶人员在行驶的公共交通工具上擅离职守,与他人互殴或者殴打他人,危及公共安全的,依照前款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。因此 BC 选项中司机和乘客的行为符合 133 条之二的规定,同时造成严重结果,构成以危险方法危害公共安全罪,最终以处罚较重的以危险方法危害公共罪定罪处罚。应注意,在《刑法修正案十一》之前,有司法解释规定,下列行为构成以危险方法危害公共安全罪:第一,乘客在公共交通工具行驶过程中,抢夺方向盘、变速杆等操纵装置,殴打、拉拽驾驶人员,危害公共安全。第二,司机在公共交通工具行驶过程中,与乘客厮打、互殴,危害公共安全。D 项,《刑法修正案十一》在《刑法》中新增第 291 条之二:从建筑物或者其他高空抛掷物品,情节严重的,处一年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。有前款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。高空抛掷燃烧的蜂窝煤引发火灾致人伤亡,符合第 291 条之二的规定,构成该罪。同时引发火灾造成严重危害结果,构成放火罪。最终应当以处罚较重的放火罪定罪处罚。应当注意,在《刑法修正案十一》之前,按照司法解释的特别规定,即使高空抛的不是燃烧物,而是普通物品,只要对楼下人有具体危险,比如楼下有人走来走去,则这种高空抛物行为构成以危险方法危害公共安全罪。

257、甲为教育局工作人员,负责保管当年高考试题。乙通过甲取得部分高考题目(约占总题量 60%,属于国家秘密)并秘密出售,联系到买家张某、李某、宋某三人,书面约定考完后每人向乙支付人民币 15 万元。事后查明乙还曾在 2014 年的执业药师职业资格考试和 2017 年 GRE (美国研究生入学考试) 中

组织多名考生作弊。下列说法中错误的是：

- A.甲触犯非法提供试题罪、故意泄露国家秘密罪，应当数罪并罚；
- B.乙触犯非法出售试题罪，属于“情节严重”的情形；
- C.乙在 2014 年执业药师职业资格考试中组织多人作弊的行为，根据刑修（九）之前的规定应当以非法获取国家秘密罪追究刑事责任，但按照修正后的规定处罚较轻的，应当适用修正后的规定；
- D.乙在 2017 年 GRE 考试中组织多人作弊的行为触犯组织考试作弊罪

【答案】AD

【解析】

本题中，高考试题既属于法律规定的国家考试的试题，又属于国家秘密。甲作为教育局工作人员，将自己保管的高考试题提供给乙，属于一行为同时触犯非法提供试题罪和故意泄露国家秘密罪两项罪名的情形，应当择一重处而非数罪并罚，A 错误；乙将非法获得的试题秘密出售，其行为触犯非法出售试题罪，虽然试题与真题内容不完全一致，但并不影响该罪名的成立。其违法所得超过 30 万元，属于“情节严重”的情形，B 正确；根据《最高人民法院关于〈中华人民共和国刑法修正案(九)〉时间效力问题的解释》1 规定，对于 2015 年 10 月 31 日以前组织考试作弊，为他人组织考试作弊提供作弊器材或者其他帮助，以及非法向他人出售或者提供考试试题、答案，根据修正前刑法应当以非法获取国家秘密罪、非法生产、销售间谍专用器材罪或者故意泄露国家秘密罪等追究刑事责任的，适用修正 1《最高人民法院关于〈中华人民共和国刑法修正案(九)〉时间效力问题的解释》（2015 年 10 月颁布）前刑法的有关规定。但是，根据修正后刑法第二百八十四条之一的规定处刑较轻的，适用修正后刑法的有关规定。即适用“从

旧兼从轻”原则，C 正确；GRE 考试不属于法律规定的国家考试，在此类考试中组织多人作弊不构成组织考试作弊罪，D 错误。

258、甲将私家车借给无驾照的乙使用。乙夜间驾车与其叔丙出行，途中遇刘某过马路，不慎将其撞成重伤，车辆亦受损。丙下车查看情况，对乙谎称自己留下打电话叫救护车，让乙赶紧将车开走。乙离去后，丙将刘某藏匿在草丛中离开。刘某因错过抢救时机身亡。（事实一）为逃避刑事责任，乙找到有驾照的丁，让丁去公安机关“自首”，谎称案发当晚是丁驾车。丁照办。公安机关找甲取证时，甲想到若说是乙造成事故，自己作为被保险人就无法从保险公司获得车损赔偿，便谎称当晚将车借给了丁。（事实二）后甲找到在私营保险公司当定损员的朋友陈某，告知其真相，请求其帮忙向保险公司申请赔偿。陈某遂向保险公司报告说是丁驾车造成事故，并隐瞒其他不利于甲的事实。甲顺利获得 7 万元保险赔偿。

（事实三）关于事实二的分析，下列选项错误的是：

- A.伪证罪与包庇罪是相互排斥的关系，甲不可能既构成伪证罪又构成包庇罪
- B.甲的主观目的在于骗取保险金，没有妨害司法的故意，不构成妨害司法罪
- C.乙唆使丁代替自己承担交通肇事的责任，就此构成教唆犯
- D.丁的“自首”行为干扰了司法机关的正常活动，触犯包庇罪

【答案】ABC

【解析】

A 选项：《刑法》第 133 条规定的伪证罪是指在刑事诉讼中，证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译，意图陷害他人或者隐匿罪证的行为。《刑法》第 310 条规定的窝藏、包庇罪是指明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的行

为。可以看出，两罪中都有作假证明的行为，即一个行为可同时触犯伪证罪与包庇罪，故伪证罪与包庇罪不是对立关系（相互排斥关系）。当一个行为同时触犯伪证罪与包庇罪时，应当按想象竞合犯处理。因此，A 选项错误。B 选项：甲为了从保险公司获取保险金而向公安机关谎称将车借给丁，其主观上并无包庇乙的目的，但是其应当认识到自己为乙作假证明的行为可能会导致公安机关无法追捕乙，即妨害司法活动的正常进行，但甲对此持放任的态度，因此可认为甲主观上具有妨害司法的间接故意，其行为也导致了妨害司法活动正常进行的结果，因此构成妨害司法罪。因此，B 选项错误。C 选项：乙无证驾驶并刘某撞成重伤，存在违反交通运输管理法规且发生重大事故的行为，构成交通肇事罪。乙在事后为逃避刑事责任，而让有驾照的丁去公安机关代替其承担责任，该行为应当认定为不可罚的事后行为，犯罪分子在犯罪后隐匿自己罪证的行为不具有期待可能性，不必再行惩罚。因此，C 选项错误。D 选项：《刑法》第 310 条规定的窝藏、包庇罪是指明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的行为。丁为包庇乙而向公安机关谎称自己是肇事者，这使得公安机关的正常司法活动受到干扰，司法机关难以将乙列入犯罪嫌疑人的范围来追究其责任，丁作假证明包庇乙的行为扰乱了公安机关正常查案的秩序，构成包庇罪。因此，D 选项正确。综上所述，本题答案为 ABC。

259、某小区五楼刘某家的抽油烟机发生故障，王某与李某上门检测后，决定拆下搬回维修站修理。刘某同意。王某与李某搬运抽油烟机至四楼时，王某发现其中藏有一包金饰，遂暗自将之塞入衣兜。（事实一）王某与李某将抽油烟机搬走后，刘某想起自己此前曾将金饰藏于其中，追赶前来，见王某神情可疑，便要其返还金饰。王某为洗清嫌疑，乘乱将金饰转交李某，李某心领神会，接过金饰藏于裤

兜中。刘某确定王某身上没有金饰后，转身再找李某索要。李某突然一拳击倒刘某，致其倒地重伤。李某与王某随即逃走。(事实二)后王某建议李某将金饰出售，得款二人平分，李某同意。李某明知金饰价值 1 万元，却向亲戚郭某谎称金饰为朋友委托其出售的限量版，售价 5 万元。郭某信以为真，花 5 万元买下金饰。拿到钱后，李某心生贪念，对王某称金饰仅卖得 1 万元，分给王某 5000 元。(事实三)关于事实二的分析，下列选项正确的是？

- A.李某接过金饰，协助王某拒不返还他人财物，构成侵占罪的帮助犯
- B.李某帮助王某转移犯罪所得的金饰，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪
- C.李某为窝藏赃物将刘某打伤，属事后抢劫，构成抢劫(致人重伤)罪
- D.王某利用李某打伤刘某的行为顺利逃走，也属事后抢劫，构成抢劫罪

【答案】B

【解析】

A.B 选项：王某的犯罪行为已经既遂，李某事后为王某掩饰、隐瞒犯罪所得赃物，成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪。不构成王某先前犯罪行为的共犯。因此，A 选项错误，B 选项正确。C 选项：李某的行为触犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。因为其行为不符合事后抢劫的前提条件，所以即使为窝藏赃物而将刘某打伤，也不成立事后抢劫罪，同理，李某也不构成抢劫罪（致人重伤）。因此，C 选项错误。D 选项：在本案中，在客观上，李某虽然对刘某实施了暴力的犯罪行为，但在主观上王某并没有利用李某的行为来实现其窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证的目的，故王某的行为非系事后抢劫的情形，未触犯抢劫罪。因此，D 选项错误。综上所述，本题答案为 B。

260、某地政府为村民发放扶贫补贴，由各村村委会主任审核本村申请材料并分

发补贴款。某村村委会主任王某、会计刘某以及村民陈某合谋伪造申请材料，企图每人套取 5 万元补贴款。王某任期届满，周某继任村委会主任后，政府才将补贴款拨到村委会。周某在分发补贴款时，发现了王某、刘某和陈某的企图，便只发给三人各 3 万元，将剩余 6 万元据为己有。三人心知肚明，但不敢声张。(事实一)后周某又想私自非法获取土地征收款，欲找县国土局局长张某帮忙，遂送给县工商局局长李某 10 万元，托其找张某说情。李某与张某不熟，送 5 万元给县财政局局长胡某，让胡某找张某。胡某找到张某后，张某碍于情面，违心答应，但并未付诸行动。(事实二)周某为感谢胡某，从村委会账户取款 20 万元购买玉器，并指使会计刘某将账做平。周某将玉器送给胡某时，被胡某拒绝。周某只好将玉器退还商家，将退款 20 万元返还至村委会账户，并让刘某再次平账。(事实三)关于事实三的分析，下列选项正确的是？

- A.周某挪用村委会 20 万元购买玉器行贿，属挪用公款进行非法活动，构成挪用公款罪
- B.周某使用村委会 20 万元购买玉器，属贪污行为，但后又将 20 万元还回，构成犯罪中止
- C.刘某第一次帮周某将账面做平，属于帮周某成功实施犯罪行为，与周某构成共同犯罪
- D.刘某第二次帮周某将账面做平，属于作假证明掩护周某的犯罪行为，构成包庇罪

【答案】C

【解析】

挪用公款罪，是指国家工作人员利用职务上的便利挪用公款归个人使

用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过3个月未还的行为。周某挪用村委会20万元购买玉器行贿不具有归还意思，主观上不是挪用的目的而是非法占有的目的，构成贪污罪。选项A错误。周某将村委会20万元取出后即构成贪污罪的既遂，犯罪既遂以后不再有犯罪中止。选项B错误。刘某第一次帮助周某做假账的行为，与周某构成贪污罪的共同犯罪，选项C正确。《刑法》第310条规定：“明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。刘某第二次帮周某将假账做平的行为构成周某的犯罪的共同犯罪而不构成包庇罪。选项D错误。

261、乙（15周岁）在乡村公路驾驶机动车时过失将吴某撞成重伤。乙正要下车救人，坐在车上的甲（乙父）说：“别下车！前面来了许多村民，下车会有麻烦。”乙便驾车逃走，吴某因流血过多而亡。关于本案，下列哪一选项是正确的？

- A.因乙不成立交通肇事罪，甲也不成立交通肇事罪
- B.对甲应按交通肇事罪的间接正犯论处
- C.根据司法实践，对甲应以交通肇事罪论处
- D.根据刑法规定，甲、乙均不成立犯罪

【答案】C

【解析】

A.C.D选项：《刑法》第133条规定的交通肇事罪是指违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公司财产遭受重大损失的行为。根据

《刑法》第17条第2款的规定：“已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。”说明14—16周岁的人犯以上八种罪行，需要承担刑事责任。本案中，乙未满16周岁，其对交通肇事行为不承担刑事责任，故乙不成立交通肇事罪。根据《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第5条第2款的规定，交通肇事后，单位主管人员、机动车辆所有人、承包人或者乘车人指使肇事人逃逸，致使被害人因得不到救助而死亡的，以交通肇事罪的共犯论处。甲作为乘车人阻止乙救治受害人吴某的行为，成立交通肇事罪。因此，A、D选项错误，C选项正确。B选项：间接正犯是指通过强制或者欺骗手段支配直接实施者，从而支配构成要件实现的行为人。其具体表现为强制他人实行犯罪，或者利用他人的错误支配犯罪事实。本案中，甲并没有通过强制或者利用乙的错误制造交通肇事的行为，交通肇事行为是乙自己造成的，故甲不成立交通肇事罪的间接正犯。因此，B选项错误。综上所述，本题答案为C。

262、下列哪一行为应以危险驾驶罪论处？

- A.醉酒驾驶机动车，误将红灯看成绿灯，撞死2名行人
- B.吸毒后驾驶机动车，未造成人员伤亡，但危及交通安全
- C.在驾驶汽车前吃了大量荔枝，被交警以呼气式酒精检测仪测试到酒精含量达到醉酒程度
- D.将汽车误停在大型商场地下固定卸货车位，后在醉酒时将汽车从地下三层开到地下一层的停车位

【答案】D

【解析】

A 选项：《刑法》第 133 条之一规定了危险驾驶罪的具体情形，其中醉酒驾驶机动车构成危险驾驶罪。但《刑法》第 133 条规定的交通肇事罪是指违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。醉酒驾驶机动车构成危险驾驶罪，但也属于违反交通运输管理法规的行为；撞死 2 名行人，属于发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。实施了一个行为既触犯危险驾驶罪又触犯交通肇事罪，成立二罪的想象竞合犯，应择一重罪处理，故应认定成立交通肇事罪。因此，A 选项错误。

B 选项：根据罪刑法定原则，《刑法》第 133 条之一关于危险驾驶罪，并没有规定吸毒后驾驶机动车的情形，故不以危险驾驶罪论处。因此，B 选项错误。

C 选项：醉酒驾驶机动车的，应当成立危险驾驶罪。但是行为人主观上对吃荔枝会导致酒驾的结果既没有故意也没有过失，行为人不构成犯罪。因此，C 选项错误。

D 选项：醉酒驾驶机动车的，应当成立危险驾驶罪。行为人在明知自己醉酒的状态下，仍然驾驶机动车，将汽车从地下三层开到地下一层的停车位，符合危险驾驶罪的构成要件，成立危险驾驶罪。因此，D 选项正确。综上所述，本题答案为 D。

263、甲对拆迁不满，在高速公路中间车道用树枝点燃一个焰高约 20 厘米的火堆，将其分成两堆后离开。火堆很快就被通行车辆轧灭。关于本案，下列哪一选项是正确的？

- A. 甲的行为成立放火罪
- B. 甲的行为成立以危险方法危害公共安全罪
- C. 如认为甲的行为不成立放火罪，那么其行为也不可能成立以危险方法危害公共

安全罪

D.行为危害公共安全，但不构成放火、决水、爆炸等犯罪的，应以以危险方法危害公共安全罪论处

【答案】C

【解析】

放火罪是指故意放火焚烧公私财物，危害公共安全的行为。以危险方法危害公共安全罪是一个概括性罪名，是故意以放火、决水、爆炸以及投放危险物质以外的并与之相当的危险方法危害公共安全的行为。无论是构成放火罪还是构成以危险方法危害公共安全罪，均要求行为人的行为对不特定多数人的生命健康安全构成了现实危险。本案中，甲在高速公路中间车道点燃一个焰高 20 厘米的火堆，并不足以危害车辆的通行安全，事实上也很快被通行车辆轧灭。因此，甲的行为既不构成放火罪，也不构成以危险方法危害公共安全罪。A、B、D 错误，C 正确。

264、甲卖迷药，明知乙将使用迷药进行犯罪活动，仍然教乙迷药的使用等方法等知识，乙用迷药迷倒丙后拿走了财物。后乙多次使用该迷药实施犯罪行为。关于甲行为的定性，下列哪一说法是错误的？

A.甲的行为成立以危险方法危害公共安全罪，因为该行为会导致乙实施不特定的犯罪

B.甲的行为不成立以危险方法危害公共安全罪，因为出售迷药的行为不会危害公共安全

C.乙的行为成立抢劫罪

D.甲的行为成立抢劫罪的帮助犯，亦触犯了传授犯罪方法罪，属于想象竞合

【答案】A

【解析】

依照通说，危害公共安全罪的法益是不特定多数人生命、身体、公共财产的安全。

甲的行为没有危害到不特定多数人的生命、身体、公共财产的安全，故不成立以危险方法危害公共安全罪。A项错误，B项正确。乙以非法占有为目的，用迷药迷倒丙拿走其财物的行为，成立抢劫罪。C项正确。传授犯罪方法罪，是指故意使用各种手段将犯罪方法传授给他人的行为。甲明知乙要实施抢劫犯罪行为，还向乙传授迷药的使用方法，成立传授犯罪方法罪与抢劫罪帮助犯的形象竞合。

CD项正确。

265、农民甲醉酒在道路上驾驶拖拉机，其认为拖拉机不属于《刑法》第133条之一规定的机动车。关于本案的分析，下列哪一选项是正确的？

- A.甲未能正确评价自身的行为，存在事实认识错误
- B.甲欠缺违法性认识的可能性，其行为不构成犯罪
- C.甲对危险驾驶事实有认识，具有危险驾驶的故意
- D.甲受认识水平所限，不能要求其对自身行为负责

【答案】C**【解析】**

A选项：关于事实认识错误和违法性认识错误的区分，应以行为人是事实产生认识错误还是对规范的评价产生错误为标准。本题中该错误是涵摄的错误或称包摄的错误，是指错误地解释构成要件要素，误认为自己的行为不符合构成要件要素的情形。该错误不属于事实认识错误，不阻却故意。甲醉酒驾驶机动车的行为，在客观上，符合危险驾驶罪的构成要件；在主观上，甲明确知道自己驾驶的是拖拉机，不存在事实认识错误问题。因此，A选项错误。B选项：违法性认识错误

是指行为人认识到了符合构成要件的事实，但不知道自己的行为被法律所禁止，又被称为禁止的错误。在主观上，甲错误地认为以为拖拉机不属于刑法意义上的机动车，这种情况并非是案件事实的认识错误，而是法律规范认识错误，系刑法理论上的违法性认识错误。但按照生活常理，一个正常的理性人也能认识到拖拉机属于机动车的范围，即这种违法性认识错误完全是可以避免，故甲的行为成立犯罪。因此，B选项错误。C选项：《刑法》第133条规定了危险驾驶罪的具体情形，其中醉酒驾驶机动车构成危险驾驶罪。危险驾驶罪的事实包括机动车、驾驶机动车、醉酒、在道路上行驶，甲对此均有认识。甲醉酒在道路上驾驶拖拉机的行为，在客观上，满足危险驾驶罪的构成要件；在主观上，甲明确知道自己是醉酒状态，且明确知道自己驾驶的是拖拉机，正常人都知道拖拉机属于机动车辆，因此该违法性错误完全可以避免，但是甲对其可能对道路安全造成的危害持希望或放任状态，则甲主观上具有危险驾驶的故意。因此，C选项正确。D选项：违法性认识，是指认识到自己的行为违反刑法，即对形式的刑事违法性的认识。其中的“违法性”并非仅指“抽象的禁止”，而应指作为各构成要件的具体的违法。违法性认识不属于故意的认识对象，换言之，成立故意犯罪不要求行为人认识到自己的行为被刑法所禁止。所以，违法性认识不会影响对行为人主观层面故意的判断。因此，D选项错误。综上所述，本题答案为C。

266、关于危害公共安全罪的认定，下列哪一选项是正确的？

- A.猎户甲合法持有猎枪，猎枪被盗后没有及时报告，造成严重后果。甲构成丢失枪支不报罪
- B.乙故意破坏旅游景点的缆车的关键设备，致数名游客从空中摔下。乙构成破坏交通设施罪

C.丙吸毒后驾车将行人撞成重伤(负主要责任),但毫无觉察,驾车离去。丙构成交通肇事罪

D.丁被空姐告知“不得打开安全门”,仍拧开安全门,致飞机不能正点起飞。丁构成破坏交通工具罪

【答案】C

【解析】

A选项:根据《刑法》第129条的规定,依法配备公务用枪的人员,丢失枪支不及时报告,造成严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役。所以只有依法配备公务用枪的人员才可以成为丢失枪支不报罪的主体,而猎户甲合法持有猎枪,并不属于配备公务用枪,仅属于依法配置枪支的人员,其不能成立丢失枪支不报罪。因此,A选项错误。B选项:根据《刑法》第117条,破坏交通设施罪是指“破坏轨道、桥梁、隧道、公路、机场、航道、灯塔、标志或者进行其他破坏活动,足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生倾覆、毁坏危险,尚未造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑。”由此可见,破坏交通设施罪中的“交通设施”是涉及公共安全的交通设施,其中“破坏”行为是指足以使公共交通设施发生倾覆、毁坏危险的行为。乙虽然破坏的是旅游景点的缆车关键设备,但缆车应当属于景点的设备,不属于破坏交通设施罪中的“交通设施”,其行为不构成破坏交通设施罪。因此,B选项错误。C选项:根据最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第2条的规定,交通肇事致一人以上重伤,负事故全部或者主要责任,并具有下列情形之一的,以交通肇事罪定罪处罚:(1)酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的;(2)无驾驶资格驾驶机动车辆的;(3)明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的;(4)明

知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的；(5)严重超载驾驶的；(6)为逃避法律追究逃离事故现场的。丙吸毒后驾车，且将行人撞成重伤(负主要责任)符合上述法条第一项的规定，构成交通肇事罪。因此，C选项正确。D选项：根据《刑法》第119条，破坏交通工具罪是指：“破坏交通工具、交通设施、电力设备、燃气设备、易燃易爆设备，造成严重后果的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。”因此，破坏交通工具罪属于具体危险犯，是破坏涉及不特定或者多数人的生命、健康或者重大财产安全的火车、汽车、电车、船只、航空器，足以使其发生倾覆、毁坏的具体危险，危及公共安全的行为。虽然丁拧开了飞机安全门，导致了飞机无法按时起飞，但该行为未到达足以引起飞机倾覆、毁坏的具体危险，故未触犯破坏交通工具罪。因此，D选项错误。综上所述，本题答案为C。

267、甲在高速公路休息站开店经营汽车补胎业务，故意在靠近经营点附近的高速公路，上撒钉子，长达数百米。甲的行为造成很多途经此路段的汽车爆胎，足以导致车辆发生倾覆、毁坏危险。为此，招致很多车主抱怨。司机问甲为什么会有这么多的钉子在路上，甲笑而不答，只是按照正常的市场价格收费补胎。甲的行为构成何罪？

- A.故意毁坏财物罪
- B.破坏交通工具罪
- C.破坏交通设施罪
- D.诈骗罪

【答案】C

【解析】

破坏交通设施罪是指，故意破坏轨道、桥梁、隧道、公路、机场、航道、灯塔、标志或者进行其他破坏活动，足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生倾覆、毁坏危险的行为。在交通设施上添附某一物品，足以使交通工具发生倾覆、毁坏危险的，同样成立本罪。甲的行为完全符合本罪的成立条件，应当认定为破坏交通设施罪。C项是正确的。如果将甲的行为认定为故意毁坏财物罪，实际上是忽视了甲的行为危害公共安全的事实，并不合适。退一步讲，即使认定甲的行为为破坏交通设施罪与故意毁坏财物罪的想象竞合，择一重的结果，亦应认定为破坏交通设施罪。甲破坏的是交通设施，而非交通工具，B项是错误的。甲按市场价收取补胎费的行为，显然不成立诈骗罪。D项是错误的。

268、甲从境外网站购买爆炸物，但是卖家寄错了，寄来了子弹。下列说法正确的是？

- A.甲构成非法买卖弹药罪既遂
- B.甲构成非法买卖爆炸物罪未遂
- C.甲客观上买到子弹，但主观上没有购买子弹的故意，故不构成非法买卖弹药罪
- D.因子弹脱离枪支后，子弹本身无法造成危害，故乙不构成非法买卖弹药罪

【答案】A**【解析】**

选择性罪名的行为对象存在多个。对这多个行为对象产生认识错误，按照客观实际来定。这是因为选择性罪名是一个罪名、一个犯罪构成。其中认识错误属于同一犯罪构成内的认识错误（具体的错误），不属于不同犯罪构成间的错误（抽象的错误）。同一犯罪构成的对象认识错误，不重要，不影响犯罪既遂。本题涉及

的选择性罪名是“非法买卖枪支、弹药、爆炸物罪”。在这三个对象之间产生认识错误，按照客观实际定。也即，对甲定非法买卖弹药罪既遂。

269、甲在建筑工地开翻斗车。某夜，甲开车时未注意路况，当场将工友乙撞死、丙撞伤。甲背丙去医院，想到会坐牢，遂将丙弃至路沟后逃跑。丙不得救治而亡。

关于本案，下列哪一选项是错误的？

- A.甲违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人死伤，触犯交通肇事罪
- B.甲在作业中违反安全管理规定，发生重大伤亡事故，触犯重大责任事故罪
- C.甲不构成交通肇事罪与重大责任事故罪的想象竞合犯
- D.甲为逃避法律责任，将丙带离事故现场后遗弃，致丙不得救治而亡，还触犯故意杀人罪

【答案】A

【解析】

A 选项：《刑法》第 133 条规定的交通肇事罪是指违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。重大交通事故必须发生在交通过程中以及与交通有直接关系的活动中。本案中，甲不当操作翻斗车发生重大事故的行为发生在建筑工地中，不在公共交通管理的范围内，故不构成交通肇事罪。因此，A 选项错误。B 选项：《刑法》第 134 条规定的重大责任事故罪，是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。本案中，甲开车时未注意路况，存在违反安全管理规定的行为，并造成了撞死乙、撞伤丙的重大伤亡事故，成立重大责任事故罪。因此，B 选项正确。C 选项：想象竞合犯又称想象的数罪、观念的竞合、一行为数法，是指一个行为触犯了数个罪名的情况。甲的行为不构成交通肇事罪，

故甲不可能构成交通肇事罪与重大责任事故罪的想象竞合犯。因此, C 选项正确。

D 选项: 甲之前撞伤丙的行为产生了其对丙的救助义务, 但是甲为逃避法律责任, 将丙带离事故现场后遗弃, 致丙不得救治而亡, 侵犯了丙的生命法益, 成立不作为的故意杀人罪。因此, D 选项正确。综上所述, 本题答案为 A。

270、关于交通肇事罪, 下列说法正确的是?

A. 甲驾驶货车在高速公路上正常行驶, 陈某醉酒后驾驶小型客车严重超速追尾甲车, 陈某当场死亡, 甲驾车逃离。交警部门认定甲负主要责任, 陈某负次要责任。

甲构成交通肇事罪

B. 乙酒后驾驶车辆将徐某撞倒, 为逃避法律追究, 其将徐某转移到某栋废楼后逃逸, 后徐某未得到及时救助而死亡。乙成立交通肇事后逃逸致人死亡

C. 丙驾车不慎将李某撞倒, 丙下车查看并将李某扶至路边, 交谈 10 分钟后, 两人都觉得无大碍, 李某同意丙离开。当天下午, 李某因腹膜后出血引发失血性休克死亡。丙成立交通肇事后逃逸

D. 丁为某客船所有人, 对客船有管理职责, 在改造客船后未经检验, 就指使不具有驾驶资格的周某等人投入营运, 造成重大沉船事故致多人死亡。丁成立交通肇事罪

【答案】D

【解析】

交通肇事致 1 人死亡或者重伤 3 人以上, 负事故全部或者主要责任的, 成立交通肇事罪。而交警的事故责任认定指出甲交通肇事逃逸, 应负事故主要责任。不过, 必须要注意的是, 交警的《行政事故责任认定书》不应作为刑法上认定交通肇事罪的绝对标准。甲正常行驶过程中被醉酒者严重超速行驶追尾, 应当认为被

害人自身需要对事故和死亡结果负责，因而甲不应成立交通肇事罪。A项错误。交通肇事后为逃避法律追究而将被害人带离事故现场后藏匿，致使被害人因得不到救助死亡的，成立作为形式的故意杀人。B项错误。逃逸是指行为人主观上基于逃避法律追究的目的而逃跑。本题中的丙误以为被害人并无大碍，被害人自身也同意丙离开，因而不应认定丙成立肇事后逃逸。C项错误。最高人民法院司法解释规定：单位主管人员、机动车辆所有人或者车辆承包人指使、强令他人违章驾驶造成重大交通事故的，以交通肇事罪定罪处罚。D项正确。

271、关于醉酒驾驶，下列说法正确的是？

A.孙某向王某说明自己要参加酒会，向王某借车，王某予以出借。孙某在酒会上喝醉酒，仍然驾车回家。王某成立危险驾驶罪的帮助犯

B.刘某晚上跟朋友聚会喝醉酒。聚会结束，刘某坐在车里，打电话让老婆来接自己，打算让老婆开车送自己回家。在等老婆的时候，刘某坐在车里觉得太冷，便将发动机打开取暖。刘某不构成危险驾驶罪

C.张某晚上在家和妻子吴某饮酒，吴某突发心脏病，周围的邻居朋友都不会驾驶汽车。张某只好开车送吴某去医院。途中没有发生交通事故。张某构成危险驾驶罪

D.赵某和同事林某一起吃饭，林某喝了酒，赵某未喝酒。饭后赵某开车送林某回家，途中林某执意要开车，于是赵某便停车，双方交换位置，林某醉酒驾车。赵某不构成危险驾驶罪

【答案】B

【解析】

考点：危害公共安全罪 A项，孙某构成危险驾驶罪的实行犯。成立帮助犯，要

求帮助行为促进的是正犯的实行行为。这种促进要具有一定的确定性或直接性。当王某出借车辆时，孙某并未醉酒，也并未准备醉酒驾驶，而且，孙某会不会醉酒驾驶并不具有确定性和必然性。因此，王某此时的出借行为不构成帮助犯。A项说法错误。 B项，醉酒驾驶型危险驾驶罪是故意犯罪，要求有醉酒驾驶的意图。刘某坐在车里，仅是用发动机取暖，没有驾驶车辆的意图，因此不构成危险驾驶罪。B项说法正确。 C项，张某虽然实施了危险驾驶行为，但是构成紧急避险，也即为了保护更大的法益（吴某的生命），不得已损害了较小法益，也即给道路制造了抽象危险。可能有人认为，张某可以打120。然而，由于吴某突发心脏病，情况紧急，不能强迫张某必须选择120。此时哪种救助措施更迅速便应采取哪种措施。C项说法错误。 D项，林某构成醉酒驾驶型危险驾驶罪，是实行犯。赵某为林某的醉酒驾驶提供车辆，构成危险驾驶罪的帮助犯。D项说法错误。 综上所述，本题答案为B。

272、下列哪些行为构成投放危险物质罪？

- A.甲故意非法开启实验室装有放射性物质的容器，致使多名实验人员遭受辐射
- B.乙投放毒害性、放射性、传染病病原体之外的其他有害物质，危害公共安全
- C.丙欲制造社会恐慌气氛，将食品干燥剂粉末冒充炭疽杆菌，大量邮寄给他人
- D.丁在食品中违法添加易使人形成瘾癖的罂粟壳粉末，食品在市场上极为畅销

【答案】AB

【解析】

投放危险物质罪与故意杀人罪、故意伤害罪的区别在于是否危及公共安全。甲故意非法开启实验室装有放射性物质的容器，致使多名实验人员遭受辐射，构成投放危险物质罪。选项A正确。投放危险物质罪投放的必须是毒害性、放射性、

传染病病原体以及其他危险物质,危害公共安全,乙的行为构成投放危险物质罪。

选项 B 正确。丙为制造社会恐慌将食品干燥剂粉末冒充炭疽杆菌大量邮寄给他人的行为,客观上不会造成危害公共安全的结果。选项 C 错误。丁在食品中违法添加易使人形成瘾癖的罂粟壳粉末的行为属于涉嫌生产、销售有毒、有害食品罪的行为,不构成投放危险物质罪。选项 D 错误。

273、乘客甲和公交车司机乙发生争吵,甲殴打乙的头部。乙被迫将车紧急靠边停。由于靠边停得太紧急,乙未看到骑自行车的丙,公交车与自行车相撞,丙当场死亡。下列说法正确的有?

- A.甲构成以危险方法危害公共安全罪
- B.甲构成寻衅滋事罪
- C.乙构成紧急避险
- D.乙构成交通肇事罪

【答案】AC

【解析】

A 项:2019 年 1 月 8 日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于依法惩治妨害公共交通工具安全驾驶违法犯罪行为的指导意见》规定:乘客在公共交通工具行驶过程中,抢夺方向盘、变速杆等操纵装置,殴打、拉拽驾驶人员,或者有其他妨害安全驾驶行为,危害公共安全,尚未造成严重后果的,依照刑法第 114 条的规定,以以危险方法危害公共安全罪定罪处罚;致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,依照刑法第 115 条第 1 款的规定,以以危险方法危害公共安全罪定罪处罚。本题中,甲殴打正在行驶中的公交车司机,危害公共安全,并且造成一人死亡的结果,构成以危险方法危害公共安全罪,适用刑法第

115 条第 1 款。A 项说法正确。B 项：2019 年 1 月 8 日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于依法惩治妨害公共交通工具安全驾驶违法犯罪行为的指导意见》规定：乘客在公共交通工具行驶过程中，随意殴打其他乘客，追逐、辱骂他人，或者起哄闹事，妨害公共交通工具运营秩序，符合刑法第 293 条规定的，以寻衅滋事罪定罪处罚。本题中，乘客甲只是殴打公交车司机，并未殴打、追逐、辱骂其他乘客，因此不构成寻衅滋事罪。B 项说法错误。CD 项：公交车司机乙被甲殴打头部时，将车紧急停靠的行为是避免甲制造的危险的行为。乙在停靠时，对路边情况有注意义务，乙违反注意义务，的确给骑自行车的丙制造了危险。但是乙属于紧急避险，也即为了保护较大合法权益，迫不得已损害较小合法权益。2019 年 1 月 8 日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于依法惩治妨害公共交通工具安全驾驶违法犯罪行为的指导意见》规定：正在驾驶公共交通工具的驾驶人员遭到妨害安全驾驶行为侵害时，为避免公共交通工具倾覆或者人员伤亡等危害后果发生，采取紧急制动或者躲避措施，造成公共交通工具、交通设施损坏或者人身损害，符合法定条件的，应当认定为紧急避险。而且，在主观上，由于当时情况紧急，无法预见到路边骑自行车的丙，丙的死亡属于意外事件。因此乙不构成交通肇事罪。C 正确。D 项错误。综上所述，本题答案为 AC。

274、关于危害公共安全犯罪，下列说法正确的有？

A.甲故意在高速公路上泼洒工业机油，导致十几辆车发生交通事故，造成重大人员伤亡。甲构成破坏交通设施罪

B.乙醉酒逆行在高速公路上，行驶十多公里。路上车辆纷纷躲避，所幸没有造成人员伤亡。乙构成以危险方法危害公共安全罪

C.丙为了报复邻居，从高空向四下无人的邻居车上扔酒瓶子，砸中车辆。丙构成以危险方法危害公共安全罪

D.丁为了自杀，打开自家煤气，给周围邻居造成重大安全隐患。丁构成以危险方法危害公共安全罪

【答案】ABD

【解析】

A 项，破坏交通设施罪中的“破坏”既包括物理性毁损，也包括妨害交通设施的道路通行功能。甲的行为虽然没有导致路面毁损，但是妨害了公路的通行功能，并且严重危害了道路公共安全，构成破坏交通设施罪。B 项，乙的行为制造了重大的公共危险，严重程度与放火罪等具有相当性，因此构成以危险方法危害公共安全罪。该罪是具体危险犯，成立该罪只要求造成具体危险，不要求造成实害结果。只造成具体危险时，适用刑法第 114 条规定。C 项，《刑法修正案十一》在《刑法》中新增第 291 条之二：从建筑物或者其他高空抛掷物品，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。丙高空扔酒瓶砸中车辆的行为符合《刑法》第 291 条之二的规定，成立该罪。丙基于报复心态毁坏邻居的车，同时构成故意毁坏财物罪。但丙扔酒瓶时目标固定并且四周无人，其行为并未引发具体危险，因此不构成以危险方法危害公共安全罪。应注意，在《刑法修正案十一》之前，有司法解释规定，高空抛物构成以危险方法危害公共安全罪，但不是一切高空抛物行为均构成该罪，因为该罪是具体危险犯，成立该罪只要求造成具体危险。D 项，丁的行为严重危害了公共安全，因此构成以危险方法危害公共安全罪。

275、乙成立恐怖组织并开展培训活动，甲为其提供资助。受培训的丙、丁为实施恐怖活动准备凶器。因案件被及时侦破，乙、丙、丁未能实施恐怖活动。关于本案，下列哪些选项是正确的？

- A.甲构成帮助恐怖活动罪，不再适用《刑法》总则关于从犯的规定
- B.乙构成组织、领导恐怖组织罪
- C.丙、丁构成准备实施恐怖活动罪
- D.对丙、丁定罪量刑时，不再适用《刑法》总则关于预备犯的规定

【答案】ABCD

【解析】

A 选项：《刑法》第 120 条之一第一款规定：“资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的，或者资助恐怖活动培训的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。”该罪帮助犯已经被刑法单独规定为犯罪即已经被正犯化，故甲资助恐怖活动培训的行为构成帮助恐怖活动罪，应该直接适用分则的规定，不再适用总则有关对从犯处罚的规定。因此，A 选项正确。B 选项：《刑法》第 120 条规定，组织、领导恐怖活动组织的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产。乙成立恐怖组织并开展培训活动，系组织、领导恐怖组织的行为，故乙构成组织、领导恐怖组织罪。因此，B 选项正确。C 选项：《刑法》第 120 条第 2 款：“有下列情形之一的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）为实施恐怖活动准备凶器、危险物品或者其他工具的；”本案中，丙、丁为实施恐怖活动准备凶器，属于第一种情形，即为实施恐怖活动准备凶器、危险物品或者其

他工具的。故 丙、丁构成准备实施恐怖活动罪。因此，C 选项正确。 D 选项：依据刑法理论，某一犯罪的预备犯被分则规定为独立犯罪时，就应直接适用分则的规定，不再适用总则关于预备犯的规定。准备实施恐怖活动罪系领导、组织恐怖组织罪的预备犯，其为独立的犯罪。应直接适用刑法分则的规定，不再适用总则有关预备犯的规定。因此，D 选项正确。综上所述，本题答案为 ABCD。

276、关于危害公共安全罪的论述，下列哪些选项是正确的？

- A.甲持有大量毒害性物质，乙持有大量放射性物质，甲用部分毒害性物质与乙交换了部分放射性物质。甲、乙的行为属于非法买卖危险物质
- B.吸毒者甲用毒害性物质与贩毒者乙交换毒品。甲、乙的行为属于非法买卖危险物质，乙的行为另触犯贩卖毒品罪
- C.依法配备公务用枪的甲，将枪赠与他人。甲的行为构成非法出借枪支罪
- D.甲父去世前告诉甲“咱家院墙内埋着 5 支枪”，甲说“知道了”，但此后甲什么也没做。甲的行为构成非法持有枪支罪

【答案】ABCD

【解析】

A 项，非法买卖危险物质罪是指故意非法买卖毒害性、放射性、传染病病原体等物质，危害公共安全的行为。买卖不一定是货币交易，有偿转让即为买卖。A 项中，无论是毒害性物质还是放射性物质，均属危险物质。甲用部分毒害性物质与乙交换部分放射性物质，甲、乙二人均属有偿转让危险物质，故甲、乙的行为属于非法买卖危险物质。A 项正确。B 项，如前所述，毒害性物质属于危险物质，吸毒者甲用毒害性物质与贩毒者乙交换毒品。吸毒者甲相当于出卖了毒害性物质，贩毒者乙相当于购买了毒害性物质，甲乙二人构成非法买卖危险物质罪。同时，

贩毒者乙相当于向吸毒者甲有偿转让了毒品,故乙另触犯贩卖毒品罪。B项正确。

C项,对于依法配备公务用枪的人员而言,非法出借枪支,一般是指违反《枪支管理办法》的规定,擅自将公务用枪在一段时间内无偿提供给他人使用的行为;同理,非法将公务用枪赠与他人的,可以评价为永久性无偿提供给他人使用的行为,应认定为非法出借枪支。C项正确。D项,2009年11月16日最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第8条规定,“非法持有”,是指不符合配备、配置枪支、弹药条件的人员,违反枪支管理法律、法规的规定,擅自持有枪支、弹药的行为。D项中,甲作为没有持枪资格的人,在明知自家院子埋着5支枪的情况下,违反枪支管理规定,擅自持有,构成非法持有枪支罪。D项正确。

277、甲非法出售枪支给乙,乙把自己非法持有的毒品交换给了甲。某日警方查获乙非法持有枪支,将其抓获,尚未讯问,乙主动交代购买枪支的事实,还提供了卖家甲的住址信息。警方依此抓到甲,并在甲家中搜查出毒品(用于自己吸食)。下列说法正确的有?

- A.乙构成非法买卖枪支罪、贩卖毒品罪、非法持有毒品罪,前两罪属于想象竞合关系
- B.甲构成非法买卖枪支、非法持有毒品罪
- C.乙就非法买卖枪支罪构成自首
- D.乙协助抓捕甲构成立功

【答案】BD

【解析】

(1)刑法中的“买卖”、“贩卖”。第一,客观上要求有偿转让。第

二，有偿的方式不限于金钱货币，可以是其他物质利益，可以物物交换。例1，甲给乙1克毒品，乙给甲10袋大米，也即物物交换也是买卖。例2(2014年第57题)，甲用毒害性物质，乙用放射性物质，二者交换。甲、乙的行为属于非法买卖危险物质罪。例3，甲用枪，乙用子弹，二者交换。二者构成非法买卖枪支、弹药罪。(2)非法买卖枪支罪中的“买卖”，既处罚“卖”，也处罚“买”。卖，包括先买进后卖出也包括单纯的卖出。买，包括为卖出而买进，也包括为自己使用而买进。本题中，甲用枪支，乙用毒品，进行交换甲构成非法买卖枪支罪，甲购买毒品用于自己吸食不构成贩卖毒品罪。但是甲将毒品放在家里构成非法持有毒品罪，该罪和非法买卖枪支罪应当数罪并罚。乙的购买行为构成非法买卖枪支罪，出售行为构成贩卖毒品罪，这是两个行为分别构成两个罪，不属于想象竞合犯，而应数罪并罚。乙的非法持有毒品罪和贩卖毒品罪，根据吸收犯原理，重罪吸收轻罪，只定贩卖毒品罪。(3)准自首，是指被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。如实供述的罪行必须与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属不同种罪行。如果是同种罪行，可以酌情从轻处罚，但不属于自首。后罪行与前罪行是不是同种罪行，一般以罪名区分，不同罪名便是不同种罪行。但是，根据司法解释，虽然罪名不同，但二者属于选择性罪名或者在法律、事实上密切关联(如吸收关系、牵连关系等)，则仍属于同种罪行的范畴。本题中，乙因非法持有枪支罪被采取强制措施后，主动交代非法买卖枪支罪的犯罪事实。这两项罪名

在事实上具有密切联系，仍然属于同种罪行的范畴，因此乙不构成准自首，而属于坦白。乙就非法买卖枪支罪要构成坦白，要求如实供述非法买卖枪支罪的犯罪事实。要如实供述非法买卖枪支罪的犯罪事实，就要求将卖家供出来。因此乙将卖家甲供出来，不属于揭发他人犯罪型立功。但是，乙将甲家的住址信息提供给警方，协助警方抓捕甲，属于协助抓捕型立功。综上所述，本题答案为BD。

278、关于危害公共安全犯罪，下列选项说法正确的有？

- A.马某从高空向下扔正在燃烧的蜂窝煤球，下方有人。马某构成以危险方法危害公共安全罪
- B.李某在公交车上沉迷手机游戏，坐过车站，便抢夺司机的方向盘要求停车。李某构成妨害安全驾驶罪
- C.陈某在公交车上与司机发生口角，便暴力捶打司机，导致公交车撞上对面的小轿车，致使小轿车内多人遭受轻伤。陈某构成妨害安全驾驶罪
- D.朱某记恨王某，在王某的摩托车上动手脚，致使王某在骑摩托车时发生故障，撞伤多名行人。朱某成立破坏交通工具罪

【答案】ABC

【解析】

考点：危害公共安全罪 A 项，马某扔的是燃烧的蜂窝煤，具有危及多数人的可能性，危害了公共安全，构成以危险方法危害公共安全罪（马某的行为如果引起火灾，则构成放火罪），同时马某也构成高空抛物罪，两罪想象竞合，择一重罪论处，定以危险方法危害公共安全罪。如果马某扔的是酒瓶子，没有危及多数人的可能性，则不构成以危险方法危害公共安全罪，而构成高空抛物罪；如果过失

致人死亡，则同时构成过失致人死亡罪，与高空抛物罪想象竞合。A 项说法正确。

B 项，妨害安全驾驶罪，是指对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力，或者抢控方向盘，干扰公共交通工具正常行驶的行为。基于此，李某构成妨害安全驾驶罪。B 项说法正确。C 项，陈某的行为构成妨害安全驾驶罪。该行为不构成交通肇事罪，因为成立交通肇事罪，要求造成一人死亡，或者三人重伤，或者一人重伤并且有严重情节。而陈某的行为仅导致多人轻伤，未导致一人重伤。C 项说法正确。D 项，第一，破坏交通工具罪要求破坏的交通工具是火车、汽车、电车、船只、航空器。摩托车不属于这些交通工具。第二，成立破坏交通工具罪，要求危害公共安全，并且达到一定的严重程度，因为该罪属于重罪。破坏个人骑行的电瓶车或摩托车，危害程度不高，不成立破坏交通工具罪。所以，朱某不构成破坏交通工具罪。如果摩托车价值数额较大，则朱某构成故意毁坏财物罪。如果导致行人受到轻伤，则朱某构成故意伤害罪，属于间接故意。D 项说法错误。

综上所述，本题答案为 ABC。

279、甲于某晚 9 时驾驶货车在县城主干道超车时，逆行进入对向车道，撞上乙驾驶的小轿车，乙被卡在车内无法动弹，乙车内黄某当场死亡、胡某受重伤。后查明，乙无驾驶资格，事发时略有超速，且未采取有效制动措施。（事实一）甲驾车逃逸。急救人员 5 分钟后赶到现场，胡某因伤势过重被送医院后死亡。（事实二）交警对乙车进行切割，试图将乙救出。此时，醉酒后的丙（血液中的酒精含量为 152mg/100ml）与丁各自驾驶摩托车“飙车”经过此路段。（事实三）丙发现乙车时紧急刹车，摩托车侧翻，猛烈撞向乙车左前门一侧，丙受重伤。20 分钟后，交警将乙抬出车时，发现其已死亡。现无法查明乙被丙撞击前是否已死亡，也无法查明乙被丙撞击前所受创伤是否为致命伤。（事实四）丁离开现场后，

找到无业人员王某，要其假冒飙车者去公安机关投案。（事实五）王某虽无替丁顶罪的意思，但仍要丁给其5万元酬劳，否则不答应丁的要求，丁只好付钱。王某第二天用该款购买100克海洛因藏在家中，用于自己吸食。5天后，丁被司法机关抓获。（事实六）关于事实三的定性，下列选项正确的是：

- A.丙、丁均触犯危险驾驶罪，属于共同犯罪
- B.丙构成以危险方法危害公共安全罪，丁构成危险驾驶罪
- C.丙、丁虽构成共同犯罪，但对丙结合事实四应按交通肇事罪定罪处罚，对丁应按危险驾驶罪定罪处罚
- D.丙、丁未能完成预定的飙车行为，但仍成立犯罪既遂

【答案】AD

【解析】

A.D选项：《刑法》第133条规定的危险驾驶罪，是指在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣，或者在道路上醉酒驾驶机动车的行为。《刑法》第25条第1款规定“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”本案中，丙明知自己是醉酒状态，却还是驾驶摩托车与丁进行危险的“飙车”行为，丁明知是“飙车”的行为，却依然和丙进行该行为，二者具有共同驾驶的故意，并实施了危险驾驶的行为。故丙、丁成立危险驾驶罪的共同犯罪。危险驾驶罪是抽象的危险犯，只要在道路上驾驶机动车进行了追逐竞驶的行为，就已经构成危险驾驶罪既遂，不要求必须将既定的飙车路线完成。因此，A.D选项正确。B选项：《刑法》上的以危险方法危害公共安全罪，是指故意使用放火、决水、爆炸、投放危险物质以外的危险方法危害公共安全的行为。本罪主观上存在危害公共安全的故意，本案中，丙主观上具有危险驾驶的故意，但不具有危害公共安全的故意，不成立以危险方法危

害公共安全罪。因此，B选项错误。C选项：丙、丁以危险驾驶的故意，构成危险驾驶罪的共同犯罪。在事实四中，无法查明乙被丙撞击前是否已死亡，也无法查明乙被丙撞击前所受创伤是否为致命伤。故无法确定丙的行为与乙的死亡之间是否存在因果关系，故不能将乙死亡的结果归因于丙的行为，也不能认定丙构成交通肇事罪。因此，C选项错误。综上所述，本题答案为AD。

280、甲于某晚9时驾驶货车在县城主干道超车时，逆行进入对向车道，撞上乙驾驶的小轿车，乙被卡在车内无法动弹，乙车内黄某当场死亡、胡某受重伤。后查明，乙无驾驶资格，事发时略有超速，且未采取有效制动措施。（事实一）甲驾车逃逸。急救人员5分钟后赶到现场，胡某因伤势过重被送医院后死亡。（事实二）交警对乙车进行切割，试图将乙救出。此时，醉酒后的丙（血液中的酒精含量为152mg/100ml）与丁各自驾驶摩托车“飙车”经过此路段。（事实三）丙发现乙车时紧急刹车，摩托车侧翻，猛烈撞向乙车左前门一侧，丙受重伤。20分钟后，交警将乙抬出车时，发现其已死亡。现无法查明乙被丙撞击前是否已死亡，也无法查明乙被丙撞击前所受创伤是否为致命伤。（事实四）丁离开现场后，找到无业人员王某，要其假冒飙车者去公安机关投案。（事实五）王某虽无替丁顶罪的意思，但仍要丁给其5万元酬劳，否则不答应丁的要求，丁只好付钱。王某第二天用该款购买100克海洛因藏在家中，用于自己吸食。5天后，丁被司法机关抓获。（事实六）关于事实一的分析，下列选项错误的是：

- A.甲违章驾驶，致黄某死亡、胡某重伤，构成交通肇事罪
- B.甲构成以危险方法危害公共安全罪和交通肇事罪的想象竞合犯
- C.甲对乙车内人员的死伤，具有概括故意
- D.乙违反交通运输管理法规，致同车人黄某当场死亡、胡某重伤，构成交通肇事

罪

【答案】BCD

【解析】

A 正确，B 错误。甲在县城主干道超车时，逆行进入对向车道，造成一死一重伤的后果，属于违反交通运输管理法规，因而造成重大伤亡事故的行为，成立交通肇事罪。甲的行为不成立以危险方法危害公共安全罪，以危险方法危害公共安全罪是故意犯罪，考题中，行为人对于危害公共安全的结果究竟是故意还是过失是判断的难点，尤其是开车撞死人，究竟是定交通肇事罪还是以危险方法危害公共安全罪，一般认为，行为人干了一件“超级危险的事情”成立以危险方法危害公共安全罪。一般的危险开车行为，造成了严重后果的，更多地是成立交通肇事罪。无论是司法实践，还是司法考试中，都应该慎用以危险方法危害公共安全罪这一罪名。C 错误，D 错误。甲的行为成立交通肇事罪，其主观上对于乙车内人员的死伤系过失的心态，交通肇事罪是过失犯罪。特别需要指出的是，犯罪故意、过失不是指行为人对行为本身的态度，而是指行为人对危害结果的心态。本案中，行为人甲对于违章行为（逆行行为）本身是故意的，但对于造成他人的死亡结果是过失的心态。因此，甲的行为成立交通肇事罪。

281、关于事实二的分析，下列选项正确的是：

- A. 胡某的死亡应归责于甲的肇事行为
- B. 胡某的死亡应归责于甲的逃逸行为
- C. 对甲应适用交通肇事“因逃逸致人死亡”的法定刑
- D. 甲交通肇事后逃逸，如数日后向警方投案如实交代罪行的，成立自首

【答案】AD

【解析】

A 正确，B、C 错误。胡某的死亡应归责于甲的肇事行为，甲虽然在本案中有逃逸行为，但并非因为甲的逃逸行为导致被害人得不到救助而死亡。根据 2000 年最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第 5 条规定，“因逃逸致人死亡”，是指行为人在交通肇事后为逃避法律追究而逃跑，致使被害人因得不到救助而死亡。本案中，甲虽然实施了逃跑行为，但急救人员 5 分钟后赶到现场，胡某因伤势过重被送医院后死亡。换言之，胡某的行为是因为伤势过重，而并非因为得不到救助而死亡。本案中，胡某已经得到了及时救助仍然死亡，所以，不能将其死亡结果归责于逃逸行为。D 正确。根据《刑法》第 67 条的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。本案中，犯罪分子犯罪数日后向警方投案，如实交代罪行的，当然成立自首。2010 年 12 月 22 日最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》规定：交通肇事后保护现场、抢救伤者，并向公安机关报告的，应认定为自动投案，构成自首的，因上述行为同时系犯罪嫌疑人的法定义务，对其是否从宽、从宽幅度要适当从严掌握。交通肇事逃逸后自动投案，如实供述自己罪行的，应认定为自首，但应依法以较重法定刑为基准，视情况决定对其是否从宽处罚以及从宽处罚的幅度。笔者认为，这种情形下，逃逸后自首的，虽然认定自首，但要视情况从宽处罚，其重要的理由在于，交通肇事后的逃逸行为有使事态恶化之趋势，与一般犯罪的逃逸不同。

282、甲将私家车借给无驾照的乙使用。乙夜间驾车与其叔丙出行，途中遇刘某过马路，不慎将其撞成重伤，车辆亦受损。丙下车查看情况，对乙谎称自己留下打电话叫救护车，让乙赶紧将车开走。乙离去后，丙将刘某藏匿在草丛中离开。

刘某因错过抢救时机身亡。(事实一) 为逃避刑事责任, 乙找到有驾照的丁, 让丁去公安机关“自首”, 谎称案发当晚是丁驾车。丁照办。公安机关找甲取证时, 甲想到若说是乙造成事故, 自己作为被保险人就无法从保险公司获得车损赔偿, 便谎称当晚将车借给了丁。(事实二) 后甲找到在私营保险公司当定损员的朋友陈某, 告知其真相, 请求其帮忙向保险公司申请赔偿。陈某遂向保险公司报告说是丁驾车造成事故, 并隐瞒其他不利于甲的事实。甲顺利获得 7 万元保险赔偿。

(事实三) 关于事实一的分析, 下列选项正确的是:

- A. 乙交通肇事后逃逸致刘某死亡, 构成交通肇事逃逸致人死亡
- B. 乙交通肇事且致使刘某死亡, 构成交通肇事罪与过失致人死亡罪, 数罪并罚
- C. 丙与乙都应对刘某的死亡负责, 构成交通肇事罪的共同正犯
- D. 丙将刘某藏匿致使其错过抢救时机身亡, 构成故意杀人罪

【答案】D

【解析】

《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第 5 条规定, “因逃逸致人死亡”, 是指行为人在交通肇事后为逃避法律追究而逃跑, 致使被害人因得不到救助而死亡的情形。本案中乙之所以离开事故现场是因为丙下车查看情况后对其谎称自己会留在现场打电话叫救护车, 并非是为了逃避法律追究而逃跑。因此不应认定为“因逃逸致人死亡”。A、B 错误。前述解释第 2 条第 2 款规定: “交通肇事致一人以上重伤, 负事故全部或者主要责任, 并具有下列情形之一的, 以交通肇事罪定罪处罚:; (二) 无驾驶资格驾驶机动车辆的;” 乙未取得驾驶资格, 将过马路的刘某撞成重伤, 已构成交通肇事罪。丙作为乘车人指使乙逃逸, 根据前述解释规定已构成交通肇事罪的共同犯罪, 但

丙杀害刘某的行为已超出乙的主观故意范围，属于共同犯罪实行过限，乙不需要对刘某的死亡结果负责。C 错误。根据前述解释第 6 条规定：“行为人在交通肇事后为逃避法律追究，将被害人带离事故现场后隐藏或者遗弃，致使被害人无法得到救助而死亡或者严重残疾的，应当分别依照刑法第 232 条、第 234 条第 2 款的规定，以故意杀人罪或者故意伤害罪定罪处罚。”丙将刘某藏匿在草丛中离开，刘某因错过抢救时机而身亡，丙的行为构成故意杀人罪。D 正确。

283、丙实施抢劫犯罪后，分管公安工作的副县长甲滥用职权，让侦办此案的警察乙想办法使丙无罪。乙明知丙有罪，但为徇私情，采取毁灭证据的手段使丙未受追诉。关于本案的分析，下列哪些选项是正确的？

- A.因甲是国家机关工作人员，故甲是滥用职权罪的实行犯
- B.因甲居于领导地位，故甲是徇私枉法罪的间接正犯
- C.因甲实施了两个实行行为，故应实行数罪并罚
- D.乙的行为同时触犯徇私枉法罪与帮助毁灭证据罪、滥用职权罪，但因只有一个行为，应以徇私枉法罪论处

【答案】AD

【解析】

A 选项：刑法 397 条规定，国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，是滥用职权罪。在本案中，甲作为国家机关工作人员，滥用职权致使丙未被认定为抢劫罪，进而未受到应该受到的惩罚，甲的行为触犯了滥用职权罪。因此，A 选项正确。B 选项：刑法 399 条规定，司法工作人员徇私枉法、徇情枉法，对明知是无罪的人而使他受追诉、对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作

枉法裁判的，是徇私枉法罪。由此可知，徇私枉法罪要求行为人具有司法机关工作人员的身份。在共犯中，由于间接正犯也是正犯，若行为人不具有司法工作人员的身份，也不可能成为徇私枉法罪的间接正犯。在本案中，甲不具有司法工作人员的身份，不满足徇私枉法罪的主体要件。因此，B选项错误。C选项：在本案中，甲仅有一个行为即指使乙想办法使丙无罪，因此，不宜数罪并罚。因此，C项错误。D选项：第一，乙实施了徇私枉法、滥用职权的行为，触犯徇私枉法罪和滥用职权罪；第二，乙又实施了毁灭证据的行为，触犯毁灭证据罪即一个行为触犯了三个罪名，依据刑法规定，滥用职权罪与徇私枉法罪之间是法条竞合的关系，按照法条竞合的处罚原则，徇私枉法罪作为特别法条应当优先适用。又由于徇私枉法罪与帮助毁灭证据罪是想象竞合犯，因此，应当择一重罪处罚，故乙触犯徇私枉法罪。因此，D选项正确。综上所述，本题答案为AD。

284、关于渎职犯罪，下列哪些选项是正确的？

- A.县财政局副局长秦某工作时擅离办公室，其他办公室人员操作电炉不当，触电身亡并引发大火将办公楼烧毁。秦某触犯玩忽职守罪
- B.县卫计局执法监督大队队长武某，未能发现何某在足疗店内非法开诊所行医，该诊所开张三天即造成一患者死亡。武某触犯玩忽职守罪
- C.负责建房审批工作的干部柳某，徇情为拆迁范围内违规修建的房屋补办了建设许可证，房主凭此获得补偿款90万元。柳某触犯滥用职权罪
- D.县长郑某擅自允许未经环境评估的水电工程开工，导致该县水域内濒危野生鱼类全部灭绝。郑某触犯滥用职权罪

【答案】CD

【解析】

A 选项, 县财政局副局长擅离办公室的行为与其他办公室人员操作电炉不当的行为没有因果关系, 且防止他人操作电炉也不属于县财政局副局长的工作职责。因此不能认定秦某构成犯罪。A 错误。B 选项, 武某作为县卫计局执法监督大队队长, 防止他人非法行医是其职责所在, 但何某刚刚开始非法行医 3 天即造成严重后果, 无法认定武某严重不负责任, 武某不构成玩忽职守罪。B 错误。C 选项, 负责建房审批的柳某为他人违规补办建设许可证, 属于典型的滥用职权行为, 最终造成国家损失, 构成滥用职权罪。C 正确。D 选项。郑某作为县里的一把手, 擅自允许不符合制度要求的水电工程开工, 属于滥用职权行为, 造成严重损失, 已构成滥用职权罪。D 正确。

285、关于渎职罪, 下列哪些选项是正确的?

A.省渔政总队验船师郑某, 明知有 8 艘渔船存在套用船号等问题, 按规定应注销, 却为船主办理船检证书, 船主领取国家柴油补贴 640 万元。郑某构成滥用职权罪

B.刑警曾某办理冯某抢劫案, 明知冯某被取保候审后未定期到派出所报到, 曾某也未依法传唤冯某或将案件移送起诉或变更强制措施。期间, 冯某再次犯罪。曾某构成徇私枉法罪

C.律师于某担任被告人马某的辩护人, 从法院复印马某贪污案的案卷材料, 允许马某亲属朱某查阅。朱某随后游说证人, 使数名证人向于某出具了虚假证明材料。于某构成故意泄露国家秘密罪

D.公安局协警闫某, 在协助抓捕行动中, 向领导黑社会性质组织的李某通风报信, 导致李某等主要犯罪分子潜逃。闫某构成帮助犯罪分子逃避处罚罪

【答案】AD

【解析】

A 选项：《刑法》397 条规定：“国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。国家机关工作人员徇私舞弊，犯前款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。”国家机关工作人员郑某利用其职权、职责的便利，随心所欲地对事项做出决定或者处理，不正确履行其职责，致使国家利益遭受严重损失的，符合滥用职权罪的构成要件，构成滥用职权罪。因此，A 选项正确。B 选项：《刑法》399 条规定：“司法工作人员徇私枉法、徇情枉法，对明知是无罪的人而使他受追诉、对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑。”在本案中，刑警曾某虽系国家司法工作人员，但没有任何徇私枉法的行为；但曾某故意不履行其应该履行的职责，引起冯某再次犯罪的，即造成了严重的后果，其行为触犯玩忽职守罪。因此，B 选项错误。C 选项：国家秘密，是指关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。在本案中，律师于某从法院复印的案卷材料非系国家秘密，因此，其允许马某之亲属朱某查阅的行为，在主观上也没有泄露国家秘密的犯罪故意，故于某未触犯故意泄露国家秘密罪。因此，C 选项错误。D 选项：帮助犯罪分子逃避处罚罪，是指有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员，向犯罪分子通风报信、提供便利，帮助犯罪分子逃避处罚的行为。公安局协警闫某，在协助抓捕行动时，系国家机关工作人员，其

向领导黑社会性质组织的李某通风报信，导致李某等主要犯罪分子潜逃，满足帮助犯罪分子逃避处罚罪的成立条件，构成帮助犯罪分子逃避处罚罪。因此，D 选项正确。综上所述，本题答案为 AD。

286、关于渎职犯罪，下列说法正确的有？

- A.司法工作人员因过失致使故意杀人犯未被起诉，致使故意杀人犯不久又杀人的，构成玩忽职守罪
- B.办案人员因受贿而为实施重罪的犯罪嫌疑人通风报信，致使犯罪嫌疑人改变供述，导致其仅受轻罪追诉，构成帮助犯罪分子逃避处罚罪
- C.国家机关工作人员为境外机构提供国家秘密，构成为境外非法提供国家秘密罪和故意泄露国家秘密罪的想象竞合
- D.国家机关工作人员收受贿赂并实施渎职犯罪，同时构成受贿罪的，一律数罪并罚

【答案】ABC

【解析】

A 项，玩忽职守罪，是指国家机关工作人员玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。该罪是过失犯罪。该罪是许多过失型渎职犯罪的兜底罪名。司法工作人员因过失致使故意杀人犯未被起诉，不构成徇私枉法罪，因为该罪是故意犯罪。但是，这种过失行为导致故意杀人犯未被起诉，该故意杀人犯在社会上又杀人，致使人民利益遭受重大损失，符合玩忽职守罪的构成要件，构成玩忽职守罪。B 项，帮助犯罪分子逃避处罚罪（第 417 条），是指有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员，向犯罪分子通风报信、提供便利，帮助犯罪分子逃避处罚的行为。本罪实际上是徇私枉法罪之外的补充罪名，行为类型包括

两种：(1) 司法工作人员利用职务便利，帮助犯罪分子逃避处罚，但又不构成徇私枉法罪的情形。(2) 其他国家机关工作人员利用职务便利，帮助犯罪分子逃避刑事处罚。题中，办案人员也即司法工作人员为犯罪嫌疑人通风报信，这种行为不构成徇私枉法罪，因为徇私枉法罪要求司法工作人员滥用自己的职权，直接为犯罪人谋利，或故意损害犯罪人利益，例如法官将无罪直接判为有罪，检察官应当起诉却不起诉。而通风报信不属于徇私枉法罪中的直接渎职行为。因此，题中办案人员构成帮助犯罪分子逃避处罚罪。同时该办案人员又有受贿行为，构成受贿罪。但本题题干仅针对渎职犯罪，因此就渎职犯罪来说该办案人员构成帮助犯罪分子逃避处罚罪。C 项，为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪（第 111 条）与故意泄露国家秘密罪（第 398 条）的比较。前者是危害国家安全犯罪。后者是渎职犯罪一章的罪名，但是，国家机关工作人员和非国家机关工作人员均可以构成该罪。两罪的区别是：二者在接受方的范围上要求不同。为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪要求为境外机构、人员。故意泄露国家秘密罪只要求故意泄露就行，至于泄露给谁，不作要求，既可以是境外机构、人员，也可以是境内机构、人员。当故意泄露给境外机构、人员时，同时触犯为境外非法提供国家秘密罪，想象竞合，择一重罪论处。C 项说法正确。D 项，国家机关工作人员既受贿，又渎职，原则上数罪并罚，但是有个例外，也即刑法第 399 条第 4 款规定：司法工作人员收受贿赂，有前三款行为的（徇私枉法罪，民事、行政枉法裁判罪，执行判决、裁定失职罪，执行判决、裁定滥用职权罪），同时又构成受贿罪的，择一重罪论处。因此，D 项说法错误。

287、关于渎职犯罪，下列说法正确的有？

A.市场监管执法人员甲明知王某生产的口罩是伪劣产品，涉嫌犯罪，向其通风报信，

帮助逃避处罚。甲构成包庇罪

B.铁路警察乙发现李某盗窃,因收了李某的钱财,对李某不予立案。乙构成徇私枉法罪和受贿罪,择一重罪论处

C.监狱管理人员丙在罪犯赵某执行有期徒刑期间,利用职权私下让其回家,要求其按时返回。丙构成私放在押人员罪

D.警察丁利用职权,使无资格获取驾驶证的田某取得驾驶证。某日,田某违章驾车,酿成车祸,致人死亡。丁构成滥用职权罪

【答案】BCD

【解析】

A项,帮助犯罪分子逃避处罚罪(第417条),是指负有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员,向犯罪分子通风报信、提供便利,帮助犯罪分子逃避处罚的行为。本题中甲构成该罪。甲不构成包庇罪。包庇罪,是指积极作假证明,为犯罪分子掩盖罪行。甲并未积极作假证明。因此,A项说法错误。B项,徇私枉法罪,是指司法工作人员徇私枉法、徇情枉法,对明知是无罪的人而使他受追诉,对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉,或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的行为。其中“明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉”,包括不立案、不侦查、不起诉、不审判、裁定无罪。本题中,乙应当立案却不予立案,构成徇私枉法罪。乙也构成受贿罪。根据《刑法》第399条第4款规定,司法工作人员犯徇私枉法罪和受贿罪,不数罪并罚,而是择一重罪论处。因此,B项说法正确。C项,私放在押人员罪,是指司法工作人员私放在押的犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯的行为。这里的私放,既包括永久性释放,也包括一定时间的放出。丙私放赵某回家一段时间,构成私放在押人员罪。因此,C项说法正确。D项,滥用职权罪,是指国家

机关工作人员滥用职权,致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。

第一,客观上,其中的实害结果不要求与滥用职权行为具有直接的因果关系。第二,主观上,也不要求行为人对这些实害结果有认识。本题中,丁存在滥用职权行为,制造马路杀手,产生了重大实害结果(田某酿成车祸),构成滥用职权罪。本题出自实务判例,司法机关认定行为人构成滥用职权罪。因此,D项说法正确。综上所述,本题答案为 B.C.D。

288、关于滥用职权罪,下列选项正确的是? ()

- A.甲是民政局局长,明知李某骗取民政补贴不予制止。甲构成滥用职权罪
- B.国家机关工作人员乙明知小孟不符合某项行为的资格要求,仍对其予以批准。后来小孟因获取此资格将违禁品交给蒋某,导致人员伤亡,即使乙的行为与蒋某造成的结果没有直接因果关系。乙仍然构成滥用职权罪
- C.国家机关工作人员丙在其职权范围内为徐某实施违法犯罪行为提供便利,并在执法工作人员检查时提前告知徐某,使徐某逃过检查,丙构成滥用职权罪和包庇罪
- D.国家机关工作人员丁在新冠疫情期间,明知自己很可能染上病毒,仍然故意在公共场所活动,后经确诊感染上了新冠病毒,并造成病毒扩散至多人。丁的行为构成滥用职权罪

【答案】AB

【解析】

A 选项正确。甲作为民政局局长,对于民政补贴的发放负有监督管理职责。但甲主观上明知李某实施了骗取补贴的行为,却未履行其监督管理职责,在客观上实施了滥用职权的行为,使得李某顺利骗取到了民政补贴,导致国家财政损失,应

以滥用职权罪处罚。B 选项正确。司法解释认为，即便滥用职权行为与造成的损失之间没有直接因果关系的，也可能成立滥用职权罪。C 选项错误。丙在其职权范围内为徐某实施违法犯罪行为提供便利，不正确地履行自己的职权，当然构成滥用职权罪。丙的行为不构成包庇罪，构成帮助犯罪分子逃避处罚罪。包庇罪是指明知犯罪的人而作假证明包庇的行为，即向司法机关提供虚假的证明材料，为犯罪分子掩盖罪行或者开脱、减轻罪责。丙并没有向司法机关作假证明对徐某进行包庇，不构成包庇罪。丙作为负有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员，向犯罪分子徐某通风报信，帮助了其逃避检查。应认定为丙构成帮助犯罪分子逃避处罚罪。D 选项错误。构成滥用职权罪，要求在“履职”过程中，本案中，丁并不是在履职过程中。根据《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》第 7 条规定：在疫情防控工作中，负有组织、协调、指挥、灾害调查、控制、医疗救治、信息传递、交通运输、物资保障等职责的国家机关工作人员，滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，依照刑法第三百九十七条的规定，以滥用职权罪或者玩忽职守罪定罪处罚。本题中丁虽然是国家机关工作人员，但并不是负有疫情防控职责人员，因此并不构成滥用职权罪。

289、甲、乙是没有正式编制的辅警，夜里十一点巡逻，发现身体虚弱、嘴角流血、不能说话的丙，开车将其送往救助站，送到救助站门外，让丙自己走进救助站，甲、乙未与救助站办理交接手续便驾车离去。第二天，救助站人员发现丙倒在救助站门口，赶紧送往医院，不治身亡。经检查，丙因失血过多而死亡，如果及时得到救助则不会死亡。下列说法正确的有？

A.甲、乙没有正式编制，不是国家机关工作人员，因此不可能构成渎职犯罪

- B.甲、乙的行为构成不作为犯罪
- C.甲、乙的不作为与丙的死亡结果存在因果关系
- D.甲、乙构成玩忽职守罪

【答案】BCD

【解析】

考点：渎职罪 A 项，渎职罪是身份犯，主体是国家机关工作人员。刑法上认定国家工作人员及国家机关工作人员，不是看有无正式编制，而是看是否从事公务。

甲、乙虽然没有编制，但是在从事巡逻这种公务活动，此时属于国家机关工作人员，具有渎职罪的主体身份。因此，A 项说法错误。B 项，甲、乙作为巡逻的警察，负有救助义务。不作为包括两种方式，一是不履行作为义务，二是不正确履行作为义务。甲、乙虽然履行了作为义务，但没有正确履行作为义务，也即履行作为义务不到位，没有将丙交到救助站人员手中。由此造成严重后果，因此甲、乙构成不作为犯罪。B 项说法正确。C 项，不作为犯罪的因果关系的判断公式是，如果履行了作为义务，则结果便不会发生，那么不履行作为义务便是结果发生的原因。题中告知，如果甲、乙及时将丙交到救助站人员手里，丙得到及时救助，丙便不会死亡，因此，甲、乙的不作为与丙的死亡存在因果关系。C 项说法正确。D 项，（1）客观上，甲、乙具有渎职犯罪的主体身份，甲、乙的行为是不作为，由此导致严重后果。（2）主观上，甲、乙对死亡结果存在过于自信的过失，也即认为自己这样做（送到门口）能够避免死亡结果的发生，实际上没有避免。因此，甲乙构成玩忽职守罪。D 项说法正确。综上所述，本题答案为 BCD。

290、朱某系某县民政局副局长，率县福利企业年检小组到同学黄某任厂长的电气厂年检时，明知该厂的材料有虚假、残疾员工未达法定人数，但朱某以该材料

为准，使其顺利通过年检。为此，电气厂享受了不应享受的退税优惠政策，获取退税 300 万元。黄某动用关系，帮朱某升任民政局局长。检察院在调查朱某时发现，朱某有 100 万元财产明显超过合法收入，但其拒绝说明来源。在审查起诉阶段，朱某交代 100 万元系在澳门赌场所赢，经查证属实。关于朱某帮助电气厂通过年检的行为，下列正确的是：

- A. 其行为与国家损失 300 万元税收之间，存在因果关系
- B. 属滥用职权，构成滥用职权罪
- C. 属徇私舞弊，使国家税收遭受损失，同时构成徇私舞弊不征、少征税款罪
- D. 事后虽获得了利益（升任局长），但不构成受贿罪

【答案】ABD

【解析】

A 选项：本案中，朱某为民政局副局长，其明知电气厂的材料有虚假、残疾员工未达法定人数，但仍以该材料为准，使其顺利通过年检。电气厂因此享受了不应享受的退税优惠政策，获取退税 300 万元。朱某帮助电气厂通过年检的行为与国家损失 300 万元税收之间，存在直接的因果关系。因此，A 选项正确。B 选项：《刑法》第 397 条规定的滥用职权罪是指，国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。朱某作为国家机关工作人员，在明知电气厂造假以骗取退税资格的情况下，仍然利用其职权帮助电气厂获得该资格，最终使国家税收遭受 300 万元的损失，该行为构成滥用职权罪。因此，B 选项正确。C 选项：《刑法》第 404 条规定的徇私舞弊不征、少征税款罪是指税务机关的工作人员徇私舞弊，不征或者少征应征税款，致使国家税收遭受重大损失的行为。朱某不是税务机关的工作人员，也未与税务机关工作

人员相勾结，故朱某的行为不成立徇私舞弊不征、少征税款罪。因此，C选项错误。D选项：受贿罪中所收受的“财物”是指具有价值的可以管理的有体物、无体物以及财产性利益。朱某虽然事后获得了利益（升任局长），但“升任局长”不属于财物或者财产性利益，不成立受贿罪。D选项正确。综上所述，本题答案为ABD。